חוברת 1 · סיכום מלא

משפט מנהלי

הסיכום המקיף

מושגים, סעיפי חוק, פסקי דין, טבלאות השוואה וטיפים למבחן

14 פרקים

הוכן ונערך ע״י

אילן פרץ

תוכן העניינים

סיכום לפי פרקים

1 מבוא — מהו המשפט המנהלי ומבנה הביקורת השיפוטית

2 עקרון חוקיות המנהל וחובת הנאמנות של הרשות

3 על מי חל המשפט המנהלי — גופים ציבוריים, דו-מהותיים ודואליות נורמטיבית

4 פרשנות החוק המסמיך וכלל ההסדרים הראשוניים

5 מקורות הסמכות — סמכות שיורית, סמכות עזר, סמכות טבועה וסיווג סמכויות

6 עצמאות שיקול הדעת — הלכת מיכלין, הנחיות מנהליות ונטילת סמכות

7 התשתית העובדתית — הלכת יורונט והראיה המנהלית

8 כללי הצדק הטבעי — שימוע, ניגוד עניינים, הנמקה והיוועצות

9 פרסום תקנות והוראות מנהל ותחילת תוקף

10 שיקולים זרים, שוויון והפליה

11 עילת הסבירות

12 עילת המידתיות ומשקל ראוי לזכויות יסוד

13 עילות הסף וערכאות השיפוט — בג"ץ ובית המשפט לעניינים מנהליים

14 הבטחה מנהלית, השתק ותוצאות הפגמים — ושיטת פתרון למבחן

פרק 1

מבוא — מהו המשפט המנהלי ומבנה הביקורת השיפוטית

1.1 מבוא — למה זה חשוב ומה מקומו בתמונה הגדולה

המשפט המנהלי עוסק ב**החלטה המנהלית** — כל החלטה או פעולה של הרשות המבצעת: משרד ממשלתי שדוחה בקשה לרישיון, עירייה שמטילה קנס, ביטוח לאומי שמסרב לקצבה, צבא שקובע תוואי גדר, שר שמתקין תקנות. אפשר להסתכל עליו משתי נקודות מבט: **מעיני האזרח** — איך תוקפים החלטה מנהלית; ו**מעיני הרשות** — איך מקבלים החלטה שתעמוד בביקורת שיפוטית. בפרק נבנה את "מפת הדרכים" של הקורס כולו: מהו המשפט המנהלי, במה הוא שונה מהמשפט החוקתי, מהן ארבע השאלות שכל תקיפה מנהלית מעוררת, ומהם שני הרעיונות שמהם נגזר הכל — **הפרדת הרשויות** ו**חובת הנאמנות**.

1.2 הגדרה

✦ הגדרה — משפט מנהלי

משפט מנהלי הוא התחום המשפטי שעוסק ב**סמכויות** גופי המנהל, ב**פרוצדורה** של הפעלת הסמכויות, ב**שיקולים המהותיים** של הפעלתן, וב**פיקוח השיפוטי** על הפעלתן התקינה.

מיהם גופי המנהל? המדינה, הממשלה ומשרדיה, המשטרה, הצבא, שירות בתי הסוהר, הרשויות המקומיות (עיריות, מועצות מקומיות ואזוריות), תאגידים שהוקמו בחוק (ביטוח לאומי, בנק ישראל, רשות העתיקות) ועוד. (מי עוד כפוף למשפט המנהלי — פרק 3.)

היקף: בכל יום מתקבלות עשרות אלפי החלטות מנהליות. לכן תקיפה מנהלית נפוצה הרבה יותר מתקיפה חוקתית.

1.3 פירוק ההחלטה — מה בדיוק תוקפים?

החלטה אחת יכולה להכיל **כמה החלטות**. דוגמה: מכתב מהמשרד להגנת הסביבה מחייב לנקות זיהום ולשלם קנס — אלה שתי החלטות. אפשר לתקוף אחת או את שתיהן; ההכרעה מה לתקוף היא של הלקוח יחד עם עורך הדין.

יתרה מזו, החלטה בנויה לעיתים קרובות על **שרשרת החלטות**: הקנס הוטל לפי הנחיות של מנכ"ל המשרד, שהוסמך בתקנות שהתקין השר, מכוח חוק. לכן התהליך הוא: (1) **לבודד** את ההחלטה שתוקפים; (2) **לבדוק את כל השרשרת** — פגם בחוליה מוקדמת עשוי להפיל את ההחלטה הסופית.

1.4 ארבע השאלות הבסיסיות של כל תקיפה מנהלית

#	השאלה	מה בודקים
1	**לאן פונים?** (סמכות השיפוט)	בית המשפט לעניינים מנהליים; בג"ץ; בית הדין לעבודה (למשל בהחלטות ביטוח לאומי); או גוף מעין-שיפוטי — כמו ועדת ערר לתכנון ובנייה (פרק 13)
2	**האם עומדים בתנאי הסף?**	"עילות הסף": זכות עמידה, שפיטות, שיהוי (בדרך כלל 45 ימים — "התיישנות" קצרה של המשפט המנהלי), מעשה עשוי, מיצוי הליכים, ניקיון כפיים, עתירה תיאורטית (פרק 13)
3	**אילו טענות אפשר לטעון?** (העילות המהותיות)	שלוש קבוצות — ראו להלן. בניגוד למשפט האזרחי, כאן אפשר לטעון, למשל, שהחלטה **אינה סבירה**
4	**איזה סעד?** (תוצאות הפגמים)	ביטול ההחלטה, החזרה לדיון מחדש, צו עשה או צו מניעה. בית המשפט המנהלי כמעט אף פעם אינו פוסק פיצויים (פרק 14)

1.5 לב הקורס — שלוש קבוצות של טענות מהותיות

קבוצה	השאלה	דוגמאות	פרקים

1. סמכות	האם הגורם שהחליט מוסמך לכך?	אין הסמכה בחוק; הסמכה כללית מדי לפגיעה בזכויות; חריגה מגבולות ההסמכה; אי-הפעלת שיקול דעת עצמאי	6–2
2. פרוצדורה	האם ההחלטה התקבלה בתהליך הנכון?	העדר תשתית עובדתית; אי-מתן זכות טיעון ועיון (שימוע); העדר הנמקה; פגם בפרסום; ניגוד עניינים, משוא פנים ודעה קדומה	9–7
3. שיקול דעת (מהות)	גם אם הייתה סמכות והפרוצדורה תקינה — האם ההחלטה עצמה פגומה?	שיקולים זרים; הפליה; חוסר סבירות; חוסר מידתיות; אי-מתן משקל ראוי לזכויות יסוד	12–10

★ טיפ למבחן — מה לעשות במבחן

בכל תרחיש עובדתי — עברו על שלוש הקבוצות לפי הסדר. כך לא תחמיצו טענה.

1.6 דוגמה מלאה — בית סוריק (בג"ץ 2056/04)

⚖ פסק דין — עובדות והכרעה

העובדות: בתחילת שנות ה-2000, אחרי גל פיגועי התאבדות, הוחלט להקים גדר הפרדה. תוואי הגדר נקבע בידי מפקד כוחות צה"ל באזור; בקטע מסוים צפונית-מערבית לירושלים, ליד הכפר בית סוריק, הגדר עברה **בין הכפר לבין אדמותיו החקלאיות**. תושבי הכפר עתרו.

הטענות — מסודרות לפי שלוש הקבוצות:

- **סמכות:** המפקד הצבאי נעדר סמכות להוציא את צווי התפיסה של הקרקע.
- **פרוצדורה:** הצווים לא פורסמו ולא הובאו לידיעת רוב בעלי הקרקעות; העותרים שמעו עליהם במקרה, וקיבלו ארכה של ימים ספורים בלבד להשיג עליהם — כלומר, לא שותפו ולא ניתנה להם

זכות טיעון נאותה.

- **שיקול דעת:** הגדר פוגעת בזכויות יסוד — קניין, חופש תנועה, פרנסה וחופש עיסוק — והשיקולים הביטחוניים אינם יכולים להצדיק פגיעה כה חמורה; הפגיעה **אינה מידתית**, ועולה בהרבה על התועלת.

(בית המשפט קיבל את העתירה בחלקה, בעיקר מטעמי מידתיות — פרק 12.)

1.7 משפט מנהלי ומשפט חוקתי

	משפט חוקתי	משפט מנהלי
עניינו	(1) היחסים בין שלוש הרשויות; (2) זכויות היסוד והגנתן החוקתית	היחסים בין האזרח לבין **הרשות המבצעת**
מה תוקפים	**חוק** של הכנסת — בטענה שהוא סותר חוק יסוד ואינו עומד בפסקת ההגבלה (ולעיתים — פגמים בהליך החקיקה)	**החלטה** של הרשות המבצעת: תקנות, הנחיות, החלטות פרטניות
יחס לחוק	החוק עצמו במחלוקת	החוק **נתון**; אפשר רק לפרש אותו
היקף	רחב בנושאים, מעט מקרים	צר בנושא, אינספור מקרים

אזור החפיפה: טענה שהחלטה מנהלית **פוגעת בזכויות יסוד** — צריך לזהות קודם את הזכות החוקתית (חוקתי), ואז לבחון איזה משקל ניתן לה בהחלטה (מנהלי). בעתירה אחת אפשר לשלב תקיפה חוקתית ומנהלית. הכלל: אם הטענה היא ש**לשון החוק** פוגעת בזכות — חוקתית; אם ה**החלטה** פוגעת בזכות (כמו מיקום הגדר) — מנהלית.

יישום — הצעות לשינוי מערכת המשפט (2023): רוב ההצעות שעלו נגעו למשפט החוקתי (הרכב הוועדה לבחירת שופטים, פסקת התגברות, רוב מיוחד לפסילת חוקים, חסינות חוקי יסוד מביקורת, מעמד היועצים המשפטיים). ההצעה שנגעה במישרין למשפט המנהלי — **ביטול עילת הסבירות**: עותר נגד החלטה מנהלית היה מאבד טענה אחת מתוך ארגז הכלים (פרק 11).

1.8 המקורות הפורמליים — רוב המשפט המנהלי הוא פסיקה

§ סעיף — 15(ד)(2) לחוק יסוד: השפיטה

— בג"ץ מוסמך "לתת צווים לרשויות המדינה, לרשויות מקומיות, לפקידיהן ולגופים ולאנשים אחרים הממלאים תפקידים ציבוריים על פי דין, לעשות מעשה או להימנע מעשות מעשה במילוי תפקידיהם כדין, ואם נבחרו או נתמנו שלא כדין — להימנע מלפעול".

הסעיף קובע **שבג"ץ מוסמך** — אבל לא **מתי**. אין בישראל "חוק סדרי מנהל" כללי. לכן, ברוח המשפט האנגלי, בתי המשפט קבעו — מקרה אחר מקרה — מתי מתערבים:

- **עקרון הסמכות** — פסיקה (אין חוק שקובע שהחלטה צריכה להתקבל בסמכות).
- **הפרוצדורה** — בעיקר פסיקה (זכות טיעון, תשתית עובדתית), עם חוקים ספציפיים: חוק חופש המידע (זכות עיון), חוק התכנון והבנייה (זכויות התנגדות), **חוק לתיקון סדרי המינהל (החלטות והנמקות), התשי"ט–1958** (חובת הנמקה).
- **מהות שיקול הדעת** — כולו פסיקה: שיקולים זרים, סבירות, מידתיות.
- **מבנה הביקורת** — עילות הסף, העילות המהותיות, תוצאות הפגמים — פסיקה.

הספרות המרכזית: **יצחק זמיר, "הסמכות המינהלית"**, ו**דפנה ברק-ארז, "משפט מינהלי"**.

1.9 המקורות המהותיים — שני רעיונות מסדרים

רעיון	מה הוא מסדר
הפרדת הרשויות	את דרישת ה**סמכות**: הרשות המבצעת פועלת רק במסגרת מה שהמחוקקת הסמיכה, והשופטת מוודאת שלא חרגה (פרק 2)
חובת הנאמנות של עובד הציבור	את דרישות ה**פרוצדורה** וה**שיקול הדעת**: עובד הציבור הוא נאמן שמנהל את נכסי הציבור, ולכן חייב לאסוף נתונים, לשמוע, לנמק, להימנע מניגוד עניינים ומשיקולים זרים, לפעול בסבירות ובמידתיות (פרק 2)

לרשות השופטת שני תפקידים: להכריע בסכסוכים בין אזרחים, ולהכריע בסכסוכים בין האזרח לבין הרשות המבצעת — ולוודא שהמבצעת אינה חורגת ממה שהמחוקקת קבעה.

1.10 מלכודות נפוצות

! שים לב — מלכודות נפוצות

- לבלבל בין תקיפת **חוק** (חוקתי) לתקיפת **החלטה** (מנהלי).
- לחשוב שיש חוק כללי שקובע את עילות ההתערבות — רובן נקבעו בפסיקה.
- לקפוץ ישר לשיקול הדעת ולשכוח לבדוק סמכות ופרוצדורה.
- לתקוף את ההחלטה הסופית בלי לבדוק את שרשרת ההחלטות שעליה נשענה.
- לשכוח שבעתירה מנהלית פיצויים הם חריג נדיר.

1.11 שלד לפתרון שאלה — מהלך קבוע בארבעה צעדים

בכל שאלת יישום במשפט מנהלי כדאי לעבוד באותו סדר. הסדר חוסך טעויות, כי הוא מונע מכם לקפוץ לטענה המרשימה (סבירות, מידתיות) לפני שבדקתם את הבסיס.

1. **זהו את ההחלטה ואת שרשרת ההחלטות** – מה בדיוק תוקפים, מי החליט, ועל מה ההחלטה נשענת (חוק, תקנות, הנחיה).
2. **בדקו את שער הכניסה** – לאן פונים, ואם עומדים בעילות הסף (עמידה, שיהוי, מעשה עשוי, מיצוי הליכים, ניקיון כפיים).
3. **עברו על שלוש קבוצות הטענות לפי הסדר** – סמכות, פרוצדורה, שיקול דעת – ולכל טענה כתבו: הכלל, יישום על העובדות, מסקנה.
4. **סיימו בסעד** – ביטול, החזרה לרשות או צו; ושקלו אם הפגם מצדיק בטלות מלאה או יחסית (פרק 14).

★ טיפ למבחן — סדר הכתיבה בבחינה

פתחו בשורה אחת שמסווגת את הטענה ("זו טענת סמכות"), ורק אחר כך פרטו. בודק שרואה סיווג נכון מיד מבין שהסדר בראשכם.

1.12 מלכודות בפתרון שאלות — טבלה

הטעות	למה היא שגויה	התיקון
לפתוח בסבירות	סבירות היא כלי אחרון; ייתכן שההחלטה פגומה כבר בסמכות או בפרוצדורה	לבדוק קודם סמכות ופרוצדורה
לערבב חוקתי ומנהלי	תקיפת לשון החוק היא חוקתית; תקיפת החלטה היא מנהלית	לשאול: מה נתקף – החוק או ההחלטה?
להתעלם משרשרת ההחלטות	פגם בתקנה או בהנחיה יכול להפיל החלטה שנראית תקינה	לעקוב אחורה עד לחוק המסמיך
לשכוח עילות סף	עתירה מצוינת עלולה להידחות בשל שיהוי או מעשה עשוי	לבדוק תנאי סף לפני המהות
לבקש פיצויים בעתירה	הסעד הרגיל הוא ביטול או צו; פיצויים הם חריג נדיר	לבקש צו או ביטול, ולבחון הליך נפרד לפיצוי

1.13 תרגיל פתור — מכתב אחד ושתי החלטות

✎ דוגמה — הריסה וקנס

העובדות: עירייה שלחה לבעל בית מכתב אחד, שבו נאמר: "תוספת הבנייה בגגך נבנתה ללא היתר – עליך להרוס אותה בתוך 30 ימים ולשלם קנס". בעל הבית מבקש לתקוף את המכתב.

הפתרון:

1. **פירוק:** במכתב שתי החלטות נפרדות – צו הריסה וקנס. כל אחת עשויה להיתקף בעילות שונות, ואפשר לתקוף אחת בלבד.
2. **שרשרת:** לבדוק על מה נשענת כל החלטה: איזה חוק מסמיך את העירייה, האם הוציא את המכתב מי שהוסמך לכך, והאם יש הנחיות פנימיות.
3. **שער הכניסה:** לבדוק לאן פונים, והאם יש חלון זמן קצר. ההריסה היא מעשה בלתי הפיך, ולכן יש למהר ולבקש צו ביניים. אם הבית ייהרס לפני הדיון, תיווצר עילת סף של מעשה עשוי.
4. **הטענות:** סמכות (מי חתם על הצו), פרוצדורה (האם ניתנה זכות טיעון), שיקול דעת (האם הקנס מידתי ואכיפה לא סלקטיבית).
5. **סעד:** ביטול הצו, או החזרה לעירייה לדיון מחדש לאחר שימוע.

1.14 סיכום הפרק

✔ **שורה תחתונה — סיכום הפרק**

- המשפט המנהלי הוא דיני ההחלטה של הרשות המבצעת: סמכות, פרוצדורה, שיקול דעת, ופיקוח שיפוטי.
- ארבע שאלות בכל תקיפה: לאן פונים, האם עומדים בסף, אילו טענות, איזה סעד.
- שלוש קבוצות טענות מהותיות: סמכות (פרקים 2–6), פרוצדורה (7–9), שיקול דעת (10–12).
- רוב הכללים נקבעו בפסיקה; בסיס הסמכות של בג"ץ הוא סעיף 15(ד)(2) לחוק יסוד: השפיטה.
- שני רעיונות מסדרים: הפרדת רשויות (סמכות) וחובת נאמנות (פרוצדורה ושיקול דעת).

1.15 מילון מושגים

- **החלטה מנהלית** — החלטה או פעולה של גוף מנהלי / ציבורי.
- **ביקורת שיפוטית** — בחינת חוקיות ההחלטה בידי בית המשפט.
- **עילות סף** — תנאים לכניסה לבית המשפט.
- **עילות מהותיות** — הטעמים שבגללם ההחלטה פגומה.
- **שיהוי** — איחור בהגשת עתירה; "ההתיישנות" של המשפט המנהלי.
- **מעשה עשוי** — פעולה שכבר בוצעה ואינה ניתנת להשבה.

1.16 נקודות מפתח למבחן

✔ **שורה תחתונה — עיקרי הפרק**

- הגדרה: סמכויות, פרוצדורה, שיקולים מהותיים ופיקוח שיפוטי על גופי המנהל.
- ארבע שאלות: לאן פונים; תנאי סף; אילו טענות; איזה סעד.
- שלוש קבוצות טענות: סמכות; פרוצדורה; שיקול דעת.
- חוקתי (תקיפת חוק) מול מנהלי (תקיפת החלטה); חפיפה — משקל ראוי לזכויות יסוד.
- ס' 15(ד)(2) לחוק יסוד: השפיטה; רוב הדין — פסיקה; חוק ההנמקות 1958, חופש המידע.
- שני רעיונות מסדרים: הפרדת רשויות (סמכות) וחובת נאמנות (פרוצדורה ושיקול דעת).

1.17 שאלות בסגנון המבחן

✎ דוגמה — שאלה בסגנון המבחן (1)

עתירה נגד החלטה של שר הפנים טוענת: (א) השר אינו מוסמך לקבל את ההחלטה; (ב) לא ניתנה לעותר הזדמנות לטעון את טענותיו; (ג) ההחלטה חורגת ממתחם הסבירות. איזו קביעה **נכונה**?

א. כל הטענות הן טענות של שיקול דעת. ב. (א) — סמכות; (ב) — פרוצדורה; (ג) — שיקול דעת. ג. (א) ו-(ב) — סמכות; (ג) — פרוצדורה. ד. כל הטענות חוקתיות, כי מדובר בשר.

התשובה וההסבר

ב. זו בדיוק החלוקה לשלוש קבוצות הטענות: סמכות (מי מוסמך), פרוצדורה (שימוע), שיקול דעת (סבירות). ד' שגויה — תקיפת החלטה של שר היא מנהלית, לא חוקתית.

✎ דוגמה — שאלה בסגנון המבחן (2)

עו"ד מקבל מלקוח מכתב מהעירייה המורה לו להרוס תוספת בנייה ולשלם קנס. מה הצעד הראשון הנכון?

א. להגיש מיד עתירה לבג"ץ נגד המכתב כולו. ב. לבודד את ההחלטות (הריסה; קנס), להחליט מה לתקוף, ולבדוק את שרשרת ההחלטות שעליהן הן נשענות. ג. לתבוע פיצויים בבית משפט השלום. ד. להמתין עד שהעירייה תבצע את ההריסה.

התשובה וההסבר

ב. החלטה אחת עשויה להכיל כמה החלטות, ולהישען על שרשרת. ד' מסוכנת במיוחד — אחרי ההריסה תעמוד בפני העותר עילת סף של "מעשה עשוי".

1.18 שאלות לחשיבה

1. למה רוב המשפט המנהלי נקבע בפסיקה ולא בחקיקה?

תשובה אפשרית: ניסיונות לחוקק "חוק סדרי מנהל" כללי לא צלחו; הישראלי ירש מהמשפט האנגלי את המסורת שבה בתי המשפט מפתחים את עילות ההתערבות מקרה אחר מקרה. היתרון — גמישות; החיסרון — חוסר ודאות, וביקורת על "אקטיביזם".

2. איך שני הרעיונות המסדרים משלימים זה את זה?

תשובה אפשרית: הפרדת הרשויות עונה על השאלה **מי** רשאי לפעול ובאילו גבולות; חובת הנאמנות עונה על השאלה **איך** עליו לפעול — בתהליך הוגן ומשיקולים ענייניים. רשות יכולה לפעול בסמכות ובכל זאת להפר נאמנות, ולהפך.

פרק 2

עקרון חוקיות המנהל וחובת הנאמנות של הרשות

2.1 מבוא — למה זה חשוב ומה מקומו בתמונה הגדולה

שני העקרונות שבפרק הזה הם יסודות הקורס. **עקרון חוקיות המנהל** — "האל"ף-בי"ת של המשפט המנהלי" — קובע שרשות ציבורית רשאית לעשות **רק** מה שהחוק הסמיך אותה לעשות. **חובת הנאמנות** קובעת שהרשות היא נאמן של הציבור, ומכאן נגזרות חובות ההגינות, השוויון, הסבירות וכללי הפרוצדורה. נלמד את מקורם בפסיקה מימי קום המדינה, את החריג הנדיר (ירדור), את יישומם היום, ואת הצד השני של המטבע — חובת ההגינות של הפרט כלפי הרשות.

2.2 שלטון החוק — שתי דרישות

דרישה	על מי חלה	תוכן
שלטון החוק הכללי (עקרון ההתאמה לחוק)	על כולם — גם על המדינה	גם המדינה, כמו כל אדם, חייבת לפעול לפי החוק ולא בניגוד לו
דרישת ההסמכה בחוק (חוקיות המנהל)	רק על גופים ציבוריים	גוף ציבורי אינו רשאי לבצע **שום** פעולה, אלא אם יש לו סמכות בחוק לעשותה

ההבדל מהפרט: לאדם פרטי מותר כל מה שאינו אסור. לרשות — אסור כל מה שאינו מותר. העיקרון נובע מהפרדת הרשויות: המחוקקת קובעת כללים, המבצעת מבצעת אותם, והשופטת מוודאת שהמבצעת לא חרגה.

העיקרון אינו קבוע בשום חוק — הוא נקבע בפסיקה מקום המדינה.

2.3 בז'רנו — פסק הדין המכונן (בג"ץ 1/49)

⚖ פסק דין — עובדות והכרעה

העובדות: בז'רנו וחבריו עסקו בתיווך מול משרד הרישוי: תמורת עמלה טיפלו בטסטים, ברישיונות ובהעברות בעלות במקום בעלי הרכב. עלו תלונות על הנחות, מתנות בחגים ועקיפת תורים. שר המשטרה הורה שאיש לא ייכנס למשרד הרישוי אלא אם הוא בעל הרכב. המתווכים, שפרנסתם נגדעה, עתרו. המדינה טענה: המשרדים שלנו, ומותר לנו לאסור כניסה.

ההכרעה: העתירה התקבלה. ללשכת הרישוי לא הייתה סמכות בחוק למנוע מאנשים לעסוק כמתווכים. וההחלטה פגעה ב**חופש העיסוק** — ולכן נדרשת הסמכה מפורשת עוד יותר.

ההלכות:

1. לרשות ציבורית מותר לעשות רק מה שהחוק מסמיך אותה; ואם ההחלטה פוגעת בזכויות — נדרשת **הסמכה מפורשת ומפורטת**.
2. גם כשהרשות מוסמכת — עליה לפרש את סמכותה באופן שימנע, ככל האפשר, פגיעה בזכויות הפרט.
3. ובלשון שהפכה לאבן יסוד: על הפקיד **להוכיח שיש צידוק** לאיסור שהוא אוסר.

2.4 שייב — גם מול ראש הממשלה (בג"ץ 144/50)

⚖ פסק דין — עובדות והכרעה

הרקע: ד"ר ישראל שייב (לימים אלדד), מראשי הלח"י, מורה לתנ"ך, ביקש לעבוד בבית ספר בתל אביב. המנהל נזקק לאישור משרד החינוך, שפנה למשרד הביטחון — ושר הביטחון (שהיה גם ראש הממשלה) התנגד: שייב "מטיף בספרו ובעיתונו להרים יד ולפעול בנשק נגד חיילי צבא ההגנה לישראל".

ההכרעה: העתירה התקבלה. לשר הביטחון **אין סמכות** להורות בעניין העסקת מורים, ולכן ההחלטה בטלה — מטעמים ביטחוניים או מכל טעם אחר. בית המשפט לא נרתע מלהכריע נגד ראש הממשלה ושר הביטחון: דרישת הסמכות היא יסודית, ואין לפגוע בחופש העיסוק בלי הסמכה ברורה ומפורשת. (בשייב נקבעה גם הלכה בעניין עצמאות שיקול הדעת — פרק 6.)

2.5 החריג — ירדור (ע"ב 1/65), וגבולותיו — ניימן (ע"ב 2/84)

ירדור: "רשימת הסוציאליסטים", שהורכבה מאנשי תנועה שהוצאה מחוץ לחוק, ביקשה להתמודד לכנסת השישית. ועדת הבחירות פסלה אותה, כי היא שוללת את קיום המדינה — **בלי שהייתה לה סמכות בחוק** לפסול מטעם כזה (רק מטעמים טכניים). בית המשפט (השופטים זוסמן ואגרנט ברוב) דחה את הערעור: יש מקרים שבהם **הדמוקרטיה חייבת להתגונן** מפני הקמים עליה ("דמוקרטיה מתגוננת"), ואז אפשר לפעול גם בלי הסמכה. עקרונות היסוד של השיטה — מדינה יהודית ודמוקרטית — עשויים לגבור, במקרים קיצוניים, על חוקיות המנהל. **"עקרונות על-חוקתיים"**.

ניימן: ועדת הבחירות פסלה את רשימת "כך" ואת "הרשימה המתקדמת לשלום". הנשיא שמגר קיבל את הערעור: לא ביטל את ירדור, אבל קבע שזה היה מקרה חריג; הדמוקרטיה חזקה דיה להכיל גם רשימות כאלה, ולוועדה אין סמכות בחוק. **אחרי ניימן תוקן החוק** והוסמכה ועדת הבחירות לפסול רשימות שוללות.

המסקנה: ירדור היא הלכה **מצומצמת לנסיבותיה**; מאז 1965 לא חזרו עליה. עקרון החוקיות שריר וקיים.

2.6 העיקרון היום

פרחי ביקל נ' הוועדה המקומית ראשון לציון: הוועדה דרשה מיזם, כתנאי להיתר בנייה, **כתב שיפוי**. בית המשפט: אין לה סמכות לכך. "עקרון חוקיות המינהל... מורה כי כל רשות מנהלית חייבת לפעול בתוך **דל"ת אמות הסמכות** שהוקנתה לה בחוק... הפעולה המנהלית חייבת להיות מבוססת על הסמכה בחוק (או מכוחו), ואסור לה לחרוג מן הגבולות שנקבעו להסמכה... על עקרון זה נאמר כי הוא **האל"ף-בי"ת של המשפט המינהלי**."

רופאים לזכויות אדם נ' השר לביטחון פנים (בג"ץ 158/21): בתחילת מבצע החיסונים לקורונה, שר הבריאות — **המוסמך** לפי פקודת בריאות העם — קבע שאסירים וסוהרים יחוסנו בעדיפות ראשונה (בתי כלא הם מוקד הדבקה). השר לביטחון פנים הורה לשב"ס שלא לחסן אסירים (ובעיקר ביטחוניים) עד לאישורו. בג"ץ: ההנחיה ניתנה ב**חוסר סמכות מובהק** ובניגוד לדין, ו"ממילא היא נעדרת כל תוקף משפטי"; המשיב התעלם מהחלטת הגורם המוסמך ומעמדת היועץ המשפטי לממשלה.

עבאדה נ' מינהל מקרקעי ישראל: קרקע שהוקצתה **שלא כדין** נלקחה בחזרה, אף שהמקבל נפגע — פעולה ללא סמכות אינה יוצרת זכות. (על הגנת המסתמך — פרק 14.)

2.7 חובת הנאמנות — "בעיית הנציג"

חובת הנאמנות היא מושג חוצה תחומים, שנובע מ**בעיית הנציג**: כל מי שיש לו כוח לפעול בנכסי הזולת, כשיש פער מידע וניגוד אינטרסים, עלול לנצל את כוחו לטובתו האישית. דוגמה: אפוטרופוס של פסול דין שמשכיר את דירת החסוי לבתו בזול. הפתרון המשפטי — **חובת אמון** משני רכיבים:

1. חובה לפעול **רק לטובת המיוצג**;
2. איסור לפעול לטובתו האישית — ואף איסור להימצא במצב של **חשש** לכך (ניגוד עניינים).

במשפט המנהלי: כל עובד ציבור — מהפקיד הזוטר ועד ראש הממשלה — מחליט בנכסי הציבור (שר האוצר — בכסף של כולנו; פקיד הביטוח הלאומי — בכספי הביטוח). הוא ה**נציג**, והציבור — ה**מיוצג**.

מה נגזר מחובת הנאמנות: חובה לאסוף נתונים (כדי לקבל את ההחלטה הטובה ביותר); חובה לשמוע את מי שעלול להיפגע (הנציג אינו יודע הכל); חובת הנמקה (מי שכותב נימוק — חושב טוב יותר, ומאפשר ביקורת); איסור ניגוד עניינים; איסור שיקולים זרים; סבירות; מידתיות; שוויון.

2.8 חובת הנאמנות בפסיקה

פרץ נ' המועצה המקומית כפר שמריהו (בג"ץ 262/62): המועצה סירבה להשכיר אולם לקהילה רפורמית לתפילות. השופט זוסמן: "בהשתמשה בנכסיה או בעשותה את פעולותיה, נטלה הרשות על עצמה **תפקיד של נאמן כלפי הציבור**, ובתור שכזה חייבת הרשות **להתייחס יחס שווה אל שווים**, ומשהפרה עקרון יסוד זה והפלתה אזרח שלא כדין, הרי זו עילה להתערבותו של בית משפט זה." — פסק הדין הראשון על חובת האמון; ממנה נגזרת **חובת השוויון**.

שפירא נ' הוועד המחוזי של לשכת עורכי הדין (בג"ץ 142/70): לרשות "אין דבר משלה": כל מה שיש לה מופקד בידיה כנאמן, והיא שואבת את סמכותה מהציבור — ולכן חייבת להפעילה בהגינות.

מרכז הקבלנים והבונים (בג"ץ 840/79): "המדינה באמצעות הפועלים בשמה היא **נאמן של הציבור**, ובידיה הופקד האינטרס הציבורי והנכסים הציבוריים לשם שימוש בהם לטובת הכלל... מעמד מיוחד זה הוא המטיל על המדינה את החובה לפעול בסבירות, ביושר, בטוהר לב ובתום לב. אסור לה למדינה להפלות, לפעול מתוך שרירות או חוסר תום לב או להימצא במצב של ניגוד עניינים. עליה לקיים את כללי הצדק הטבעי. קיצורו של דבר, עליה **לפעול בהגינות**."

אברהם נ' עיריית טבריה: גם כשהרשות פועלת במישור הפרטי (למשל בחוזה), חלות עליה חובות של רשות מנהלית — היא מחזיקה בנכס כנאמן. **תמיד דואליות** (פרק 3).

2.9 הצד השני — חובת ההגינות של הפרט כלפי הרשות

קונטרם נ' משרד האוצר — אגף המכס (בג"ץ 164/97): חברה ביקשה רישיון למחסן ערובה. אחד התנאים — להוכיח בעלות או שכירות במחסן. היא הציגה "הסכם שכירות" שהיה למעשה רק **רשות שימוש**, וקיבלה את הרישיון. כשהתגלה הדבר — הרישיון נשלל, והעתירה נדחתה: קבלת דבר במרמה; החברה הפרה **חובת גילוי**, והמכס פעל כדין. שלוש עמדות בשאלה העקרונית:

שופט	העמדה
זמיר	הרשות, כנאמן, חייבת בהגינות — וחובה זו חלה כלפי כל אדם. וגם **הפרט חייב בהגינות כלפי השלטון**, מתוך תפיסה של שיתוף פעולה — חובה כללית

ברק אין חובה כללית כזו בחוק; אבל **חובת הגילוי** נגזרת מהצורך של הרשות לבסס **תשתית עובדתית** ראויה, כשהמידע מצוי בידי הפרט

חשין חובת הגינות של הפרט כלפי הרשות אינה קיימת, אלא אם נקבעה במפורש בחוק

ההלכה: חובת הגינות חלה על הפרט בפנייתו לרשות, ובמקרים שבהם מידע מהותי להחלטה מצוי בידיו — קיימת **חובת גילוי**.

יישומים נוספים — "נאמנות הציבור לרשות":

- **אילנית מרכז לשיקום נ' מדינת ישראל: שיהוי** בהעלאת התנגדות פוגע באינטרס הציבורי — הפרט אינו רשאי "לשבת על הגדר".
- **עיריית רמת השרון נ' טו-מז:** הקנס שהוטל לא היה תקין — אבל העותרת עצמה נהגה **בחוסר הגינות** (פעלה שלא כדין ולא שילמה), ולכן לא זכתה לסעד.

2.10 כשהנאמן "נאמן לעצמו"

הסכנה המובנית בבירוקרטיה: גוף ציבורי עלול לפתח **"נאמנות עצמית"** — לשמירת מעמדו, תקציבו ומקומות העבודה שבו — במקום נאמנות למטרה שלשמה הוקם; או "בירוקרטיה שוחקת" שמכבידה על האזרח. חובת הנאמנות היא הכלי המשפטי שמחזיר את הרשות למטרתה. דוגמאות:

- **בוצר נ' המועצה המקומית מכבים-רעות (בג"ץ 7081/93):** תלמיד עם מוגבלות ביקש שבית הספר יונגש. הרשות טענה למגבלות תקציב. בית המשפט חייב אותה לפעול — הרשות חייבת **לאזן** בין שיקולי תקציב לבין זכויות, ואינה יכולה להסתתר מאחורי "האתגר הבירוקרטי".
- **פרשת קו 300:** דוגמה קיצונית לגוף ש"נאמן לעצמו" — טיוח בתוך שירות ביטחון, הפוך מחובתו לציבור.

2.11 מלכודות נפוצות

! שים לב — מלכודות נפוצות

- לחשוב שעקרון החוקיות קבוע בחוק — הוא פרי הפסיקה.
- לחשוב שלרשות "מותר כל מה שאינו אסור" — זה כלל הפרט.
- לחשוב שירדור היא הלכה כללית — היא מצומצמת לנסיבותיה.
- לחשוב שחובת הנאמנות חלה רק על הרשות — יש גם חובת הגינות וגילוי של הפרט (קונטרם).
- לבלבל בין עמדות זמיר, ברק וחשין בקונטרם.

2.12 שלד לפתרון שאלה — חוקיות המנהל ונאמנות

1. **זהו את הפעולה** – מה הרשות עשתה או סירבה לעשות, ומי עשה זאת (שר, פקיד, ועדה).
2. **חפשו הסמכה** – האם יש חוק (או תקנה מכוחו) שמסמיך את הגורם הזה לעשות את הפעולה הזו. בלי הסמכה – הפעולה בטלה.
3. **בדקו אם הפעולה פוגעת בזכות** – אם כן, נדרשת הסמכה מפורשת ומפורטת יותר (בז'רנו), והפרשנות תהיה דווקנית.
4. **אם יש סמכות** – עברו לחובת הנאמנות: האם הרשות פעלה בשוויון, בהגינות, בלי ניגוד עניינים ולטובת הציבור.
5. **הצד השני** – האם העותר עצמו נהג בהגינות וגילה מידע מהותי (קונטרם, טו-מז)? אם לא, ייתכן שיישלל ממנו סעד.

2.13 מלכודות בפתרון שאלות — טבלה

הטעות	למה היא שגויה	התיקון
"לרשות מותר מה שלא נאסר"	זה כלל הפרט. לרשות מותר רק מה שהוסמכה לעשות	לחפש הסמכה בחוק

לחשוב שגורם בכיר מוסמך מעצם בכירותו לראות בירדור כלל כללי	שייב: גם שר הביטחון וראש הממשלה זקוקים להסמכה בחוק	לבדוק את מקור הסמכות של הגורם הספציפי
	ירדור חריג מצומצם לנסיבותיו; ניימן קבע שלא חוזרים עליו	להזכיר ירדור רק כחריג וגבולותיו
לחשוב שחובות ההגינות חלות רק על הרשות	קונטרם: גם הפרט חייב בהגינות ובגילוי מידע מהותי	לבחון את התנהגות העותר
להסיק שרשות במישור החוזי פטורה ממשפט מנהלי	אברהם נ' עיריית טבריה: חלות עליה חובות מנהליות גם בחוזה	להחיל דואליות נורמטיבית

2.14 תרגיל פתור — מאגר החניה של העירייה

✎ דוגמה — עירייה, הצעת חניה ושיפוי

העובדות: ועדה מקומית לתכנון ובנייה דורשת ממבקש היתר בנייה לחתום על כתב שיפוי, שבו הוא מתחייב לפצות את העירייה על כל תביעה שתוגש נגדה בקשר לבנייה. בחוק התכנון והבנייה אין הוראה המתירה דרישה כזו. המבקש מסרב, וההיתר נדחה.

הפתרון:

1. **כלל:** הרשות רשאית לעשות רק מה שהסמיכה אותה הדין (בז'רנו; פרחי ביקל). יש לבדוק איזה סעיף מסמיך.
2. **יישום:** דרישת שיפוי היא תנאי שלא נקבע בחוק, והיא גם פוגעת בקניין ובחופש הבנייה. פגיעה כזו מחייבת הסמכה מפורשת.
3. **מסקנה:** הדרישה חורגת מדל"ת אמות הסמכות, והדחייה מטעמה בטלה; הוועדה תדון מחדש בבקשה בלי התנאי.
4. **הערה:** אם המבקש הסתיר עובדות מהותיות בבקשתו, הרשות עשויה להעלות טענה של חוסר הגינות (קונטרם), אך זו לא תתקן את חוסר הסמכות.

2.15 סיכום הפרק

✔ שורה תחתונה — סיכום הפרק

- חוקיות המנהל: רשות רשאית לעשות רק מה שהחוק הסמיך אותה; הפרט רשאי הכל פרט למה שנאסר.
- שני מרכיבים בשלטון החוק: התאמה לחוק (על כולם) והסמכה בחוק (על רשויות).
- בז'רנו: פגיעה בחופש עיסוק מחייבת הסמכה מפורשת; על הפקיד להוכיח צידוק; פרשנות מצמצמת פגיעה.
- שייב: אפילו שר הביטחון נדרש להסמכה. ירדור: חריג מצומצם; ניימן: הסמכות חייבת להיות בחוק.
- חובת הנאמנות נגזרת מ"בעיית הנציג": שוויון (פרץ), הגינות (שפירא, מרכז הקבלנים), איסור ניגוד עניינים.
- הצד השני: חובת הגינות וגילוי של הפרט (קונטרם: זמיר, ברק, חשין).

2.16 מילון מושגים

- **עקרון חוקיות המנהל** — רשות פועלת רק מכוח הסמכה בחוק.
- **דל"ת אמות הסמכות** — גבולות ההסמכה.
- **דמוקרטיה מתגוננת** — הגנה מפני הקמים על הדמוקרטיה.
- **בעיית הנציג** — מי שפועל בנכסי זולתו עלול להעדיף את עצמו.
- **חובת אמון** — לפעול רק לטובת המיוצג; איסור ניגוד עניינים.
- **חובת גילוי** — חובת הפרט למסור לרשות מידע מהותי.

2.17 נקודות מפתח למבחן

✔ שורה תחתונה — עיקרי הפרק

- שתי דרישות: התאמה לחוק (כולם) והסמכה בחוק (רשויות).
- בז'רנו: הסמכה מפורשת לפגיעה בחופש העיסוק; לפרש סמכות כך שתימנע פגיעה; "על הפקיד להוכיח צידוק".
- שייב: אין סמכות — גם לשר הביטחון וראש הממשלה.
- ירדור (חריג, דמוקרטיה מתגוננת) מול ניימן (אין סמכות; תיקון החוק).
- היום: פרחי ביקל ("האל"ף-בי"ת"), רופאים לזכויות אדם (חיסונים — חוסר סמכות מובהק).
- חובת נאמנות: בעיית הנציג; פרץ (שוויון); שפירא; מרכז הקבלנים (הגינות).
- קונטרם: זמיר (הגינות כללית של הפרט), ברק (חובת גילוי מתשתית עובדתית), חשין (רק בחוק); הלכה — חובת גילוי.

2.18 שאלות בסגנון המבחן

✎ דוגמה — שאלה בסגנון המבחן (1)

שר הקליטה הורה למוסדות להשכלה גבוהה שלא לקבל לעבודה מרצים שחתמו על עצומה מסוימת. אין בחוק הוראה המסמיכה אותו לכך. מה הטענה החזקה ביותר נגד ההוראה?

א. חוסר סבירות. ב. חוסר סמכות — ובמיוחד כשמדובר בפגיעה בחופש העיסוק נדרשת הסמכה מפורשת. ג. שיהוי. ד. אין טענה — לשר מותר כל מה שאינו אסור.

התשובה וההסבר

ב. לפי בז'רנו ושייב, רשות רשאית לפעול רק מכוח הסמכה, ופגיעה בחופש העיסוק מחייבת הסמכה מפורשת. ד' מבטאת את הכלל החל על **פרט**, לא על רשות. טענת סבירות (א) נבחנת רק אם הייתה סמכות.

✎ דוגמה — שאלה בסגנון המבחן (2)

חברה קיבלה היתר מרשות לאחר שהציגה מסמך שהטעה את הרשות לגבי מצב עובדתי מהותי. כשהתגלה הדבר, הרשות ביטלה את ההיתר. לפי ההלכה, מה הדין?

א. הביטול פסול — הרשות הייתה צריכה לבדוק בעצמה. ב. הביטול כדין; על הפרט חלה חובת גילוי כשמידע מהותי מצוי בידיו. ג. הביטול פסול, כי אין חובות על הפרט כלפי הרשות. ד. הביטול כדין רק אם יש לכך הוראה מפורשת בחוק.

התשובה וההסבר

ב. זו הלכת קונטרם. ג' ו-ד' משקפות את עמדת חשין, שאינה ההלכה. אפשר להזכיר שזמיר ביסס זאת על חובת הגינות כללית, וברק — על הצורך בתשתית עובדתית.

2.19 שאלות לחשיבה

1. מדוע ירדור לא בוטלה במפורש, אך לא יושמה מאז?

תשובה אפשרית: בית המשפט מעדיף לצמצם תקדים חריג לנסיבותיו מאשר לבטלו — כך שמור "פתח חירום" לנסיבות קיצוניות, אך הכלל נשאר ברור. ובפועל, אחרי ניימן המחוקק הסדיר את הנושא, כך שהצורך בחריג פחת.

2. איך חובת הנאמנות מסבירה את חובת השמיעה וההנמקה?

תשובה אפשרית: נאמן חייב לקבל את ההחלטה הטובה ביותר עבור המיוצג. שמיעת הנפגע מוסיפה מידע ומשפרת את ההחלטה; ההנמקה מחייבת חשיבה מסודרת ומאפשרת ביקורת. שתיהן כלים להבטחת ההחלטה הטובה ביותר.

פרק 3

על מי חל המשפט המנהלי — גופים ציבוריים, דו-מהותיים ודואליות נורמטיבית

3.1 מבוא — למה זה חשוב ומה מקומו בתמונה הגדולה

לפני שבודקים אם החלטה פגומה, צריך לשאול: **האם בכלל חלים עליה כללי המשפט המנהלי?** נגד גוף פרטי אפשר לטעון רק טענות של המשפט הפרטי (חוסר תום לב, תקנת הציבור, תנאי מקפח). נגד גוף ציבורי — גם טענות ציבוריות (סמכות, שימוע, שיקולים זרים, סבירות, מידתיות, שוויון), שהן לרוב רחבות ומחמירות יותר. בפרק נמפה את הגופים: רשויות המדינה, רשויות מקומיות, תאגידים סטטוטוריים, חברות ממשלתיות — ובמיוחד את הקטגוריה המרתקת של **הגופים הדו-מהותיים**, שהפסיקה יצרה במהלך שנות ה-80 וה-90. נלמד את שלוש הדרכים שבהן המשפט הישראלי "הזרים" ערכים ציבוריים למגזר הפרטי.

3.2 הגופים של המשפט הציבורי — סעיף 15(ד)(2) לחוק יסוד: השפיטה

קבוצה	דוגמאות	הערות
רשויות המדינה ופקידיהן	משרדי הממשלה, צבא, משטרה, שב"ס	כולל את **הכנסת** ו**הנהלת בתי המשפט** כשהן פועלות כמעסיק או כמנהל — למשל מנכ"ל הכנסת שמפטר עובד
רשויות מקומיות ופקידיהן	עיריות, מועצות מקומיות ואזוריות	
גופים ואנשים הממלאים תפקיד ציבורי על פי דין	תאגידים סטטוטוריים: בנק ישראל, המוסד לביטוח לאומי, רשות שדות התעופה; וגם יחידים: יו"ר ועדת חקירה ממלכתית, חבר ועדה לתכנון ובנייה	המחוקק הקים אותם **בחוק** — אבל במכוון **לא כחלק מהמדינה**

למה תאגיד סטטוטורי? כדי להבטיח עצמאות או אופי מיוחד. **בנק ישראל** — כדי שהבנק המרכזי יהיה עצמאי מהממשלה (קביעת הריבית, פיקוח על הבנקים). **ביטוח לאומי** — כי הוא אינו "תשלום רווחה" אלא ביטוח סוציאלי שמשלמים לו כל החיים. החוק קובע את הקמתם, מבנם, סמכויותיהם ותפקידיהם — ולכן הם גופים ציבוריים לכל דבר. (תאגיד סטטוטורי אינו חייב להיות מתוקצב מהמדינה — רשות שדות התעופה, למשל, אינה מתוקצבת.)

3.3 דואליות נורמטיבית

סוג הגוף	טענות פרטיות	טענות ציבוריות
גוף ציבורי	✓ (למשל בחוזה)	✓
גוף פרטי	✓	✗
גוף דו-מהותי	✓	✓ — **חלק** מהכללים

דואליות נורמטיבית = על הגוף חלים שני סטים של נורמות בבת אחת: פרטיות וציבוריות. כך גם כשרשות ציבורית מתקשרת בחוזה, היא אינה "רק" צד לחוזה — היא כפופה גם לשוויון, להגינות ולסבירות.

3.4 חברות ממשלתיות

חברה ממשלתית — חברה שהמדינה מחזיקה במניותיה. היא נולדה כדרך של הממשלה **לפעול בשוק הפרטי** כשהשוק עצמו לא סיפק צורך (אל-על כחברת תעופה לאומית), או כדי להציל חברה בקריסה. היא כפופה ל**חוק החברות הממשלתיות**, שלפיו עליה לפעול כגוף עסקי, אלא אם הממשלה קבעה אחרת (למשל: הוראה לאל-על שלא לטוס בשבת — החלטת ממשלה; אחרי ההפרטה — החלטה עסקית של הבעלים).

מעמדה: במהותה גוף פרטי (חברה בע"מ, רשומה ברשם החברות) — אבל, כפי שנראה, ברוב המקרים **דו-מהותית**. ההכרעה משתנה מחברה לחברה, לפי אופייה.

3.5 נקודת המוצא — מיקרודף נ' חברת החשמל (בג"ץ 731/86)

⚖ פסק דין — עובדות והכרעה

העובדות: חברת החשמל נזקקה למערכת מחשוב חדשה. ב-1986 עוד לא היה חוק חובת המכרזים (נחקק ב-1992), והיא פנתה ישירות לחברת NCR, שהייתה לה עמה היכרות עסקית. המתחרה — מיקרודף — דרשה **שוויון הזדמנויות**. במשפט הפרטי אין לה טענה כזו; לכן עתרה לבג"ץ וטענה שחברת החשמל היא גוף ציבורי.

השופט ברק: בג"ץ אינו הערכאה המתאימה (אלא בית המשפט המחוזי); אבל גם שם אפשר לטעון נגד חברת החשמל טענות ציבוריות, כי היא "**יצור כלאיים**" — **גוף דו-מהותי**. "לא הצורה הארגונית קובעת את חובות הגוף, אלא **מהות תפקידו**." הסממנים הציבוריים:

1. בבעלות המדינה;
2. מספקת **שירות חיוני**;
3. **מונופול** (כוח שוק דומיננטי);
4. **סמכויות מעין-שלטוניות** (כניסה לחצרות פרטיות לטיפול במונים) וזיכיון בלעדי.

ההלכה: גוף דו-מהותי כפוף ל**עקרונות היסוד** של המשפט המנהלי — הגינות, שוויון, סבירות, יושר ותום לב — גם בפעולותיו העסקיות, אך **לא בהכרח** למכלול כללי המשפט המנהלי. (בסוף ויתרה חברת החשמל על המערכת, והדיון לא הגיע לבירור.)

3.6 חברה קדישא נ' קסטנבאום (ע"א 294/91)

⚖ פסק דין — עובדות והכרעה

העובדות: קסטנבאום ביקש לחרוט על מצבת אשתו את שמה ואת תאריכי הלידה והפטירה **בלועזית**. חברה קדישא סירבה — הוא חתם על טופס שלפיו הכיתוב יהיה בעברית. המחוזי: הטופס הוא חוזה אחיד, והסעיף — **תנאי מקפח**; ביטל אותו. בעליון הערעור נדחה.

שופט	הדרך	המבחן
שמגר	זו שאלה ציבורית: חברה קדישא היא גוף דו-מהותי, וחייבת לכבד את **כבוד האדם** — כולל האוטונומיה להחליט איך להתאבל ולהנציח	שירות מהותי + מונופול
אלון	מסכים עקרונית שהיא דו-מהותית; אבל לדעתו חיוב כיתוב עברי אינו פוגע בכבוד האדם (דעת מיעוט בתוצאה)	עצם השירות החיוני
ברק	המבחן המחמיר: שלושה סממנים — תפקיד חיוני, מונופול, סמכויות מעין-שלטוניות (גביית אגרות קבורה לפי קביעת משרד הדתות). ו**דרך חלופית**: **תחולה** סממנים **עקיפה** של זכויות היסוד דרך **מושגי השסתום** של המשפט הפרטי — תום לב, תקנת הציבור, תנאי מקפח. סעיף הפוגע בכבוד האדם — נוגד את תקנת הציבור; התנהגות מפלה — חוסר תום לב	שלושה סממנים

המשמעות של דרך ברק: (1) עקרון "משקל ראוי לזכויות יסוד" חל **על כולם**, לא רק על גופים דו-מהותיים; (2) אבל טענות ציבוריות "טהורות" — חוסר סבירות, שיקולים זרים — **אינן** חלות על גופים פרטיים.

3.7 שלושה מסלולים שהתפתחו

מסלול	תוכן	דוגמאות
1. הכרה בגופים דו-מהותיים	הרחבת הקטגוריה והחלת כללים ציבוריים	שטרית, אברמוביץ, און, חלמיש
2. תחולה עקיפה של זכויות יסוד	פרשנות מושגי השסתום במשפט הפרטי לאור זכויות היסוד	נעאמנה, פרומר

3. חקיקה	הסדרה ישירה של איסור ההפליה	חוק איסור הפליה במוצרים ובשירותים (2000)

3.8 מסלול 1 — שלוש שאלות על גופים דו-מהותיים

שאלה 1: מי נכנס להגדרה?

- **שטרית נ' קופת חולים מאוחדת (ע"ע 1091/00, בית הדין הארצי לעבודה):** קופת חולים — עמותה פרטית, לא מונופול, בלי סמכויות שלטוניות — היא דו-מהותית בשל **סממן אחד**: היא ממלאת **תפקיד חיוני** של אספקת שירותי בריאות. (ברוח גישת אלון.)
- **אברמוביץ נ' ראש הממשלה והחברה לפיתוח הרובע היהודי:** חברה ממשלתית שהוקמה אחרי 1967 לשיקום הרובע — דו-מהותית בשל **בעלות ממשלתית + תפקיד ציבורי** (לאו דווקא חיוני), אף שאינה מונופול ואין לה סמכויות שלטוניות. (בית המשפט קבע קביעות דומות גם לגבי הסוכנות היהודית והקרן הקיימת.)

✦ הגדרה — המבחנים היום — שני מבחנים חלופיים

(1) האם הגוף מספק **שירות חיוני**; או (2) האם הוא **בבעלות המדינה או רשות מקומית** וממלא **תפקיד ציבורי** חשוב.

שאלה 2: אילו כללים חלים? שלושת המישורים: מהות, פרוצדורה, סמכות.

- **מהות:** מיקרודף וקסטנבאום — שוויון, איסור הפליה, איסור שיקולים זרים, כבוד האדם.
- **פרוצדורה:** בשטרית — ועדת החריגים של קופת החולים היא גוף מעין-שיפוטי, ולכן חייבת לנהל **פרוטוקול**, לתת לחולה **זכות טיעון** ו**זכות עיון** במסמכים, לתת **החלטה מנומקת**, ולפעול בסבירות ובהגינות — גם בהחלטה שלא לכלול שירות בסל.
- **סמכות:** באברמוביץ — תושבי הרובע ביקשו מתנ"ס בבניין ציבורי, והחברה רצתה להוציאו למכרז לעמותות. כל השופטים בחנו גם טענת **חריגה מסמכות** וגם **חוסר סבירות** (הרוב — פרוקצ'יה ועדיאל — דחו; המיעוט — ג'ובראן — קיבל). כלומר: לפי אברמוביץ, אפשר להחיל על גוף דו-מהותי

גם את עקרון הסמכות. (אפשר להעיר שזה מעורר קושי: עקרון הסמכות מניח הסמכה בחוק, ולגוף כזה סמכויות רק מכוח תקנות והחלטות ממשלה — אבל לצורך המבחן, ההלכה היא שאפשר.)

שאלה 3: האם יש גוף "חצי דו-מהותי"? — גוף פרטי שבחלק מפעילותו (קניון) ציבורי, ובחלק אחר (מגדל משרדים) פרטי?

און נ' מפעלי בורסת היהלומים (ע"א 3414/93): הבורסה — חברה פרטית שבבעלות חבריה. שמחה און, שאינו חבר, נהג לבוא כל בוקר לקנות ולמכור. בעקבות סכסוך עם יהלומן בבלגיה, נאסרה כניסתו. המחוזי: בניין פרטי. העליון (השופט **זמיר**): ההבחנה בין קניין פרטי לציבורי אינה חד-משמעית; מקומות כמו אצטדיון, קמפוס או קניון — אף שהם בבעלות פרטית — יש בהם מהות ציבורית. גוף יכול להיות פרטי בתחום אחד ודו-מהותי בתחום אחר. **חמישה שיקולים**:

1. האם יש לו סמכות שלטונית;
2. האם הוא שולט באמצעי חיוני;
3. האם הוא מונופול;
4. האם הוא מקבל תמיכה מרשויות השלטון;
5. האם הוא ממלא תפקיד ציבורי.

התיק הוחזר למחוזי לבירור עובדתי (האם הבורסה דומה לקניון או לבניין משרדים); און נפטר, ולא ניתנה הכרעה סופית — אבל העיקרון נקבע.

מקרים נוספים:

- **גוב נ' בורסת היהלומים:** לבורסה אופי ציבורי, מעין-מונופול, וגביית אגרה — ולכן היא כפופה לעקרונות הדואליים.
- **ימית הביטחון נ' הסוכנות היהודית:** הסוכנות — פטורה ממס, עוסקת בעלייה ובחינוך בתפוצות, מוזכרת בחוקים, ויש לה סמכויות מטעם המדינה — דו-מהותית.
- **שירותי בריאות כללית נ' משרד הביטחון:** לעניין **הטיפול** בחולה — קופת החולים גוף ציבורי ויש להחיל כללים ציבוריים; לעניין **התחשבנות פיננסית** מול משרד הביטחון — גוף פרטי. דוגמה ל"חצי דו-מהותיות".
- **יהודאי נ' חלמיש (ע"א 483/16):** חברה ממשלתית-עירונית לדיור (כמו עמידר) — דו-מהותית, ולכן חלה עליה **חובת הגינות מוגברת**; שיפוץ דירה לשכנה ולא לדיירת — טענת שוויון.

3.9 מסלול 2 — תחולה עקיפה

- **נעאמנה נ' קיבוץ קליה (ת"א 11259/93):** פארק מים בצפון ים המלח התיר כניסה בסופי שבוע רק לבעלי תעודת זהות כחולה (מונע כניסת תושבי השטחים). בית משפט השלום: **הפליה** ופגיעה בשוויון = **חוסר תום לב** בקיום החוזה.
- **פרומר נ' רדגארד (ע"ע 164/99):** תניית אי-תחרות של 22 חודשים בחוזה עבודה. בית הדין לעבודה: סעיף הפוגע באופן לא סביר ולא מידתי ב**חופש העיסוק** — נוגד את **תקנת הציבור**, ובטל.

3.10 מסלול 3 — חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, התשס"א–2000

- המחוקק הבין שהפסיקה יוצרת אי-ודאות, והסדיר חלק גדול מהתחום.
- **"מקום ציבורי"** — כל מקום המיועד לשימוש הציבור: אתר תיירות, מלון, מסעדה, בית קפה, דיסקוטק, מתקן ספורט, קניון, חנות, מוסך. **"שירות ציבורי"** — תחבורה, תקשורת, אנרגיה, חינוך, תרבות, בידור, תיירות ושירותים פיננסיים.
- **סעיף 3:** אסור להפלות במתן מוצר או שירות ציבורי או בכניסה למקום ציבורי.
- אפשר לתבוע **פיצויים ללא הוכחת נזק**; ויש גם היבט פלילי.
- אין צורך לקבוע שהגוף דו-מהותי — החוק חל ישירות.

3.11 מלכודות נפוצות

! שים לב — מלכודות נפוצות

- לחשוב שחברה ממשלתית היא גוף ציבורי לכל דבר — היא במהותה פרטית, ולרוב דו-מהותית.
- לחשוב שעל גוף דו-מהותי חלים כל כללי המשפט המנהלי — "לא בהכרח למכלול".
- לחשוב שצריך את כל ארבעת הסממנים של מיקרודף — היום מספיק אחד משני מבחנים חלופיים.
- לבלבל בין גישת ברק (תחולה עקיפה) לבין גישת שמגר ואלון (דו-מהותיות) בקסטנבאום.
- לשכוח שגוף יכול להיות דו-מהותי רק בחלק מפעילותו (און; כללית).

3.12 שלד לפתרון שאלה — האם הגוף כפוף למשפט המנהלי?

1. **סווגו את הגוף** – רשות מדינה, רשות מקומית, תאגיד סטטוטורי (גוף ציבורי מובהק), חברה ממשלתית, או גוף פרטי.
2. **גוף ציבורי מובהק** – חל עליו המשפט המנהלי במלואו, כל עוד הוא פועל במישור המנהלי (גם הכנסת, כשמנכ"ל מפטר עובד).
3. **גוף פרטי או חצי-פרטי** – שאלו האם הוא דו-מהותי: שירות חיוני; בעלות מדינה או רשות מקומית ותפקיד ציבורי; ובחלק מהפעילות – חמשת שיקולי זמיר (און).
4. **אם דו-מהותי** – חלים עקרונות היסוד (הגינות, שוויון, סבירות, תום לב), ובמקרים מסוימים גם סמכות. נבחנת הפעילות הספציפית.
5. **אם גוף פרטי לגמרי** – אין סבירות מנהלית, אבל אפשר תחולה עקיפה של זכויות יסוד דרך תקנת הציבור ותום הלב, או חוק ההפליה (2000).

3.13 מלכודות בפתרון שאלות — טבלה

הטעות	למה היא שגויה	התיקון
"כל חברה ממשלתית היא גוף ציבורי מלא"	חברה ממשלתית היא לרוב דו-מהותית; הכללים תלויים בתפקיד ובפעילות	לבחון את מהות התפקיד
לדרוש את כל ארבעת הסממנים של מיקרודף	בשטרית נקבע שדי בשירות חיוני כסממן אחד	להזכיר את שני המבחנים החלופיים
להחיל סבירות מנהלית על גוף פרטי	גוף פרטי נבחן במשפט הפרטי; סבירות מנהלית אינה חלה	לנסות תחולה עקיפה (תקנת הציבור, תום לב)
לסווג גוף כציבורי "כולו" או פרטי "כולו"	באון ובכללית נקבעה דו-מהותיות חלקית – לפי הפעילות	לבחון את הפעילות הספציפית
לשכוח את החקיקה	חוק ההפליה (2000) חל על מקומות ושירותים ציבוריים גם בלי קביעת דו-מהותיות	לבדוק חוק ספציפי לפני הלכות

3.14 תרגיל פתור — מרכז קניות פרטי

✎ דוגמה — החרגת קבוצה מקניון

העובדות: חברה פרטית מפעילה קניון גדול, שהוא מרכז החיים של העיר. ההנהלה אסרה על קבוצת צעירים להיכנס לקניון, בלי נימוק ובלי שימוע. הצעירים עותרים לבית המשפט.

הפתרון:

1. **סיווג:** גוף פרטי. אין כאן רשות. אולם יש לבחון אם הוא דו-מהותי בחלק מפעילותו.
2. **שיקולי זמיר (און):** האם יש סמכות שלטונית (לא), אמצעי חיוני (חלקית – מקום ציבורי מרכזי), מונופול (לפי העובדות), תמיכה שלטונית, תפקיד ציבורי. הקניון משמש כ"כיכר העיר" ולכן יש טיעון לדו-מהותיות.
3. **גיבוי חוקי:** חוק איסור הפליה במוצרים ובשירותים ובכניסה למקומות ציבוריים אוסר הפליה במקום ציבורי, ללא צורך בקביעת דו-מהותיות. אם הסיבה לאיסור היא מאפיין מוגן – מסלול זה הקל ביותר.
4. **תחולה עקיפה:** חוסר תום לב או הפרת תקנת הציבור (קסטנבאום, נעאמנה).
5. **מסקנה:** לא תתקבל טענת סבירות מנהלית טהורה נגד גוף פרטי, אך יש שלושה מסלולים חלופיים; יש להתחיל בחוק ההפליה.

3.15 סיכום הפרק

✔ שורה תחתונה — סיכום הפרק

- סעיף 15(ד)(2): הגופים הכפופים כוללים רשויות מדינה, רשויות מקומיות, פקידיהן וגופים הממלאים תפקידים ציבוריים על פי דין.
- תאגיד סטטוטורי (בנק ישראל, ביטוח לאומי) הוא גוף ציבורי; חברה ממשלתית היא לרוב דו-מהותית.
- דואליות נורמטיבית: נורמות פרטיות וציבוריות חלות במקביל על אותו גוף.
- מיקרודף: מהות התפקיד, לא הצורה הארגונית. שטרית: שירות חיוני די. און: דו-מהותיות חלקית, חמישה שיקולים.
- גוף פרטי: תחולה עקיפה (קסטנבאום, נעאמנה, פרומר) או חוק ההפליה (2000).

3.16 מילון מושגים

- **תאגיד סטטוטורי** — גוף בעל אישיות משפטית שהוקם בחוק.
- **חברה ממשלתית** — חברה שהמדינה מחזיקה במניותיה.
- **גוף דו-מהותי** — גוף פרטי שחלים עליו גם עקרונות ציבוריים.
- **דואליות נורמטיבית** — תחולה של נורמות פרטיות וציבוריות במקביל.
- **מושגי שסתום** — מונחים פתוחים במשפט הפרטי (תום לב, תקנת הציבור).
- **תחולה עקיפה** — החלת זכויות יסוד על יחסים פרטיים דרך מושגי השסתום.

3.17 נקודות מפתח למבחן

✔ **שורה תחתונה — עיקרי הפרק**

- ס' 15(ד)(2): רשויות המדינה, רשויות מקומיות, גופים הממלאים תפקיד ציבורי על פי דין.
- מיקרודף: "יצור כלאיים"; מהות התפקיד, לא הצורה; ארבעה סממנים; עקרונות היסוד חלים.
- קסטנבאום: שמגר ואלון — דו-מהותית; ברק — שלושה סממנים + תחולה עקיפה.
- מבחנים היום: שירות חיוני, או בעלות ציבורית + תפקיד ציבורי (שטרית; אברמוביץ).
- אילו כללים: מהות; פרוצדורה (שטרית — ועדת חריגים); סמכות (אברמוביץ).
- און: חמישה שיקולים; דו-מהותיות חלקית.
- תחולה עקיפה: נעאמנה, פרומר; חוק איסור הפליה (2000) — פיצוי בלי הוכחת נזק.

3.18 שאלות בסגנון המבחן

✎ דוגמה — שאלה בסגנון המבחן (1)

עמותה פרטית מפעילה את בית החולים היחיד באזור. ועדה של העמותה דחתה בקשה של מטופל לטיפול חריג, בלי לשמוע אותו ובלי לנמק. איזו קביעה **נכונה**?

א. מדובר בגוף פרטי, ולכן אפשר לטעון רק טענות חוזיות. ב. העמותה עשויה להיחשב גוף דו-מהותי בשל השירות החיוני, ואז עשויים לחול עליה גם כללים פרוצדורליים כמו זכות טיעון והנמקה. ג. על גוף דו-מהותי חלים רק כללים מהותיים, לעולם לא פרוצדורליים. ד. העמותה גוף ציבורי לכל דבר, כי היא ממלאת תפקיד.

התשובה וההסבר

ב. לפי שטרית, די בשירות חיוני כדי להכיר בגוף כדו-מהותי, ובית הדין החיל עליו גם זכות טיעון, עיון והנמקה. ג' שגויה לאור שטרית. ד' מגזימה — גוף דו-מהותי אינו "ציבורי לכל דבר".

✎ דוגמה — שאלה בסגנון המבחן (2)

מסעדה פרטית סירבה להכניס לקוח בשל מוצאו. מהי הדרך הישירה ביותר לתבוע?

א. עתירה לבג"ץ בטענת חוסר סבירות. ב. תביעה לפי חוק איסור הפליה במוצרים ובשירותים — אפשר לקבל פיצוי בלי להוכיח נזק. ג. אין עילה, כי המסעדה פרטית. ד. עתירה מנהלית בטענת שיקולים זרים.

התשובה וההסבר

ב. המסלול השלישי — החוק חל ישירות על "מקום ציבורי", כולל מסעדה. א' ו-ד' — טענות ציבוריות שאינן חלות על גוף פרטי. ג' שגויה.

3.19 שאלות לחשיבה

1. מה היתרון של "תחולה עקיפה" על פני הרחבת הקטגוריה הדו-מהותית?

תשובה אפשרית: היא שומרת על ההבחנה בין פרטי לציבורי — הגוף הפרטי לא נחשף לכל ארגז הכלים המנהלי (סבירות, שיקולים זרים), אבל עדיין חייב לכבד זכויות יסוד. מנגד, היא תלויה בפרשנות של בית המשפט ופחות צפויה.

2. האם הקניון של היום הוא "הכיכר העירונית" של פעם?

תשובה אפשרית: הרבה מהמרחב הציבורי עבר לידיים פרטיות — קניונים, אצטדיונים, רשתות. הלכת און וחוק איסור ההפליה מבטאים את ההכרה בכך שמקום פרטי שפתוח לציבור נושא אחריות ציבורית, לפחות בתחום השוויון והכניסה.

פרק 4

פרשנות החוק המסמיך וכלל ההסדרים הראשוניים

4.1 מבוא — למה זה חשוב ומה מקומו בתמונה הגדולה

עקרון החוקיות קובע שהרשות זקוקה להסמכה בחוק. אבל הסמכה לעולם אינה מפורטת עד הסוף, ולכן השאלה האמיתית בכל תיק היא **פרשנית**: האם סעיף החוק הזה מסמיך את הרשות לעשות **את הפעולה הזאת**? בפרק נלמד את כללי הפרשנות הקבועים בחוק הפרשנות, ואת שני כללי הפרשנות המרכזיים שקבעה הפסיקה: (1) **ככל שהפגיעה בזכויות חמורה יותר — נדרשת הסמכה מפורשת יותר**; (2) **הסדרים ראשוניים** צריכים להיקבע בחקיקה ראשית. נראה איך שני הכללים "מתלכדים" לכלל אחד, ונעסוק בשאלה הפתוחה — האם הכלל השני הוא פרשני בלבד, או חוקתי.

4.2 מקור הסמכות — רק בחקיקה ראשית

מקור הסמכות הוא **תמיד בחקיקה ראשית** — לא בתקנות, לא בהחלטת ממשלה ולא בהנחיה פנימית. הסיבה: אילו שר יכול היה להתקין תקנות שמקנות לו סמכויות, הוא היה קובע לעצמו מה מותר לו — בניגוד להפרדת הרשויות. המחוקקת מסמיכה; המבצעת מבצעת.

דוגמה לסעיף מסמיך — סעיף 82 לחוק הטיס, התשע"א–2011: מנהל רשות התעופה האזרחית "אחראי לתכנון ולפיתוח של מרחב הפיקוח התעופתי... ולמתן הוראות לעניין השימושים במרחב האמור, **בין השאר** בעניינים המפורטים להלן" — ואחריו תשעה תחומים (אזורי המרחב, נתיבי טיסה, גישה לשדות, תנועה קרקעית, אזורים אסורים ועוד), "והכל במטרה להבטיח את בטיחות התעבורה האווירית, סדירותה ויעילותה, ובמטרה להגן על שלום הציבור והסביבה". **שאלה פרשנית:** האם המנהל רשאי לתת הוראות בנושא שאינו ברשימה? — "בין השאר" מלמד שהרשימה פתוחה; כל עוד ההוראה נוגעת לשימושים במרחב האווירי האזרחי ולתכליות שבסיפא — היא בסמכותו.

4.3 חוק הפרשנות, התשמ"א–1981 — פרק ג': פירוש הסמכות

סעיף	הכלל	דוגמה / משמעות
11	הסמכה או חובה **בלי קביעת זמן** — לעשות "**במהירות הראויה**" ולחזור ולעשות "ככל הנדרש"	אם המנהל לא קבע כללים שלושה חודשים — סביר; עשר שנים — אפשר לעתור ולדרוש
12	הסמכה ליתן פטור או הקלה — כוללת לתת אותם **במקצת או בתנאים**	
13	מינוי בשם האדם או בשם המשרה; מינוי בשם המשרה — חל על מי שממלא אותה מזמן לזמן	
14	הסמכה **למנות** — כוללת להתלות, לבטל, לפטר ולהשעות	
15	הסמכה להתקין תקנות או ליתן הוראת מינהל — כוללת לתקן, לשנות, להתלות ולבטל — **בדרך שבה הותקנו**	אם מינוי היועמ"ש נעשה אחרי ועדת איתור — גם פיטוריו מחייבים אותו הליך (פרק 8)
16	הסמכה למנות גוף — כוללת למנות יו"ר וממלאי מקום	
17(א)	הסמכה לעשות או להכריע — כוללת לקבוע **נוהל עבודה וסדרי דיון**	
17(ב)	הסמכה לעשות דבר — כוללת **"סמכויות עזר** הדרושות לכך במידה המתקבלת על הדעת"	הפעלת נמל תעופה כוללת שכירת עובדים ויועצים — חריג לחוקיות המנהל (פרק 5)
18	סמכות בערר — לאשר, לשנות, לבטל, להחליט אחרת או להחזיר	
19	סמכות לפי חיקוק אחד אינה גורעת מסמכות לפי חיקוק אחר	ריבוי מקורות סמכות (פרק 5)
20	פעולה שהוטלה על מספר בני אדם — כשרה אם נעשתה בידי **רובם**	

4.4 כלל פרשנות מס' 1 — עוצמת הפגיעה קובעת את רמת ההסמכה

העמותה למען החתול נ' עירייית ערד (בג"ץ 6446/96): העירייה פיזרה רעל לחיסול חתולי רחוב, בלי התפרצות כלבת. האם היא מוסמכת?

- ס' 247(א) לפקודת העיריות — השמדת **כלבי** רחוב: לא חתולים.
- ס' 242(10) — השמדת עכברושים, עכברים "ושאר שרצים": לא חתולים.
- ס' 247(ב) — הסדרת החזקת חזירים ובעלי חיים: לא השמדה.
- ס' 242(1) — "תנקוט אמצעים להסרת כל **מטרד** או למניעתו" — **מכוח סעיף זה** יש לעירייה סמכות.

התוצאה: יש סמכות להשמיד חתולי רחוב — **פרשנות רחבה**; אבל לא באמצעות רעל (העתירה התקבלה בחלקה).

קטלן נ' שירות בתי הסוהר (בג"ץ 355/79): בשנות ה-70, בגלל סמים בבתי הכלא, הוחלט לבצע **חוקן** בכל אסיר שחוזר מבית משפט, מטיפול או מחופשה. מקורות הסמכה לכאורה: ס' 5 לפקודת בתי הסוהר ("בשעת קבלת אסיר ייערך **בו** חיפוש"), וסעיפים בפקודת סדר הדין הפלילי (חיפוש "בכליו או בגופו"). בית המשפט: אין די בכך — נדרשת **הסמכה חד-משמעית ומפורשת**; אי אפשר לפגוע בזכויות אדם מכוח סמכות כללית. (בעקבות זאת חוקק **חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה — חיפוש בגוף החשוד), התשנ"ו–1996**, עם הסדר מפורט: הסכמה, הסבר, אישור רופא, היתר בית משפט.)

למה ההבדל בין שני פסקי הדין? בחתול — אין פגיעה בזכויות יסוד של אדם, ולכן פרשנות רחבה. בקטלן — פגיעה חמורה בגופו ובכבודו של אדם, ולכן פרשנות דווקנית.

מאנע נ' רשות המסים (בג"ץ 6824/07): פקודת המסים (גבייה) מסמיכה את גובה המס "להיכנס לחצריו של הסרבן... ולעקלם". בתקופת האינתיפאדה הצטרפו פקידי המס למחסומי משטרה בירושלים, בדקו נהגים ו**עיקלו רכבים במחסום**. ד"ר מאנע, מרצה לחשבונאות, נעצר בטענה לחוב (שהתברר שאינו קיים), ונדרש לשלם במזומן או לאבד את רכבו. בג"ץ: הסמכות "להיכנס לחצר" אינה מסמיכה עמידה במחסומים, בדיקת תעודות ועיקול בכביש.

§ סעיף — ציטוט / הסעיף

"כשפעולתה של הרשות עלולה להביא לפגיעה בזכות יסוד מוכרת, מקבלת ההקפדה על עיקרון [חוקיות המנהל] משנה חשיבות... אין הרשות יוצאת ידי חובתה בהצבעה על הוראת חוק כללית שיכולה להתפרש כמקור הסמכה לפעולתה... על ההסמכה לפעולה להיות **ברורה, מפורטת ומפורשת** בחקיקה ראשית." (בהסתמך על הוועד הציבורי נגד עינויים, בג"ץ 5100/94)

יישומים נוספים:

- **פלונית נ' קצין התגמולים — משרד הביטחון:** אי אפשר להסתמך על הסמכה כללית בחוק הנכים כדי לבצע **מעקבים וחקירות** אחר תובעי גמלה — מדובר בפגיעה בפרטיות, ולכן נדרשת הסמכה מפורטת יותר.
- **גת נ' המשרד לביטחון פנים:** מגבלות על ירי במטווח — פגיעה **מינורית** יחסית, ולכן די בהסמכה כללית.
- **מפקד כוחות צה"ל ביהודה ושומרון נ' עליאן:** החזקת גופות מחבלים לצורכי משא ומתן — הרוב: יש לכך הסמכה בתקנות ההגנה (שעת חירום); המיעוט: פגיעה כזו מחייבת **חקיקה מפורשת**, לא פרשנות.

✦ הגדרה — כלל פרשנות מס' 1

ככל שהסמכות המבוקשת פוגעת יותר בזכויות יסוד — הפרשנות דווקנית, ונדרשת הסמכה **ברורה, מפורטת ומפורשת**. ככל שאינה פוגעת בזכויות יסוד — הפרשנות רחבה, ודי בהסמכה כללית.

4.5 כלל פרשנות מס' 2 — הסדרים ראשוניים בחקיקה ראשית

שלוש דרכים להסמיך (על דוגמת רישוי טייסים):

סוג ההסמכה	דוגמה	שיקול הדעת שנותר
רחבה וכללית	"ראש מינהל התעופה יקבע את הכללים בנוגע לרישוי והפעלה של כלי טיס"	כמעט בלתי מוגבל
עם הסדרים ראשוניים	"לא יפעיל אדם כלי טיס אלא ברישיון. לשם כך: מעל גיל 21; מינימום שעות טיסה *כפי שיקבע* הראש; מבחן עיוני ומעשי *בנושאים שיקבע*; בדיקות בריאות *שיקבע בהתייעצות* עם מנכ"ל משרד הבריאות"	משמעותי, אבל מתוחם במסגרת
עם הסדרים ראשוניים ומשניים	כנ"ל, אבל עם 50 שעות, נושאי המבחן ותחומי הבדיקות — במפורש בעיקר ביצוע	

הכלל: החוק צריך לקבוע **לפחות** את ההסדרים הראשוניים — המדיניות הכללית ואמות המידה העקרוניות. את הפירוט המשני אפשר להשאיר לתקנות ולהוראות מנהל.

★ טיפ למבחן — מה לעשות במבחן

כשהמחוקק "מרבה במלל" — אם המלל **מגביל** או קובע קטגוריות, יש הסדרים ראשוניים; אם המלל רק **מרחיב** את הסמכות — זו עדיין הסמכה כללית.

בפועל, המחוקק הישראלי הרבה להסמיך בהסמכות רחבות:

- **תקנות שעת חירום** — ס' 39 לחוק יסוד: הממשלה: במצב חירום הממשלה רשאית להתקין תקנות "כדי להגן על המדינה, ביטחון הציבור וקיום האספקה והשירותים החיוניים", ו**כוחן יפה לשנות כל חוק**. הסמכה רחבה מאוד; בית המשפט יפרש בצמצום את תכליותיה. (בתחילת הקורונה הוטלו כך בידודים והגבלות; אחר כך חוקק חוק ייעודי.)
- **חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי"ח–1957** — מנגנון של שלושה שלבים: (1) הממשלה מסמיכה שר; (2) השר מכריז על מצרך או שירות כ"בר-פיקוח"; (3) השר קובע בצו כמעט כל דבר — ייצור, הובלה, מכירה, מחיר, צריכה — "לאסרו, להגבילו, להטיל עליו פיקוח... להתנות בתנאים, לרבות רישיון".

4.6 שנסי נ' המפקח על היהלומים (בג"ץ 2740/96)

⚖ פסק דין — עובדות והכרעה

הרקע: מכוח חוק הפיקוח הוכרזו היהלומים כמצרך בר-פיקוח, ונקבע בצו (1979) שאיש לא יעסוק ביהלומים — ייצור, מסחר, יבוא, יצוא, החזקה — אלא ברישיון של "המפקח על היהלומים". עזיז שנסי, שהורשע ברצח מתחרה עסקי ושוחרר בחנינה אחרי חלק קטן מעונשו, ביקש רישיון; המפקח סירב.

השופט חשין:

- "מבט מרפרף... ילמדנו כי המחוקק אמר להפקיד בידיהם של שרי הממשלה סמכויות **כול-כוללות**... וידעת כי שרים המחזיקים בסמכות על פי החוק הינם (כמעט) **כול-יכולים** בשררה על חיי המשק והכלכלה."
- "הענקת סמכויות זו **טופחת בחוזקה על פניו של עקרון שלטון החוק**. עקרון שלטון החוק במובנו המהותי מורנו, כי 'הסדרים ראשוניים' חייבים למצוא את מקומם בחוק הכנסת, וכי תקנות לא נועדו, בעיקרן, אלא לביצועם של חוקים... הופכות את הממשלה — למעשה אם לא להלכה — לרשות מחוקקת ראשה בנושאי כלכלה ומשק."
- ובכל זאת — **לא הכריע** אם הצו בטל: העותר לא תקף את חוקיות הצו, והמדינה לא הגיבה לכך; וממילא — אדם שהורשע ברצח ושוחרר כעבור זמן קצר, "לא נתקשה לסרב לו". העתירה נדחתה.

השאלה שנותרה: האם הכלל **חוקתי** (חוק שמסמיך באופן כללי — בטל; כך במדינות עם חוקה: "האיסור על האצלת סמכויות חקיקה") או **פרשני** (החוק תקף, אבל מפרשים אותו בצמצום)?

4.7 רובינשטיין נ' שר הביטחון (בג"ץ 3267/97)

⚖ פסק דין — עובדות והכרעה

הרקע: מאז קום המדינה דחה שר הביטחון את שירותם של בחורי ישיבות שתורתם אומנותם — 400 בימי בן-גוריון, ובהמשך עשרות אלפים. עתירות קודמות: **בקר** (1970, כ-5,000) ו**רסלר** (1981, כ-11,500) — נדחו בהיעדר זכות עמידה; **רסלר** (1986, כ-17,000) — הורחבה זכות העמידה לעותר ציבורי, אך העתירה נדחתה לגופה. ב-1997 עתר ח"כ אמנון רובינשטיין.

החוק המסמיך — ס' 36 לחוק שירות ביטחון: השר רשאי לפטור "מטעמים הקשורים בהיקף הכוחות... או מטעמים הקשורים בצרכי החינוך, ההתיישבות הביטחונית או המשק הלאומי, או מטעמי משפחה **או מטעמים אחרים**". הטענה: "או מטעמים אחרים" מרוקן את ההסדר מתוכן.

הנשיא ברק:

- **(פס' 19)** "כלל בסיסי של המשפט הציבורי בישראל קובע, כי מקום שפעולת שלטון מעוגנת בתקנה או בהוראת מינהל, מן הראוי הוא כי המדיניות הכללית ואמות המידה העקרוניות... יעוגנו בחקיקה ראשית... '**הסדרים ראשוניים**'... צריכים להיקבע בחוק של הכנסת, ואילו התקנות או הוראות המינהל צריכות לקבוע אך '**הסדרים משניים**'."
- **(פס' 24) רמת ההפשטה משתנה:** "ככל שהפגיעה בחירותו של הפרט גדולה יותר, כן אין להסתפק ברמת הפשטה גבוהה מדי... כאשר אובייקט ההסדר הוא נושא מורכב, הדורש **מומחיות** רבה, ניתן לא פעם להסתפק ברמת הפשטה גבוהה." (למשל: הגדרת "זיהום אוויר" — אפשר להשאיר לשר.)
- **(פס' 27–28) מעמד הכלל:** עד חוקי היסוד — **כלל פרשנות**: "חזקה פרשנית היא כי הסמכת המינהל לחקיקת משנה או להוראות מינהל, היא הסמכה לקביעתם של הסדרים משניים בלבד."
- **(פס' 31)** חוקי היסוד על זכויות האדם **מחזקים** את החזקה הפרשנית; על מלוא השינוי — "צריך עיון" (החוק בעניינו קדם לחוקי היסוד, ונהנה משמירת דינים).
- **(פס' 40–41) היישום:** סמכות השר תופעל "בעקבות ההכרעות החברתיות הקשות שיתקבלו אצל המחוקק"; השר "אינו רשאי ליטול לעצמו סמכות הכרעה זו". "טעמים אחרים" — אפשר לפטור רק מספר **מצומצם** של מקרים; כשהעניין הופך ל"**בעיה לאומית**" (כ-29,000 פטורים) — נדרש הסדר בחקיקה ראשית.

השופט חשין (אמרת אגב): הבעיה אינה ה**כמות** אלא ה**פגיעה בשוויון** — כבר ברסלר, עם 17,000, היה צריך לפסול.

התוצאה: לכנסת לקח כחמש שנים לחוקק את "**חוק טל**" — ומאז הפכה הסוגיה לחוקתית (עתירות על חוקתיות החוק).

4.8 התלכדות שני הכללים — ועדת המעקב העליונה (בג"ץ 11163/03)

הממשלה קבעה **אזורי עדיפות לאומית** בחינוך — 535 יישובים זכו להטבות, מהם רק 4 יישובים ערביים קטנים — מכוח **ס' 32 לחוק יסוד: הממשלה** (הסמכות השיורית: "הממשלה מוסמכת לעשות בשם המדינה... כל פעולה שעשייתה אינה מוטלת בדין על רשות אחרת"). בג"ץ: **הפליה אסורה**, והעתירה התקבלה. ובנוסף, הנשיא **ברק**: קביעת אזורי עדיפות היא **הסדר ראשוני**, שבסמכות הכנסת בלבד; ס' 32 אינו מסמיך לכך. **מבחנים** להסדר ראשוני: היקף ההשפעה על הציבור, מידת המחלוקת הציבורית, המשמעות הכספית — ומנגד: מעורבות הכנסת, דחיפות, הסתמכות הציבור. (ס' 32 לא בוטל — פורש בצמצום, ככלל פרשני.)

✦ הגדרה — הכלל המאוחד

ככל שהסמכות המבוקשת פוגעת יותר בזכויות יסוד, **או** מבקשת להסדיר נושא בעל משמעות חברתית גדולה ("בעיה לאומית") — הפרשנות דווקנית, וההסמכה צריכה להיות ברורה, מפורטת ומפורשת ולכלול הסדרים ראשוניים. ככל שאינה כזו — די בהסמכה כללית.

4.9 חוקתי או פרשני? — השאלה הפתוחה

פסק הדין	העובדות	העמדה

התאחדות הסטודנטים וחדו"ש נ' הממשלה (בג"ץ 616/11)	מלגות לאברכי כולל נקבעו בשורה בחוק התקציב ("מלגת לימוד... 100 מיליון ₪ בשנה"), והקריטריונים — בהחלטת ממשלה	השופט **רובינשטיין**: הסדר ראשוני חסר — נוגד את חובת השוויון, והסעיף **בטל**: יש לראות בכלל **כלל חוקתי** (פגיעה בזכות רק "בחוק או לפי חוק... מכוח הסמכה מפורשת בו")
המרכז האקדמי למשפט ועסקים נ' ממשלת ישראל (בג"ץ 4491/13)	מדיניות יצוא הגז הטבעי (בעקבות ועדת צמח), מכוח סעיף כללי בחוק הנפט	**הרוב** (גרוניס ואחרים): אף שזה הסדר ראשוני — החזקה **ניתנת לסתירה**; כשאין פגיעה ממשית בזכויות, די ב**הסמכה משתמעת**. המעמד — **"צריך עיון"**; עמדת רובינשטיין אינה מחייבת. **המיעוט** (ג'ובראן): יש להתמקד בחשיבות ההחלטה, ולא רק בפגיעה בזכויות
בן מאיר נ' ראש הממשלה (בג"ץ 2109/20)	איכון טלפונים בידי השב"כ בתחילת הקורונה, מכוח הסמכה כללית בחוק השב"כ	בשעת **דחיפות** — אפשר כהסדר זמני מכוח הסמכה כללית; כשהדחיפות חולפת — זה **הסדר ראשוני** שחייב להיקבע בחוק

4.10 מלכודות נפוצות

! שים לב — מלכודות נפוצות

- לחשוב שתקנות או החלטות ממשלה יכולות להקנות סמכות — רק חקיקה ראשית.
- לחשוב שהסמכה כללית תמיד פסולה — היא מספיקה כשאין פגיעה בזכויות או בעיה לאומית.
- לחשוב שברובינשטיין בוטל סעיף 36 — הוא פורש בצמצום.
- לחשוב שהשאלה "חוקתי או פרשני" הוכרעה — היא ב"צריך עיון".
- לשכוח שבנושא מקצועי-מורכב אפשר להסתפק ברמת הפשטה גבוהה.

4.11 שלד לפתרון שאלה — פרשנות הסמכה

1. **מצאו את לשון ההסמכה** – האם היא מפורשת ומפורטת, או כללית ("רשאי לקבוע תקנות", "כל אמצעי נדרש")?
2. **הערכו את עוצמת הפגיעה בזכויות יסוד** – ככל שהפגיעה חמורה יותר (גוף, חירות, פרטיות, קניין, עיסוק) נדרשת הסמכה ברורה, מפורטת ומפורשת (כלל פרשנות 1: קטלן, מאנע).
3. **הערכו את משמעות הנושא** – האם מדובר בהסדר ראשוני: מדיניות כללית ואמות מידה עקרוניות בנושא בעל חשיבות חברתית? אם כן – הוא צריך להיקבע בחקיקה ראשית (כלל פרשנות 2: רובינשטיין, ועדת המעקב).
4. **בדקו סמכויות עזר** – האם הפעולה נדרשת במידה המתקבלת על הדעת כדי לממש את ההסמכה (ס' 17(ב) לחוק הפרשנות)?
5. **הסיקו** – פרשנות מצמצמת (בטלות או היעדר סמכות) או פרשנות מרחיבה (החתול), ונמקו לפי שני הכללים.

4.12 מלכודות בפתרון שאלות — טבלה

הטעות	למה היא שגויה	התיקון
לחשוב שהסמכה כללית מספיקה לכל פעולה	כשהפגיעה בזכות חמורה נדרשת הסמכה מפורשת (קטלן, מאנע)	לדרוש רמת פירוט יחסית לפגיעה
לפרש תמיד בצמצום	בעניין החתול אין פגיעה בזכויות אדם ולכן פרשנות רחבה	להבחין לפי עוצמת הפגיעה
לראות בהסדרים ראשוניים כלל חוקתי מוחלט	ברק ראה בו כלל פרשני; מעמדו נותר "צריך עיון" (יצוא גז)	לציין את המחלוקת
לחשוב שתקנות יכולות להסמיך להתעלם מתקנות שעת חירום	הסמכה מקורה בחקיקה ראשית; תקנות כפופות לה כוחן יפה לשנות חוק, אך יפורשו בצמצום ובדחיפות בלבד	לחפש את החוק המסמיך לבחון דחיפות ותקופה

4.13 תרגיל פתור — תקנה שמסמיכה חיפוש בגוף

✎ דוגמה — חוקן בכלא

העובדות: חוק שירות בתי הסוהר מסמיך את השב"ס "לערוך חיפוש בגופו של אסיר". שב"ס הורה להפעיל חוקן על אסירים שחזרו מחופשה, בחשד להברחת סמים. אסיר עתר.

הפתרון:

1. **פגיעה:** חוקן פוגע בכבוד האדם, בפרטיות ובשלמות הגוף – פגיעה חמורה.
2. **כלל פרשנות 1:** ככל שהפגיעה חמורה יותר נדרשת הסמכה ברורה, מפורטת ומפורשת. "חיפוש בגופו" הוא ניסוח כללי שאינו מכוון לבדיקה פולשנית.
3. **הלכה:** קטלן – הסמכה כללית אינה מספיקה לפגיעה כזו.
4. **מסקנה:** היעדר סמכות; פעולת השב"ס בטלה. הפתרון המתאים הוא חקיקה מפורשת, וכך אכן נעשה בחוק חיפוש בגוף החשוד.

4.14 סיכום הפרק

✔ **שורה תחתונה — סיכום הפרק**

- מקור הסמכות הוא בחקיקה ראשית; תקנות כפופות לה. חוק הפרשנות מסדיר סוגיות כמו מועד הפעלה (ס' 11), ביטול תקנה (ס' 15), סמכויות עזר (ס' 17(ב)) ופעולה במספר אנשים (ס' 20).
- כלל פרשנות 1: ככל שהפגיעה בזכויות חמורה יותר – נדרשת הסמכה מפורשת (קטלן, מאנע, פלונית) ולהפך – החתול.
- כלל פרשנות 2: הסדרים ראשוניים בחקיקה ראשית (שנסי, רובינשטיין, ועדת המעקב).
- הכלל המאוחד: פגיעה בזכויות או נושא בעל משמעות חברתית גדולה מחייבים הסמכה מפורשת ופירוט.
- מעמד הכלל: פרשני (ברק) או חוקתי (רובינשטיין, 616/11); נותר "צריך עיון" (יצוא גז). בחירום – תקנות שעת חירום יפורשו בצמצום.

4.15 מילון מושגים

- **חוק מסמיך** — החוק שממנו שואבת הרשות את סמכותה.
- **הסדר ראשוני** — המדיניות הכללית ואמות המידה העקרוניות.
- **הסדר משני** — הפירוט והביצוע.
- **הסמכה משתמעת** — הסמכה שנלמדת מהקשר החוק, לא מלשון מפורשת.
- **"בעיה לאומית"** — נושא בעל משמעות חברתית רחבה שדורש הכרעת מחוקק.
- **שמירת דינים** — חוק שקדם לחוק יסוד אינו נפגע ממנו.

4.16 נקודות מפתח למבחן

✔ שורה תחתונה — עיקרי הפרק

- מקור הסמכות — רק חקיקה ראשית; חוק הפרשנות ס' 11–20.
- כלל 1: חתול (רחב — אין פגיעה בזכויות) מול קטלן ומאנע (מפורש — פגיעה בזכויות); פלונית נ' קצין התגמולים; עליאן.
- כלל 2: הסדרים ראשוניים בחקיקה ראשית; שלוש רמות הסמכה; תקנות שעת חירום; חוק הפיקוח.
- שנסי: "טופחת על פניו של שלטון החוק" — אך ללא הכרעה.
- רובינשטיין: כלל פרשני; רמת ההפשטה לפי הפגיעה והמומחיות; "בעיה לאומית"; חשין — שוויון.
- ועדת המעקב: ס' 32 אינו מסמיך להסדר ראשוני; התלכדות הכללים.
- חוקתי או פרשני: רובינשטיין ב-616/11 (חוקתי) מול 4491/13 (צריך עיון; הסמכה משתמעת כשאין פגיעה); איכוני שב"כ.

4.17 שאלות בסגנון המבחן

✎ דוגמה — שאלה בסגנון המבחן (1)

חוק מסמיך את מנהל רשות הספורט "לקבוע כללים בנוגע לפעילות ספורט מאורגנת". המנהל קבע בכללים חובת בדיקה גנטית לכל ספורטאי. מה הטענה החזקה ביותר?

א. אין טענה — ההסמכה רחבה מספיק. ב. הבדיקה פוגעת בפרטיות ובאוטונומיה, ולכן נדרשת הסמכה ברורה, מפורטת ומפורשת — ההסמכה הכללית אינה מספיקה. ג. הכללים בטלים כי לא פורסמו. ד. רק הכנסת רשאית לעסוק בספורט.

התשובה וההסבר

ב. כלל פרשנות מס' 1: ככל שהפגיעה בזכויות חמורה יותר, נדרשת הסמכה מפורשת (קטלן, מאנע). ג' אינה עולה מהעובדות. ד' מגזימה.

✎ דוגמה — שאלה בסגנון המבחן (2)

בהתאם להלכת רובינשטיין, מה מעמדו של הכלל בדבר הסדרים ראשוניים לגבי חוק שנחקק לפני חוקי היסוד?

א. כלל חוקתי — חוק שאינו כולל הסדרים ראשוניים בטל. ב. כלל פרשני — החוק תקף, אבל מפרשים את ההסמכה כהסמכה להסדרים משניים בלבד. ג. אין כלל כזה. ד. הכלל חל רק על תקנות שעת חירום.

התשובה וההסבר

ב. ברק בפס' 27–28. לגבי חוקים שאחרי חוקי היסוד — השאלה נשארה ב"צריך עיון" (ונדונה ב-616/11 וב-4491/13).

4.18 שאלות לחשיבה

1. למה ברובינשטיין ברק בחר בפרשנות מצמצמת ולא בביטול?

תשובה אפשרית: החוק קדם לחוקי היסוד ונהנה משמירת דינים; פרשנות מצמצמת משיגה את המטרה — מחזירה את ההכרעה למחוקק — בלי ביטול חוק, ומיישבת את המתח עם פסיקת רסלר הקודמת (מספר מצומצם — מותר; בעיה לאומית — לא).

2. מה ההבדל בין עמדת ברק לעמדת חשין ברובינשטיין?

תשובה אפשרית: ברק — הבעיה היא ההיקף ("בעיה לאומית"); חשין — הבעיה היא הפגיעה בשוויון, גם ב-17,000. לפי ברק העניין מוסדי (מי מחליט); לפי חשין — מהותי (זכויות).

פרק 5

מקורות הסמכות — סמכות שיורית, סמכות עזר, סמכות טבועה וסיווג סמכויות

5.1 מבוא — למה זה חשוב ומה מקומו בתמונה הגדולה

בפרק הקודם ראינו שמקור הסמכות הוא החקיקה הראשית הספציפית. אבל מה קורה כשהיועץ המשפטי בודק את החוק הרלוונטי ולא מוצא בו סמכות לפעולה המבוקשת? לא תמיד המסקנה היא "אסור". יש שני מקורות סמכות **כלליים, משלימים**: **הסמכות השיורית** של הממשלה (ס' 32 לחוק יסוד: הממשלה) ו**סמכויות העזר** (ס' 17(ב) לחוק הפרשנות) — ולצדם רעיון ה**סמכות הטבועה**. נלמד מתי אפשר להישען עליהם ומה גבולותיהם; מה עושים כש**יש כמה מקורות סמכות** לאותה פעולה; איך **מסווגים** סמכויות (חקיקה, ביצוע, מעין-שפיטה; חובה ורשות) ולמה הסיווג חשוב; ומדוע **פעולה בניגוד לחוק היא חריגה מסמכות**.

5.2 הסמכות השיורית של הממשלה

ההיסטוריה: עד 1968 — "**הפרוגטיבה** של השלטון", סמכויות ממשל "טבועות" שירשנו מהמשפט האנגלי: בנושא שלא הוסדר בשום מקום, הממשלה מוסמכת לטפל. ב-1968, בחקיקת חוק יסוד: הממשלה, התלבטה הכנסת: מצד אחד, סעיף כזה סותר את רוח עקרון החוקיות — ממשלה שמוסמכת "לכל דבר" אינה צריכה לחוקק ולהגביל את עצמה; מצד שני — עדיף שהסמכות תהיה מעוגנת בחוק, כדי להציל את שלטון החוק לפחות ברמה הפורמלית. הוחלט לעגן.

§ סעיף — 32 לחוק יסוד: הממשלה

(בעבר ס' 29, ואחר כך ס' 40): "הממשלה מוסמכת לעשות בשם המדינה, **בכפוף לכל דין**, כל פעולה **שעשייתה אינה מוטלת בדין על רשות אחרת**."

שני סייגים:

1. **"בכפוף לכל דין"** — אסור להפר חוקים.
2. **"שעשייתה אינה מוטלת בדין על רשות אחרת"** — אם רשות אחרת הוסמכה, הממשלה אינה רשאית. דוגמה: את הריבית קובע נגיד בנק ישראל לפי חוק בנק ישראל; גם אם הממשלה ושר האוצר אינם מרוצים — הם אינם רשאים להוריד את הריבית מכוח ס' 32.

5.3 עיריית קריית גת נ' מדינת ישראל (בג"ץ 2918/93)

⚖ פסק דין — עובדות והכרעה

הרקע: במשך שנים קבעו הממשלות הטבות לערי פיתוח ואזורי קו עימות מכוח הסמכות השיורית (הנחות במס, הטבות בחינוך). ב-1988 נחקק **חוק ערי ואזורי פיתוח**: ועדת שרים קובעת אילו ערים הן ערי פיתוח, והחוק קובע את ההטבות (חינוך חינם, הלוואות דיור עד 95%, מלגות) — אבל גם קובע שעיר שתקבל את ההטבות לפי החוק **תאבד את הטבות המס**. אף עיר לא רצתה את המעמד; החוק לא הופעל, והממשלות המשיכו לתת הטבות בשיטה הישנה. ב-1993 שינתה הממשלה את המפה, וקריית גת ואריאל הוצאו ממנה — ועתרו: יש חוק, ולממשלה אין סמכות להחליט במסלול אחר.

השופט גולדברג:

- הסמכות רחבה ביותר ("חובקת עולם ומלואו") — אך מוגבלת בשני הסייגים.
- "הסייג... 'בכפוף לכל דין', אינו מורה רק כי אסור למעשי הממשלה כי יסתרו כל דין... אלא גם זאת כי **משקיים דין אשר יוצר הסדר, נסוגה מפניו סמכות הממשלה**, ואין בידה ליצור הסדר אלטרנטיבי. אם היה חלל ריק משפטי — הוא התמלא בחוק."
- "מסלול מקביל" לחוק "מטשטש את הגבולות בין הרשות המבצעת ובין הרשות המחוקקת" — יש לפרש את הסעיף **בצמצום**, ולהפעילו רק ב**ריק משפטי**.

- עם זאת — כיוון שהחוק **לא יושם בפועל**, הממשלה יכולה הייתה להפעיל את סמכותה השיורית כל עוד רשות אחרת לא פעלה.

השופטת דורנר: "דין" בסעיף כולל לא רק חקיקה אלא גם **הלכה פסוקה** — ובפרט ההלכות על **זכויות הפרט**. לכן הסמכות השיורית אינה מאפשרת לפגוע בזכויות יסוד.

ההלכה: הסמכות השיורית **נסוגה** מפני הסדר חוקי ספציפי; אפשר להפעילה רק בריק משפטי (או כשההסדר החוקי אינו מיושם בפועל); והיא כפופה גם לזכויות היסוד.

5.4 יישומים נוספים של הסמכות השיורית

- **פדרמן נ' שר המשטרה (בג"ץ 5128/94):** ישראל שלחה שוטרים להדרכת כוח משטרה חדש בהאיטי, במסגרת משלחת רב-לאומית. העותר טען שסמכויות המשטרה הן בתוך המדינה. **הנשיא שמגר:** אין חקיקה על שיגור יועצים לחו"ל — "האם בהיעדר חוק אין לה סמכות לשלוח למדינות חוץ שגרירים...? האם... אסור לה לשלוח משלחת רופאים לרואנדה...?" הסמכות קנויה לממשלה מכוח הסמכות השיורית, שכוללת קשרים וסיוע הדדי בינלאומי. ריק משפטי — העתירה נדחתה.
- **איגוד שמאי הביטוח נ' מדינת ישראל (בג"ץ 5062/97):** אחרי לילות קרה שפגעו בפירות טרופיים, במקום להכריז על "אסון טבע" לפי **חוק פיצויים לנפגעי אסונות טבע** (שבו השמאים מעריכים נזקים), סוכם על סובסידיה של 40 מיליון ₪ מכוח הסמכות השיורית. השמאים עתרו; אחר כך משכו, וביקשו הכרעה עקרונית — **עתירה תיאורטית**, שנדחתה. אבל השופט **אור** העיר (אמרת אגב): הממשלה אינה רשאית לבחור "מסלול מקביל" לפני שבחנה את הפעלת החוק. רק אם דנה בכך ענייני וסביר, והחליטה שלא להכריז על אסון טבע — אז, ורק אז, "בכפוף לכל דין" אינו מונע ממנה לפצות מכוח הסמכות השיורית. (צמצום של קריית גת.)
- **הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל נ' ממשלת ישראל (בג"ץ 5100/94):** הסמכות השיורית **אינה מקור** לסמכות שפוגעת בחירות הפרט — ס' 32 אינו מתיר "לחץ פיזי" בחקירות.
- **ועדת המעקב העליונה (פרק 4):** אזורי עדיפות לאומית — הסדר ראשוני, ולכן ס' 32 אינו מספיק.

5.5 סמכויות עזר — ס' 17(ב) לחוק הפרשנות

§ סעיף — ציטוט / הסעיף

"הסמכה לעשות דבר או לכפות עשייתו — משמעה גם מתן **סמכויות עזר הדרושות לכך במידה המתקבלת על הדעת**."

דוגמה: רשות הטבע והגנים מוסמכת "להקים, לנהל, להחזיק, להפעיל ולטפח" שמורות וגנים לאומיים. מכאן — סמכות עזר לשכור עובדים, יועצים, חברת שמירה וקבלנים. ומה עם **קיוסק** בגן לאומי? סביר: מבקרים מצפים לקנות שתייה, וזה חלק מהפעלת הגן. ו**חתונות** בגן הלאומי כדי למען אותו? — נושא שנדון בפסיקה, וראו להלן.

שתי מגבלות:

1. סמכות העזר חייבת להיות **נלווית** לסמכות הראשית ונדרשת לה — אי אפשר "לקנות" סמכות ראשית במסווה של סמכות עזר.
2. "**במידה המתקבלת על הדעת**" — כפופה לסבירות ולמידתיות; לא להגזים.

מגבלה שלישית (מהפסיקה): אין להפעיל סמכות עזר באופן ש**פוגע בזכויות יסוד** — שם נדרשת הסמכה מפורשת (כלל פרשנות 1).

5.6 סמכויות עזר בפסיקה

איגוד העיתונים היומיים נ' רשות השידור (בג"ץ 757/84): רשות השידור — תאגיד סטטוטורי שתפקידיו פורטו בחוק (חינוך, בידור ואינפורמציה; לשקף את חיי המדינה; לטפח אזרחות טובה; לחזק את הקשר למורשת; שידורים בערבית ולתפוצות). כדי לממן מעבר לטכנולוגיה חדשה ביקשה לשדר **תשדירי שירות**, **שקופיות חסות** ו**פרסומות**. העיתונים, שהכנסותיהם היו נפגעות, עתרו.

סוג השידור	ההכרעה	הנימוק
תשדירי שירות	מותר	חלק מהסמכות המפורשת — אינפורמציה

שקופיות חסות מותר — **סמכות** נדרש להפעלת הסמכות הראשית, "במידה המתקבלת על הדעת";
עזר פורמט מקובל בשידור ציבורי בעולם, ואינו פוגע במהותו הציבורית
פרסומות **אסור** סותר את מהות השידור הציבורי — אינו "מתקבל על הדעת"
מסחריות

השופט אלון (אמרת אגב): הרשות היא תאגיד "כשר לכל חובה, זכות ופעולה משפטית" — היא רשאית לגייס כסף בכל דרך חוקית שלא נאסרה, כדי לממן את התפקידים שלשמם הוקמה; אין צורך בהסמכה מיוחדת. **דעת המיעוט:** מטרת תשדירי החסות היא גיוס כספים — שינוי במבנה התקציב, תפקיד **מרכזי ועצמאי**, ולכן נדרשת **הסמכה מפורשת**; והזיקה בין סמכות העזר לראשית צריכה להיות **חיונית**, לא רק סבירה. **ההלכה:** סמכות עזר תוכר כשקיימת **זיקה** בין התפקיד הראשי לסמכות העזר; כשאין פגיעה בזכויות אדם — גישה מרחיבה.

מגן דוד אדום נ' הממונה על השכר (ע"א 9657/03): הוועד המנהל של מד"א (תאגיד סטטוטורי) החליט לשלם ליו"ר — שתפקידו התנדבותי — שכר של 50% משכר המנכ"ל. הממונה על השכר סירב. מד"א טען: סמכות עזר. **השופט ג'ובראן** — הבחנה בין שני מישורים:

מישור	תוכן	היקף סמכויות העזר
חיצוני	הפעלת הסמכויות כלפי הציבור (פינוי לבתי חולים, טיפול בחירום)	**מצומצם**
פנימי	הארגון שמשרת את המישור החיצוני — לוגיסטיקה, הכשרות, ציוד; זקוק לאוטונומיה, גמישות ויעילות	**רחב**

ובכל זאת — קביעת שכר ליו"ר **חורגת** מהמינהל הפנימי: הזיקה לסמכות הראשית אינה הדוקה מספיק; **תשלום שכר בגוף ציבורי מחייב הסמכה מפורשת**. (ניתן להעיר שגם שיקולים אחרים תמכו בתוצאה: השפעה על תאגידים אחרים, ויו"ר שאמור לפקח על שכר המנכ"ל.) **כלל עזר:** מחיר אפשר לגבות במסגרת סמכות עזר; **אגרה ומס — לא**.

פלונית נ' קצין התגמולים (רע"א 2558/16): שוטרת לשעבר עם 20% נכות ביקשה החמרה. קצין התגמולים שלח **חוקר פרטי** שצילם אותה בשוק ובחוג יוגה, ואחוזי הנכות הופחתו ל-10%. בית המשפט: "הפעלה רחבה של [העיקרון בדבר סמכויות עזר] עלולה לסכל את תכליתו של עקרון חוקיות המינהל. לפיכך, **מגבלה יסודית** על הכרה בסמכויות כסמכויות עזר היא האפשרות לעשות כן אך ביחס לסמכויות

שאינן פוגעות בזכויות יסוד" — מעקב פוגע בפרטיות, ולכן אין סמכות עזר כזו. (בביטוח הלאומי, לעומת זאת, ניתנה סמכות מפורשת.)

ברזון נ' מדינת ישראל: בעניין הפרדה במוסדות — "הסמכה לעשות דבר או לכפות עשייתו — משמעה גם מתן סמכויות עזר הדרושות לכך במידה המתקבלת על הדעת". **היועמ"ש נ' זיאד:** שוטר אינו מוסמך להורות לעציר לנקות את התא — פגיעה בזכויות; אין להסתפק בסמכות עזר כללית.

5.7 סמכות טבועה מתוקף התפקיד

לצד שני המקורות, הפסיקה הכירה לעיתים בסמכות "טבועה" בתפקיד:

- **אל-סרוג'י נ' שר הדתות:** בהיעדר בעלי תפקיד מוסמכים, משרד הדתות נטל סמכויות כדי לספק שירותי דת — כדי לאפשר למשרד למלא את ייעודו.
- **התנועה למשילות ודמוקרטיה:** מעמד נשיאת בית המשפט העליון כראש הרשות השופטת מקנה לה סמכות להורות למועמדים לשיפוט שלא להיפגש עם פוליטיקאים — אף שהחוק לא הסמיך במפורש.

אלה חריגים מצומצמים; ככלל — אין סמכות בלי חוק.

5.8 ריבוי מקורות סמכות

לעיתים יש **כמה מקורות סמכות** לאותה פעולה. בישראל יש יותר מ-20 חוקים שמאפשרים **הפקעת קרקע**: **פקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 1943** — מנדטורית, מהירה, עם יכולת התנגדות מצומצמת; **חוק התכנון והבנייה** — הליך ארוך ומסודר, עם אפשרויות התנגדות רבות (קודם תוכנית שמייעדת את הקרקע לצורכי ציבור); וחוקים ייעודיים (מסילות ברזל, מים). ס' 19 לחוק הפרשנות: סמכות לפי חיקוק אחד אינה גורעת מסמכות לפי חיקוק אחר. איזה לבחור?

פסק הדין	העובדות	ההלכה

פילצר נ' שר האוצר (בג"ץ 171/69)	הפקעות בשכונת ימין משה בירושלים לאחר 1967, לשיקומה כשכונת אמנים — לפי הפקודה, ולא לפי חוק בינוי ופינוי	השופט **לנדוי**: "הפקודה והחוק הם שני מעשי חקיקה שווי דרגה, ואין בחוק... הוראה מפורשת השוללת משר האוצר את סמכותו לפעול לפי הפקודה". הרשות **רשאית לבחור**
מהדרין נ' שר האוצר (בג"ץ 3028/94)	של אזורי שיקום (הידידותי יותר) הפקעת פרדסים להרחבת נמל התעופה בן גוריון — לפי הפקודה ולא לפי חוק התכנון והבנייה	גם אחרי חוקי היסוד: "שני מסלולים נפרדים, ובידי הרשות לבחור מסלול הנראה לה ביותר"
יוחייב נ' התובע הצבאי הראשי (רע"פ 1057/99)	מי שלא התייצב לגיוס טופל בדרך הקשוחה (ס' 49) ולא בדרך המקלה (ס' 12) בחוק שירות ביטחון	העתירה נדחתה, אבל נקבע: שיקול הדעת בבחירה בין סמכויות מקבילות **כפוף למבחן המידתיות** — "על הרשות להעדיף את הסמכות שפגיעתה קלה יותר, אלא אם קיימים שיקולים להעדיף את השנייה"

המצב היום: פילצר לא בוטלה; יוחייב מוסיפה דרישת מידתיות — אך "שיקולים" להעדפת הסמכות הקשוחה (זמן, כסף) קיימים כמעט תמיד, ולכן כוחה מוגבל.

5.9 סיווג סמכויות — חקיקה, ביצוע ומעין-שפיטה

לרשות המבצעת יש לא רק סמכויות **ביצוע** (רישוי, פיקוח, קנסות, מדיניות), אלא גם סמכויות **מעין-חקיקה** (תקנות, צווים, חוקי עזר — פי חמישה מחוקי הכנסת) ו**מעין-שפיטה** (השגות, ועדות ערר, בתי דין מנהליים — 15 ועדות ערר בתכנון ובנייה בלבד; בתי הדין לעובדים זרים ואשרות). (וגם לכנסת יש סמכויות ביצוע — מכרזים — ומעין-שפיטה — ועדת האתיקה.)

מבחן מעין-חקיקה — היועמ"ש נ' הורנשטיין (ע"פ 74/58): הורנשטיין קיבל קנס חנייה בתל אביב. חוק העזר קבע איפה מותר לחנות, והסמיך את **ראש העירייה** לקבוע: (1) אילו מקומות "מוסדרים" (בתשלום); (2) מדחן או סדרן; (3) כמה משלמים. הטענה — הכלל האנגלי: **"שליח אינו עושה שליח"** — מי שקיבל סמכות מעין-חקיקה אינו רשאי להעבירה הלאה. **השופט אגרנט** — סימני ההיכר של **תקנה בת-פועל תחיקתי** (שני תנאים מצטברים):

1. קובעת **נורמה משפטית** — כלל התנהגות שמשנה את המשפט הנוהג;
2. הנורמה **כללית** — מופנית לציבור כולו או לחלק בלתי מסוים ממנו.

היישום: קביעת מקום כ"מוסדר" — מעין-חקיקה (לא הייתה מותרת לראש העירייה); קביעת התעריף — מעין-חקיקה; בחירה בין מדחן לסדרן — **ביצוע** בלבד (אין שינוי במשפט). הערעור התקבל.

מבחן מעין-שפיטה — ברמן נ' שר הפנים (בג"ץ 3/58): ועדת גבולות המליצה להעביר את שכונת נחלת יצחק מתל אביב לגבעתיים. התושבים ביקשו להשמיע טענותיהם בפני השר; סירב. באותה תקופה — זכות טיעון רק בסמכות מעין-שיפוטית. **השופט זילברג:** גוף מנהלי פועל באורח מעין-שיפוטי כשהכרעתו מתבססת על קביעת ממצאים **השנויים במחלוקת בין שני צדדים "מתדיינים"**. כאן — אין סכסוך מקדים; המהלך התחיל בהחלטה חד-צדדית של השר — סמכות **ביצוע**. אבל זילברג קבע גם: הכלל שאין זכות טיעון בסמכות ביצוע **אינו נכון** — גם החלטת ביצוע שפוגעת באדם מחייבת שמיעתו (פרק 8).

מדינת ישראל נ' סלוק (בש"א 136/90): חוקר משטרה לשעבר ביקש רישיון חוקר פרטי; הוועדה סירבה (חוסר ניסיון במעקבים); המחוזי הפך. האם ערעור המדינה לעליון בזכות? תלוי אם החלטת הוועדה שיפוטית. בית המשפט: "המבחן העיקרי הוא קיומו של **סכסוך בין שני צדדים**" — כאן אין "ריב" בין צדדים, ולכן החלטה **מנהלית**; גם זכות הוועדה לשמוע את היועמ"ש ולאסוף ראיות אינה משנה זאת.

סוג	המבחן
מעין-חקיקה	(1) מופנית לציבור בלתי מסוים; **וגם** (2) משנה את המצב הנורמטיבי
מעין-שפיטה	הכרעה של צד שלישי (הגוף המנהלי) בסכסוך בין שני צדדים
ביצוע	כל השאר

5.10 למה הסיווג חשוב — "כללי עוצמה"

כללי הפרוצדורה אינם בינאריים ("יש/אין"), אלא **כללי עוצמה** — עוצמתם משתנה לפי סוג הסמכות:

כלל	מעין-חקיקה	ביצוע	מעין-שפיטה
זכות טיעון	חלשה (מכתב שיועבר)	בינונית (שימוע, בלי חקירה נגדית)	חזקה (בכתב ובעל פה, עם עו"ד, עיון בטענות הצד שכנגד, חקירה נגדית)
חובת הנמקה	חלשה (דברי הסבר)	בינונית	חזקה (החלטה מפורטת)
סופיות	חלשה (אפשר לשנות)	בינונית	חזקה (אי אפשר לשנות אחרי שנמסרה)

איסור גיבוש עמדה מראש / עצמאות פרסום	חלש (חבר מועצה שננשך בידי כלב אינו פסול)	בינוני	חזק
	חזק — חובה, אחרת אין תוקף	בינוני	חלש — מסירה לצדדים

מלאך נ' לוי (בג"ץ 701/81): יו"ר ועדה שהייתה אמורה לשמוע התנגדויות להקמת אצטדיון התבטא בעיתון בעד הפרויקט ופעל לשכנע מתנגדים לחזור בהם. כשהוא שומע התנגדויות ומכריע — הוא **כשופט**, ואסור לו להיות נעול מראש. העתירה התקבלה.

5.11 סמכות חובה וסמכות רשות

אופנהיימר נ' שרי הפנים והבריאות (בג"ץ 295/65): החוק למניעת מפגעים (1961) אסר רעש, ריח וזיהום "בלתי סבירים", וקבע שהשרים "**רשאים**" לקבוע בתקנות מה נחשב כזה. ארבע שנים לא הותקנו תקנות — ובלעדיהן אי אפשר לאכוף את החוק. אופנהיימר, שגר ליד מאפייה עם גנרטור סולר, עתר. השרים: "רשאים" — סמכות רשות. בית המשפט: זו **סמכות חובה**.

- בכל סמכות יש **רכיב חובה** (להפעיל את הסמכות, בזמן סביר — ס' 11 לחוק הפרשנות) ו**רכיב רשות** (שיקול הדעת לגבי התוכן).
- "רשאים" התייחס ל**תוכן** התקנות; עצם התקנתן — חובה, כי החוק כולו תלוי בהן.
- האם סמכות היא חובה או רשות — שאלה **פרשנית**, לפי מהות הפעולה ולא רק הנוסח. (עירייה מוסמכת להסיר מטרד — אם משאית התהפכה ויש הר זבל, היא חייבת.)

5.12 פעולה בניגוד לחוק — חריגה מסמכות

דוגמה: משרד השיכון מוסמך בחוק לבנות דיור למעוטי יכולת, ובונה שכונה **בלי היתר בנייה** לפי חוק התכנון והבנייה (שחל גם על המדינה). יש סמכות לבנות, הפרוצדורה תקינה והשיקול ענייני — ובכל זאת: **פעולה בניגוד לחוק היא חריגה מסמכות**. הסמכות היא לפעול **לפי החוק**; טענת אי-חוקיות היא חלק מטענת הסמכות.

5.13 מלכודות נפוצות

! שים לב — מלכודות נפוצות

- לחשוב שס' 32 מסמיך את הממשלה לפעול גם כשיש חוק בנושא — הסמכות נסוגה.
- לשכוח את דורנר: "כל דין" כולל הלכה פסוקה וזכויות יסוד.
- להפעיל סמכות עזר לפגיעה בזכויות — אסור (פלונית נ' קצין התגמולים).
- לבלבל בין מבחן מעין-חקיקה (שני תנאים מצטברים) למבחן מעין-שפיטה (סכסוך בין שני צדדים).
- לחשוב ש"רשאי" תמיד פירושו סמכות רשות — אופנהיימר.

5.14 שלד לפתרון שאלה — מציאת מקור לסמכות

1. **חפשו הסמכה מפורשת** – חוק או תקנה מכוחו המסמיכים את הגורם לעשות את הפעולה.
2. **אם אין** – בדקו סמכות עזר (ס' 17(ב)): האם הפעולה נלווית לסמכות מפורשת, נדרשת במידה המתקבלת על הדעת ואינה פוגעת בזכויות יסוד?
3. **ואם מדובר בממשלה** – בדקו סמכות שיורית (ס' 32): בכפוף לכל דין (כולל הלכה פסוקה וזכויות יסוד), ובלבד שאין חוק שמסדיר את הנושא ושהפעולה לא מוטלת על רשות אחרת.
4. **סווגו את הסמכות** – חקיקה, ביצוע או מעין-שפיטה; הסיווג קובע את עוצמת כללי הפרוצדורה (זכות טיעון, פרסום).
5. **הכריעו** – סמכות חובה או רשות, ואם יש כמה מסלולים – בחירה לפי מידתיות (יוחייב).

5.15 מלכודות בפתרון שאלות — טבלה

הטעות	למה היא שגויה	התיקון
להפעיל סמכות שיורית כשיש חוק קריית גת: הסמכות השיורית נסוגה מפני	לבדוק אם הנושא מוסדר	הסדר בחוק

להפעיל סמכות עזר כדי לפגוע בזכות	פלונית: סמכות עזר אינה מקור לפגיעה בזכויות יסוד	לדרוש הסמכה מפורשת
לגבות אגרה או מס מכוח עזר	אפשר מחיר בלבד; אגרה ומס מחייבים הסמכה	להבחין מחיר/אגרה/מס
לסווג בחירה בין מדחן לסדרן כמעין-חקיקה	הורנשטיין: זו פעולת ביצוע, אין שינוי במשפט	להפעיל את שני תנאי אגרנט
לחשוב ש"רשאי" פירושו חופש מוחלט	אופנהיימר: יש רכיב חובה – להפעיל בזמן סביר	לבחון חובה/רשות לפי מהות הפעולה

5.16 תרגיל פתור — רשות שידור, פרסומות ושקיפות

✎ דוגמה — סמכות עזר לגוף ציבורי

העובדות: רשות ציבורית שהוקמה בחוק לשידור ציבורי מחליטה (א) לשדר תשדירי שירות; (ב) להציג בתחילת תוכניות שקופית חסות; (ג) לשדר פרסומות מסחריות לשם הגדלת הכנסות. עיתונים עותרים.

הפתרון:

1. **מקור:** אין הוראה מפורשת בחוק לגבי שניים מהשלושה, ולכן הבדיקה היא של סמכות עזר.
2. **תשדירי שירות:** נכללים בהסמכה מפורשת.
3. **חסות:** נלווית לשידור, במידה המתקבלת על הדעת, ואינה פוגעת במהות הציבורית – מותרת כסמכות עזר.
4. **פרסומות:** סותרות את מהות השידור הציבורי ואינן מתקבלות על הדעת – אסורות (איגוד העיתונים).
5. **מסקנה:** עתירה תתקבל לגבי הפרסומות בלבד.

5.17 סיכום הפרק

✔ שורה תחתונה — סיכום הפרק

- סמכות שיורית (ס' 32 לחוק יסוד: הממשלה): בכפוף לכל דין, ובלבד שלא מוטלת על רשות אחרת; נסוגה מפני הסדר בחוק (קריית גת); אינה מקור לפגיעה בחירויות.
- סמכות עזר (ס' 17(ב)): נלווית לסמכות ראשית, במידה המתקבלת על הדעת, ולא לפגיעה בזכויות (פלונית, מגן דוד אדום).
- ריבוי מקורות: בחירה חופשית בין חיקוקים שווי דרגה (פילצר), בכפוף למידתיות (יוחייב).
- סיווג: חקיקה (הורנשטיין – שני תנאים), מעין-שפיטה (ברמן וסלוק – סכסוך בין צדדים), ביצוע.
- כללי עוצמה: זכות טיעון חזקה במעין-שפיטה; פרסום חזק במעין-חקיקה; אופנהיימר – רכיב חובה בכל סמכות רשות.

5.18 מילון מושגים

- **סמכות שיורית** — סמכות הממשלה לפעול בנושא שלא הוסדר ולא הוטל על רשות אחרת.
- **סמכות עזר** — סמכות נלווית הדרושה להפעלת הסמכות הראשית.
- **ריק משפטי** — היעדר הסדר בחוק.
- **מסלול מקביל** — פעולה מכוח ס' 32 לצד הסדר חוקי קיים — אסורה.
- **תקנה בת-פועל תחיקתי** — נורמה כללית שמשנה את המשפט.
- **"שליח אינו עושה שליח"** — איסור להעביר סמכות מעין-חקיקה.
- **כלל עוצמה** — כלל שעוצמתו משתנה לפי הנסיבות.

5.19 נקודות מפתח למבחן

✔ שורה תחתונה — עיקרי הפרק

- ס' 32: "בכפוף לכל דין" + "אינה מוטלת בדין על רשות אחרת"; קריית גת — נסוגה מפני הסדר; דורנר — כולל הלכה וזכויות; פדרמן — ריק משפטי; שמאי הביטוח — מסלול מקביל רק אחרי בחינת החוק; עינויים — לא לפגיעה בחירות.
- ס' 17(ב): נלווית; "במידה המתקבלת על הדעת"; לא לפגיעה בזכויות. איגוד העיתונים (חסות — כן; פרסומות — לא); מד"א (פנימי/חיצוני; שכר — הסמכה מפורשת); פלונית (חוקר פרטי — לא).
- סמכות טבועה — חריגים (אל-סרוג'י; נשיאת העליון).
- ריבוי מקורות: פילצר ומהדרין (בחירה חופשית) מול יוחייב (מידתיות).
- הורנשטיין (מעין-חקיקה: נורמה + כללית); ברמן וסלוק (מעין-שפיטה: סכסוך; כללי עוצמה; מלאך.
- אופנהיימר: רכיב חובה ורכיב רשות; פעולה בניגוד לחוק — חריגה מסמכות.

5.20 שאלות בסגנון המבחן

✎ דוגמה — שאלה בסגנון המבחן (1)

חוק מסדיר מנגנון מפורט לסיוע לעסקים בעת שביתה כללית. הממשלה החליטה, מבלי לבחון את הפעלת החוק, להעניק לעסקים מענק מכוח ס' 32 לחוק יסוד: הממשלה. מה הדין?

א. ההחלטה כדין — לממשלה סמכות לכל פעולה. ב. ההחלטה פגומה — כשקיים הסדר בחוק, הסמכות השיורית נסוגה, ואין לבחור "מסלול מקביל" לפני שנבחנה הפעלת החוק. ג. ההחלטה כדין, כי מדובר בהטבה ולא בפגיעה. ד. ההחלטה פגומה רק אם לא פורסמה.

התשובה וההסבר

ב. קריית גת ושמאי הביטוח. ג' — העובדה שזו הטבה אינה מתירה מסלול מקביל.

✎ דוגמה — שאלה בסגנון המבחן (2)

מועצת עירייה הסמיכה את ראש העירייה לקבוע בצו את גובה הקנס על השלכת פסולת ברחוב. מה הטענה החזקה ביותר?

א. מדובר בסמכות ביצוע, ולכן אין בעיה. ב. קביעת גובה קנס היא סמכות מעין-חקיקה (נורמה כללית שמשנה את המשפט), ומי שקיבל סמכות כזו אינו רשאי להעבירה — "שליח אינו עושה שליח". ג. נדרש שימוע לכל תושב. ד. מדובר בסמכות מעין-שיפוטית.

התשובה וההסבר

ב. הלכת הורנשטיין: הנורמה כללית ומשנה את המשפט — מעין-חקיקה.

5.21 שאלות לחשיבה

1. האם ס' 32 "מציל" את שלטון החוק או פוגע בו?

תשובה אפשרית: פורמלית — מציל, כי גם הסמכות השיורית מעוגנת בחוק. מהותית — פוגע, כי הממשלה יכולה לפעול כמעט בכל נושא בלי חקיקה. הפסיקה מצמצמת את הנזק: נסוג מפני הסדר, כפוף לזכויות, ואינו מספיק להסדרים ראשוניים.

2. למה זכות הטיעון חזקה יותר בהליך מעין-שיפוטי?

תשובה אפשרית: כשיש שני צדדים יריבים והרשות מכריעה ביניהם, ההליך דומה למשפט — וההגינות מחייבת כלים דומים (עיון, חקירה נגדית). בחקיקת משנה, שפונה לציבור רחב, אין אפשרות מעשית לשמוע כל אחד בהרחבה.

פרק 6

עצמאות שיקול הדעת — הלכת מיכלין, הנחיות מנהליות ונטילת סמכות

6.1 מבוא — למה זה חשוב ומה מקומו בתמונה הגדולה

עד כאן עסקנו בצד ה"מהותי" של הסמכות: איפה היא נמצאת ואיך מפרשים אותה. עכשיו — הצד ה**פרסונלי**: מי בדיוק צריך להפעיל אותה? אם החוק הסמיך פקיד מסוים — האם הוא חייב לציית לשר שמעליו? האם מותר לו להתייעץ, לפעול לפי הנחיות, להעביר את הסמכות לאחר, או להיעזר בחברה פרטית? בפרק נלמד את המתח בין שני עקרונות: **עצמאות שיקול הדעת** של בעל הסמכות, מול **המבנה ההיררכי** של הרשות המבצעת. נושא מרכזי במיוחד — ומופיע הרבה בשאלות מבחן.

6.2 עקרון עצמאות שיקול הדעת — שלושה עקרונות משנה

הרעיון הכללי: אם החוק הסמיך אותך — הפעל את שיקול הדעת **בעצמך**, ואל תסתתר מאחורי אחרים.

עיקרון משנה	תוכן	דוגמה
1. איסור כבילת שיקול הדעת	אסור להתחייב מראש מה תחליט (Non-Fettering) — ההחלטה הטובה תלויה בנסיבות שלא להעלות מסים 20 שנה — הוא אינו ברגע ההחלטה	חברה תקים מפעל אם שר האוצר יתחייב יכול: אולי תפרוץ מלחמה
2. איסור דעה מוקדמת	לבוא לקבלת ההחלטה בראש פתוח, לאסוף נתונים, לשמוע — ורקלבוא "נעול" אז להחליט	בית חולים בבאר שבע או באשדוד — אסור
3. חובה להפעיל שיקול דעת עצמאי	מי שהוסמך — הוא שקובע	הלכת מיכלין

המקור: שילוב של עקרון הסמכות (המחוקק בחר בו) וחובת הנאמנות (עובד הציבור חב נאמנות לציבור — לא לשר).

מנגד — העיקרון ההיררכי: הרשות המבצעת היא פירמידה; כל אחד מבצע הוראות של הממונה עליו. דוגמה: ראש אגף רישוי כלי ירייה (הגורם המוסמך בחוק) סבור שיש לצמצם רישיונות; השר — שיש להרחיבם בשל המצב הביטחוני. מי גובר?

6.3 מיכלין נ' שר הבריאות (בג"ץ 70/50)

⚖ פסק דין — עובדות והכרעה

העובדות: אחרי מלחמת העצמאות, בתקופת צנע, הוסמך בכל משרד **מפקח על המחירים**. יבואני התרופות, ובהם מיכלין, הגיעו להסכמה עם השרים על רמת מחירים. אבל המפקח, פוגל — הגורם המוסמך — סבר שהמחירים גבוהים מדי ופרסם טבלת מחירי מקסימום זולה יותר. מיכלין עתר: המפקח פעל בניגוד להחלטת השר.

§ סעיף — ציטוט / הסעיף

השופט דונקלבלום: "התקנה... מעניקה סמכות לרשות המפקחת... היא איננה מחייבת את הרשות המפקחת להישמע או להיכנע להוראותיו של השר הממונה עליה. לדעתי אם חוק מעניק כוח ידוע למוסד או לרשות מיוחדת... הרי על המוסד או על הפקיד לפעול בהתאם לזה, ועל כל פנים **אינו מחויב להישמע להוראותיו של מישהו אחר**... להיפך, יש אסמכתא לדעה, כי **אם פקיד כזה יפעל על פי הוראות השר במקום לפעול על פי שיקול דעתו הוא — תהא פעולתו בטלה**."

חלק	התוכן
הרציו	השר רוצה א', הפקיד המוסמך רוצה ב' — קובע הפקיד
האוביטר	הפקיד רוצה ב', אבל בגלל השר קובע א' — ההחלטה **בטלה**

בעיית ההוכחה: איך נדע שהפקיד החליט בגלל השר ולא כי השתכנע? השאלה הגדולה — האם האוביטר הפך להלכה, והאם נוצרה **חזקה** שפקיד שהחליט כמו השר לא הפעיל שיקול דעת עצמאי.

הנימוקים בעד ההלכה: עקרון הסמכות (המחוקק בחר בפקיד; לו רצה בשר — היה מסמיך את השר); חובת הנאמנות לציבור; ומומחיות מקצועית לעומת שיקולים פוליטיים (אף שההבחנה בין "מקצועי" ל"פוליטי" אינה נקייה — למשל החלטה מה להכניס לסל הבריאות). **הנימוקים נגד:** אין אחריות בלי סמכות — אם הפקיד טעה, האחריות הציבורית תוטל על השר; וההלכה אינה מציאותית — במבנה היררכי, פקיד כמעט אף פעם לא יפעל נגד שר. **פתרונות שהמחוקק יכול היה לבחור** (ולא בחר): להסמיך את ראש הפירמידה, או לקבוע כלל כללי שהפקיד יפעל לפי הנחיות השר.

6.4 התייעצות — מותרת, אבל ההחלטה שלך

המרכז של ארגוני הקבלנים נ' שר המסחר (בג"ץ 74/51): הממשלה החליטה לחלק את המלט החסר: 50% למשרד הביטחון, 30% לחברות ההסתדרות, 20% לקבלנים פרטיים. פקיד ההקצבות, נוי, יישם זאת. הקבלנים הפרטיים: הוא לא הפעיל שיקול דעת. בית המשפט **זימן את נוי לעדות** (צעד חריג): "אין כל רע בכך שהפקיד... יקבל **עצה או הדרכה** מפי אחרים, בתנאי כי **ההחלטה הסופית שלו** תהיה... בקבלו את המינוי הסכים מר נוי למדיניות ועשאה למדיניות שלו... אין אנו מקבלים את הטענה כי את רצונם של אחרים הוא עושה". העתירה נדחתה. **המשמעות:** האוביטר של מיכלין התקבל כהלכה; ה**חזקה** — לא.

שני סוגי התייעצות: סטטוטורית — חובה לפי החוק (למשל: השר יתקין תקנות "אחרי התייעצות עם המועצה הארצית"); **וולונטרית** — מרצון, ומותרת.

הגבול — ניימן נ' ועדת הבחירות (ע"ב 2/84): ועדת הבחירות פסלה את "הרשימה המתקדמת לשלום" על סמך חוות דעת של שר הביטחון, אלוף פיקוד ואיש שב"כ — שקבעו שהרשימה פועלת נגד המדינה, בלי לפרט (חומר סודי). השופט שמגר:

§ סעיף — ציטוט / הסעיף

"על בעל הסמכות רובצת החובה לבדוק את הנתונים; האחרים יכולים לקבצם, למיינם ולארגנם — ובלבד שלא יגרע משלמות התמונה ומדיוקה — והם רשאים אף לצרף עצותיהם, המלצותיהם או חוות דעותיהם, אך **ההחלטה נופלת על יסוד העיון העצמי** ולא על יסוד עיונם של אחרים."

הוועדה קיבלה "שורה תחתונה" בלי נתונים — כאילו העבירה את ההחלטה לשר הביטחון. אין כאן חזקה, אלא **מסקנה עובדתית**: מי שלא ראה את העובדות — לא יכול היה להחליט בעצמו.

התייעצות עם הממונה — הסתדרות הרוקחים נ' שר הבריאות (בג"ץ 4870/90): פקודת הרוקחים אסרה בית מרקחת במרחק של פחות מ-500 מ' מבית מרקחת קיים, אך המנכ"ל רשאי להתיר אם הדבר "חיוני". סופר-פארם ביקשה לפתוח בקניון השרון בנתניה; בפגישה עם השר (והמנכ"ל) אמר השר שהסעיף מיושן והוא מתכוון לבטלו, ובינתיים — שיגישו בקשה למנכ"ל. המנכ"ל התיר. הרוקחים: הוא פעל לפי השר. המנכ"ל בתצהיר: התייעצתי, השתכנעתי והחלטתי בעצמי. העתירה נדחתה — מותר **לאמץ** את מדיניות השר אחרי בחינה עצמאית.

שייב (פרק 2): "אין שר החינוך חייב ואין הוא רשאי לעשות מעשה אשר עלה במחשבת שר הביטחון, **אלא אם נתן דעתו** על אותה מחשבה **ועשאה מחשבתו הוא ורצונו הוא**." **רוטשטיין נ' המועצה המקומית הרצליה:** רשות מוסמכת אינה עושה את תפקידה כראוי כשהיא מסכימה להפוך ל"עושה דברם של אחרים" — אסור שגופים יכפו את רצונם עליה (חלוקת חלב). **שטיין נ' שר הפנים:** גם אם ניתנה הוראה לבטל רישיון לעיתון — השאלה היא אם הממונה בדק בעצמו את העובדות והגיע למסקנה.

6.5 הנחיות מנהליות

מהן: "כללים גמישים שרשות מנהלית קובעת לעצמה כדי שידריכו אותה בהפעלת סמכותה". שמות שונים: הנחיות, נהלים, חוזרים, הוראות ביצוע, מדיניות, קווי פעולה, תוכנית אב. צורות שונות: מהתקשי"ר והתכ"ם (כלל-ממשלתיים), דרך חוזר מנכ"ל משרד החינוך והחלטות מועצת מקרקעי ישראל, ועד הנחיות של פקיד רישוי לעובדיו או סיכום דיון.

צד	הנקודות
	יתרונות גיבוש יסודי, בלי לחץ של החלטה ספציפית; אחידות ושוויון; עיצוב מדיניות; ודאות לאזרח; ביקורת שיפוטית קלה יותר
	חסרונותנוקשות במקום גמישות — הפקיד "כבול" במקום להפעיל שיקול דעת

הכוח המחייב — חפציבה נ' מינהל מקרקעי ישראל (בג"ץ 2709/91): לפי הנחיות המינהל, כשזוכה במכרז אינו מממש את זכייתו — יוצאים **למכרז חדש**. חפציבה, שהגיעה שנייה בפער קטן, ביקשה לקבל את הקרקע. בג"ץ קיבל את העתירה. **השופט אור:** קביעת מדיניות שהרשות תפעל לפיה "תהיינה הנסיבות אשר תהיינה — **כמוה כהחלטה שלא להפעיל את שיקול הדעת**", ועלולה להיפסל. **ההנחיות אינן מחייבות באופן מוחלט** — אפשר, ולעיתים חובה, לשקול סטייה מהן.

אבל הסטייה מוגבלת — סיעת למען התורה נ' המועצה הדתית צפת (עע"מ 6726/10): הנחיית המשרד לשירותי דת: אין לפתוח בהליך למינוי רב שכונה בלי תקן ותקציב מאושרים. המועצה הדתית בצפת פתחה בהליך בכל זאת, בטענת "מצב חירום". השופט רובינשטיין ביטל את ההליך: "היכולת וההיתר לסטות מהנחיות — יכולת והיתר **מוגבלים** הם... כל החלטה של הרשות לסטות מהנחיותיה היא החלטה מיוחדת, המחייבת שיקול דעת מינהלי מתאים, **נימוקים חזקים במיוחד** ועמידה בדרישות דיוניות גבוהות מהרגיל... ומצדיקה ביקורת קפדנית במיוחד".

הנחיות מול מיכלין: הרציו והאוביטר חלים **חלקית מאוד** — פקיד שפועל לפי הנחיה פנימית, גם אם היה מחליט אחרת, החלטתו ככלל תקפה; סטייה — רק בנימוקים חזקים. כלומר, ההנחיות הן **חריג גדול** להלכת העצמאות.

פרסום הנחיות: האם הן "תקנה בת-פועל תחיקתי" (נורמה + כללית) שמחייבת פרסום ברשומות? אפשר לטעון לכאן ולכאן; בית המשפט קבע שלא — כדי לשמור על גמישותן. אבל **ס' 6(א) לחוק חופש המידע, התשנ"ח–1998**: "רשות ציבורית תעמיד לעיון הציבור את ההנחיות המנהליות הכתובות שעל פיהן היא פועלת ושיש להן נגיעה או חשיבות לציבור" — וכיום הן מפורסמות באתרי הרשויות (פרק 9).

6.6 נטילת סמכות — ס' 34 לחוק יסוד: הממשלה

§ סעיף — ציטוט / הסעיף

"שר הממונה על ביצועו של חוק רשאי ליטול לעצמו כל סמכות, למעט סמכות בעלת אופי שיפוטי, הנתונה על פי אותו חוק לעובד המדינה, אם אין כוונה אחרת משתמעת מן החוק. השר רשאי לעשות כאמור לעניין מסוים או לתקופה מסוימת."

תנאי	הסבר	דוגמה שבה התנאי אינו מתקיים
1. השר **הממונה על ביצוע** החוק	לפי סעיף ההגדרות והביצוע בחוק	
2. הסמכות נתונה ל**עובד המדינה**	עובדי משרדי הממשלה — לא עובדי רשויות מקומיות או תאגידים סטטוטוריים	שר האוצר אינו יכול ליטול את סמכות נגיד בנק ישראל לקבוע ריבית; שר הפנים אינו יכול ליטול סמכות ראש עירייה להסיר מטרד
3. סמכות **שאינה שיפוטית**	לא סמכות להכריע בסכסוך	ועדת ערר לתכנון; המפקח על המקרקעין בסכסוכי בית משותף
4. **אין כוונה אחרת** משתמעת מהחוק	פרשנות	שר הבריאות אינו יכול ליטול את סמכות הפסיכיאטר המחוזי לאשפוז כפוי (חוק טיפול בחולי נפש)

הוראות ספציפיות נוספות: למשל ס' 28 לחוק התכנון והבנייה — הוועדה המחוזית רשאית להורות לוועדה המקומית, ואם לא קיימה — לבצע בעצמה. נטילת סמכות היא **חריג גדול** להלכת מיכלין.

6.7 העברה, האצלה והסתייעות

פעולה	המשמעות	מתי מותר
העברת סמכות	הקשר בין בעל הסמכות לסמכות **מתנתק**; אינו יכול להחזירה או להנחות	רק בהסמכה מפורשת (למשל העברה משר לשר בחוק יסוד: הממשלה, באישור הכנסת)

האצלת סמכות	הקשר **אינו מתנתק**: המאציל יכול לבטל את ההאצלה ולהנחות את הנאצל; הנאצל הופך ל"רשות מוסמכת" — כפוף לכל הכללים וחשוף לביקורת	בהסמכה — מפורשת או **משתמעת**
הסתייעות	עזרה באיסוף נתונים או בפעולות טכניות; שיקול הדעת וההחלטה נשארים אצל בעל הסמכות	**חזקה שמותר**, אלא אם החוק אוסר

> **§ סעיף — 33 לחוק יסוד: הממשלה**
>
> הממשלה רשאית לאצול סמכות לשר; שר רשאי לאצול סמכות שלו (למעט **התקנת תקנות**) לעובד ציבור — כולה, מקצתה או בסייגים.

פיליפוביץ נ' רשם החברות (בג"ץ 2303/90): רשם החברות, שמחזיק מרשם פתוח לציבור, מסר בהליך מכרז לחברה פרטית את מתן שירותי העיון והצילום. פיליפוביץ, שהפסיד במכרז, טען: האצלה אסורה. **השופט ברק:** "חזקה היא על חוק כי תכליתו אינה להסמיך את בעל הסמכות לאצול... **אין חזקה** כי תכלית החוק היא למנוע מבעל הסמכות לקבל מאחר **סיוע**... נהפוך הוא... יש להבטיח כי ההסתייעות לא תהיה כה מקיפה ועמוקה, עד כי הלכה למעשה תהיה שקולה כנגד האצלת הסמכות." כאן — סיוע טכני בלבד (החברה אינה מחליטה מה פתוח לעיון ואינה מטילה קנסות). והאצלה — "חזקה פרשנית... כי אצילת סמכות אסורה היא, אלא אם כן הדבר הותר... לעתים ניתן להסיק אותה כמשתמעת מתוך החוק".

אנכית מול אופקית: בית המשפט נוטה להתיר אצילה **אנכית** (לכפוף בהיררכיה) גם בלי הסמכה מפורשת; ונוטה שלא להתיר אצילה **אופקית** (למי שאינו כפוף) בלי הסמכה מפורשת.

לגורם פרטי — לא:

- **הנפלינג נ' ראש עיריית אשדוד (בג"ץ 839/82):** ראש העירייה מינה מתנדבים פרטיים כ"מפקחים" על סגירת עסקים בשבת, עם סמכויות כניסה וקנסות. כשביטל את המינויים — אחד מהם עתר. העתירה נדחתה, ונקבע שהמינוי מלכתחילה היה פסול: "אין זה מתקבל על הדעת, כי סמכויות סטטוטוריות יוענקו לאדם פרטי, שאיננו משרת במערכת שכוננה על פי דין... דומה הדבר לכך, לו הוענקו סמכויות של שוטר לידי מי שאיננו חלק מחיל המשטרה".
- **תנו לחיות לחיות נ' מנהל השירותים הווטרינריים (בג"ץ 4884/00):** חברה פרטית ("מגן לחתול") הוסמכה לבצע המתת חתולים, עם חלק דומיננטי בהחלטות מהותיות. "תפקידה של החברה אינו

טכני, אלא הוענק לה תפקיד מובהק של שיקול דעת... **ככלל, סמכות שלטונית אינה ניתנת לאצילה לגורמים פרטיים**, אלא בנסיבות מיוחדות." העתירה התקבלה.

6.8 האם הלכת מיכלין עוד קיימת?

חמשת הסייגים:

1. מותר **להתייעץ** — ובלבד שהפקיד מכיר את העובדות ולא רק את "השורה התחתונה" (ניימן);
2. מותר להתייעץ עם הממונים ו**לאמץ** את מדיניותם (ארגוני הקבלנים; הרוקחים);
3. מותר לפעול לפי **הנחיות פנימיות**;
4. מותר לשר **ליטול** את הסמכות (ס' 34);
5. מותר **לאצול** (בהסמכה מפורשת או משתמעת) ולהסתייע.

המסקנה: עקרונית — ההלכה קיימת; אבל קשה מאוד להוכיח הפרה (הפקיד יטען שהתייעץ ואימץ אחרי בחינה); יש לה חריגים משמעותיים; והביקורת עליה חלחלה לפסיקה.

חורב נ' שר התחבורה (בג"ץ 5016/96) — השופט חשין (אמרת אגב): המפקח הארצי על התעבורה כתב ב-1994 ש"לא יעלה על הדעת" לסגור את רחוב בר-אילן בירושלים בשבת — עורק תנועה ראשי. ב-1996, אחרי שיחות עם שר התחבורה (שבחר שלא ליטול את סמכותו), שינה את דעתו מקצה לקצה והורה לסגור בזמני התפילה. חשין: "על הילכת עצמאותה של הרשות המוסמכת... ניתכה ביקורת מכל עבר... נשתכנעתי סופית כי יש וראוי להפוך על פיה את הילכת ה'עצמאות'... **מקום ששר רשאי ומוסמך ליטול סמכותה של רשות מוסמכת, רשאי ומוסמך הוא להורות אותה רשות מה תחליט ומה תעשה**. ביקורתו של בית המשפט תהיה לגופה של ההחלטה ולא לגופו של המחליט." שאר השופטים לא הצטרפו — ההצעה לא הפכה להלכה, אך היא מבטאת את הספקות.

6.9 מלכודות נפוצות

! שים לב — מלכודות נפוצות

- לחשוב שהלכת מיכלין בוטלה — היא קיימת, עם סייגים רבים.
- לחשוב שיש חזקה שפקיד שהחליט כמו השר לא הפעיל שיקול דעת — אין חזקה (ארגוני הקבלנים, הרוקחים).
- לבלבל בין ניימן (מסקנה עובדתית: לא ראו נתונים) לבין חזקה.
- לשכוח את ארבעת התנאים לנטילת סמכות (בפרט: עובד מדינה; לא שיפוטית).
- לחשוב שאצילה מחייבת תמיד הסמכה מפורשת — אפשר גם משתמעת; והסתייעות — מותרת בחזקה.
- לחשוב שאפשר לאצול סמכות שלטונית לגורם פרטי — ככלל לא.

6.10 שלד לפתרון שאלה — מי החליט באמת?

1. **מי בעל הסמכות בחוק?** זהו את הגורם שהחוק נותן לו את הסמכות (פקיד, ועדה, רשות עצמאית).
2. **מי עיצב את ההחלטה בפועל?** שר, ממונה, יועץ, הנחיה פנימית, או גורם חיצוני.
3. **האם זו התייעצות או הכתבה?** התייעצות והסתייעות מותרות; החלטה סופית חייבת להיות פרי "העיון העצמי" של בעל הסמכות (ניימן). אימוץ מדיניות אחרי בחינה עצמאית מותר (הרוקחים).
4. **האם יש הנחיה?** הנחיה גמישה: סטייה ממנה אפשרית, אך מחייבת נימוקים חזקים (סיעת למען התורה); מדיניות נוקשה "תהיינה הנסיבות אשר תהיינה" – כבילת שיקול דעת (חפציבה).
5. **האם נעשתה נטילה, העברה או האצלה?** נטילה – ס' 34 (ארבעה תנאים); העברה – מחייבת הסמכה מפורשת; אצילה – חזקה שאסורה אלא אם הותרה; לגורם פרטי – רק בנסיבות מיוחדות.

6.11 מלכודות בפתרון שאלות — טבלה

הטעות	למה היא שגויה	התיקון
"כל התייעצות פוסלת את ההחלטה"	התייעצות מותרת; הפגם הוא כשהממונה מכתיב ולא נשאר שיקול דעת עצמאי	לבדוק אם נשמרה ההחלטה הסופית

להחיל את מיכלין בלי להזכיר סייגים	יש חמישה סייגים: התייעצות, אימוץ, הנחיות, נטילה, אצילה	לציין את הסייג הרלוונטי
לטעון שהנחיה מחייבת מוחלט	חפציבה: מדיניות נוקשה היא כבילה של שיקול דעת	לדרוש גמישות וסטייה מנומקת
להפעיל ס' 34 על תאגיד סטטוטורי	הנגיד אינו עובד מדינה – אי אפשר ליטול ממנו סמכות	לבדוק את ארבעת התנאים
לבלבל העברה והאצלה	בהעברה הקשר מתנתק; באצילה המאציל נשאר ויכול לבטל ולהנחות	להבחין לפי הקשר הנמשך

6.12 תרגיל פתור — ועדה שקיבלה "שורה תחתונה"

✎ דוגמה — החלטה שהתקבלה על סמך המלצה

העובדות: ועדה מקצועית מוסמכת להחליט על אישור הקמת מפעל. יועץ ביטחוני העביר לה מסקנה: "להימנע מאישור". הוא לא מסר נתונים. הוועדה אימצה את המסקנה בלי לעיין בתשתית, ושר שהיה בפגישה הביע תמיכה בשלילה. היזם עתר.

הפתרון:

1. **הכלל:** בעל הסמכות חייב להפעיל שיקול דעת עצמאי ולהחליט על סמך עיון עצמי (ניימן).
2. **יישום:** קבלת "שורה תחתונה" בלי נתונים אינה הפעלת שיקול דעת. התייעצות מותרת, אך ההחלטה הסופית צריכה להיות של הוועדה.
3. **הסתייגות:** אילו הוועדה הייתה בוחנת את החומר ומאמצת בעצמה את מסקנת היועץ, או את עמדת השר, ההחלטה הייתה כשרה (המרכז, הרוקחים).
4. **מסקנה:** ההחלטה בטלה; הוועדה תחליט מחדש בעצמה.

6.13 סיכום הפרק

✔ שורה תחתונה — סיכום הפרק

- שלושה עקרונות משנה: איסור כבילת שיקול דעת, איסור דעה מוקדמת (סגורה), חובה להפעיל שיקול דעת עצמאי.
- מיכלין: כשהשר והפקיד המוסמך חלוקים – מכריע הפקיד; החלטה לפי הוראת השר בלבד – בטלה.
- סייגים: התייעצות מותרת; אימוץ מדיניות אחרי בחינה; הנחיות גמישות; נטילה לפי ס' 34; אצילה לפי ס' 33.
- נטילה (ס' 34): שר ממונה, עובד מדינה, לא סמכות שיפוטית, ואין כוונה אחרת בחוק.
- אצילה: חזקה שאסורה אלא אם הותרה; הסתייעות מותרת; אצילה לגורם פרטי רק בנסיבות מיוחדות.

6.14 מילון מושגים

- **כבילת שיקול הדעת** — התחייבות מראש לתוצאה.
- **התייעצות סטטוטורית / וולונטרית** — חובה לפי חוק / מרצון.
- **הנחיה מנהלית** — כלל גמיש שהרשות קובעת לעצמה.
- **נטילת סמכות** — שר נוטל לעצמו סמכות של עובד מדינה (ס' 34).
- **האצלה** — הסמכת אחר תוך שמירת הקשר; **העברה** — ניתוק הקשר; **הסתייעות** — עזרה טכנית.
- **אצילה אנכית / אופקית** — לכפוף / למי שאינו כפוף.

6.15 נקודות מפתח למבחן

✔ **שורה תחתונה — עיקרי הפרק**

- שלושה עקרונות משנה: איסור כבילה, איסור דעה מוקדמת, שיקול דעת עצמאי.
- מיכלין: רציו (הפקיד קובע) ואוביטר (החלטה לפי השר — בטלה).
- ארגוני הקבלנים (אוביטר — הלכה; אין חזקה); ניימן ("העיון העצמי"); הרוקחים (אימוץ מדיניות).
- הנחיות: חפציבה (גמישות — לא מחייבות לחלוטין); צפת (סטייה — נימוקים חזקים במיוחד); חופש המידע ס' 6(א).
- נטילת סמכות — ס' 34, ארבעה תנאים.
- העברה / האצלה / הסתייעות; ס' 33; פיליפוביץ; אנכית מול אופקית; הנפלינג ותנו לחיות לחיות (לא לגורם פרטי).
- חמשת הסייגים; חשין בחורב.

6.16 שאלות בסגנון המבחן

✎ דוגמה — שאלה בסגנון המבחן (1)

החוק מסמיך את "המפקח על הרישוי" להחליט על בקשות לרישיון. לפני שהחליט, נפגש המפקח עם השר, שהביע את עמדתו. המפקח בחן את החומר, השתכנע ופעל כעמדת השר. איזו קביעה **נכונה**?

א. ההחלטה בטלה — חזקה שפעל לפי השר. ב. ההחלטה תקפה — מותר להתייעץ עם הממונה ולאמץ את מדיניותו, ובלבד שההחלטה הסופית מבוססת על שיקול דעתו. ג. ההחלטה תקפה רק אם השר נטל את הסמכות. ד. ההחלטה בטלה, כי אסור להיפגש עם השר.

התשובה וההסבר

ב. ארגוני הקבלנים והרוקחים — האוביטר של מיכלין הוא הלכה, אבל אין חזקה. א' שגויה.

✎ דוגמה — שאלה בסגנון המבחן (2)

שר הפנים, הממונה על ביצוע חוק מסוים, מבקש ליטול סמכות שהחוק נתן לוועדת ערר להכריע בעררים של אזרחים. מה הדין?

א. מותר — הוא השר הממונה. ב. אסור — ס' 34 אינו חל על סמכות בעלת אופי שיפוטי. ג. מותר לתקופה מסוימת בלבד. ד. מותר רק באישור הממשלה.

התשובה וההסבר

ב. אחד מארבעת התנאים: אין ליטול סמכות מעין-שיפוטית.

6.17 שאלות לחשיבה

1. האם הלכת מיכלין טובה לדמוקרטיה?

תשובה אפשרית: בעד — מגינה על מקצועיות ומונעת לחצים פוליטיים, וממשת את בחירת המחוקק. נגד — "אין אחריות בלי סמכות": הציבור מטיל אחריות על השר, ועליו להיות מסוגל להכתיב מדיניות. ההצעה של חשין בחורב מבקשת פשרה: לבחון את ההחלטה עצמה, לא את מי שקיבל אותה.

2. למה בית המשפט חושש מאצילה לגורמים פרטיים?

תשובה אפשרית: הגורם הפרטי אינו כפוף למרות השלטון, אינו חב בחובות עובד ציבור, ואין עליו פיקוח מוסדי — ולכן הוא עלול להפעיל כוח שלטוני בלי אחריות. ההבחנה בין הסתייעות טכנית לשיקול דעת מאפשרת שימוש בשירותים פרטיים בלי למסור את הכוח עצמו.

פרק 7

התשתית העובדתית — הלכת יורונט והראיה המנהלית

7.1 מבוא — למה זה חשוב ומה מקומו בתמונה הגדולה

כל החלטה מנהלית, גם הקטנה ביותר, נשענת על **עובדות**. רשות שמחליטה "לפי תחושת בטן", על סמך שמועות, על נתונים ישנים או על מידע שאינו אמין — פועלת שלא כדין, גם אם יש לה סמכות והיא שוקלת שיקולים ענייניים. בפרק נלמד את חובת הרשות **לבסס תשתית עובדתית**: מקורה, ארבעת התנאים שלה (איסוף, רלוונטיות, אמינות ומוצקות), ומבחן **הראיה המנהלית** — איזה מידע מותר לרשות להסתמך עליו, ומדוע הוא שונה מכללי הראיות בבית משפט. זו עילה פרוצדורלית, שמשמשת לעיתים קרובות כבסיס גם לעילות אחרות (סבירות, מידתיות, הנמקה).

7.2 למה חובה? — שלטון החוק ונאמנות

- **שלטון החוק:** רשות אינה רשאית לפעול בשרירות; כל פעולה צריכה בסיס עובדתי.
- **חובת הנאמנות** (פרק 2): הנאמן חייב לקבל את ההחלטה הטובה ביותר עבור הציבור — ובלי עובדות אי אפשר.
- **הקשר לחובת ההנמקה:** אי אפשר לנמק החלטה שאין לה בסיס; הנימוקים נשאבים מהעובדות (פרק 8).
- **"בעיית הנציג" בגרסת המידע:** לרשות המבצעת מידע רב לאין פרק מאשר לכנסת ולציבור; החובה לבסס תשתית ולחשוף אותה (בהנמקה, בעיון) מצמצמת את הפער.

כבר **בז'רנו (1949)** נאמר: "**אין יורדין לחייו של אדם ואין מקפחין פרנסתו של אדם על יסוד שמועות בלבד**".

7.3 הלכת יורונט (בג"ץ 987/94 יורונט קווי זהב נ' שרת התקשורת)

⚖ פסק דין — עובדות והכרעה

הרקע: משרד התקשורת נדרש להסדיר תחום שירותי שיחות שעורר תלונות, וקבע קריטריונים. היו דרכים רבות להתמודד עם הבעיה; המשרד בחר בדרך ה**קלה עבורו** — זו שכבר מראש הזהירו מפניה, ואף שהיו חלופות טובות ופחות פוגעניות.

ההכרעה: בית המשפט הבין את המטרה, אבל קבע שהרשות לא ביצעה **עבודת מטה** ולא גיבשה **תשתית עובדתית** אמינה לפני שקבעה את הקריטריונים; אילו עשתה זאת — הייתה מגיעה לחלופות טובות יותר. הפגיעה בחופש העיסוק הייתה קשה ("פגיעה קשה מאוד, אם לא פגיעה אנושה"), ולא מידתית (פרק 12).

הסעד: בית המשפט אינו מחליט במקום הרשות — הוא אינו הגורם המוסמך — אלא **מחזיר את העניין לרשות** כדי שתבצע עבודת מטה ותחליט מחדש. (הקושי המעשי: רשות שנדרשת לבחון מחדש נוטה לא פעם להגיע לאותה תוצאה.)

7.4 ארבעת התנאים לתשתית עובדתית (זמיר)

#	התנאי	תוכן	דוגמאות מהפסיקה
1	**איסוף הנתונים**	לאסוף את המידע הדרוש — מילוי טפסים, איסוף אקטיבי, עבודת מטה, חוות דעת מומחים; לפעמים לפנות לרשות אחרת	מונא; מוניות הדרים; ברגר
2	**רלוונטיות**	להפריד בין נתונים שנוגעים לעניין לבין כאלה שאינם — מתחבר לאיסור השיקול הזר (פרק 10)	סקאפי
3	**אמינות**	מידע מהימן, בלי חשש להטיה או זיוף — מבחן "הראיה המנהלית"; רלוונטי במיוחד בעידן של חדשות כזב ובינה מלאכותית	לנסקי; מלבסקי; דותי; אייזנברג

4	**מוצקות**	מכלול רחב דיו כדי להסתמך עליו; ככל שההחלטה חשובה ופוגענית יותר — נדרשת תשתית מוצקה יותר	שללם; ג'ועמיס; ניימן; מוסטקי

7.5 איסוף נתונים — יישומים

- **מונא נ' שר הפנים:** אפשר — ולעיתים **חובה** — להסתמך על נתוני רשות אחרת (למשל המוסד לביטוח לאומי) בקביעת "מרכז חיים".
- **מוניות הדרים נ' שר התחבורה:** בית המשפט חייב את המפקח על התעבורה להתחשב בנתוני הרשויות המקומיות על מחסור בתחבורה ציבורית.
- **ברגר נ' שר הפנים (שעון הקיץ):** השר אינו יוצא ידי חובתו אם הוא **דוחה חוות דעת חדשות** ומסתמך על חוות דעת מלפני שלושים שנה.
- **היועמ"ש נ' ועדת השחרורים:** החלטה לא תסתמך על נתונים **מוקדמים מדי** — צריך מידע עדכני לזמן ההחלטה.

7.6 רלוונטיות

סקאפי נ' מפקד כוחות צה"ל ביהודה ושומרון: מחלוקת על התשתית העובדתית — הרוב (השופטים עמית וסולברג) סברו שהתשתית מספקת; המיעוט — שהיא פגומה, בהיעדר דו"ח משטרה על כך שהאירוע (דריסה) היה על רקע לאומני. הלקח: הנתונים צריכים להוכיח את **מה שההחלטה נשענת עליו**.

מוסטקי נ' פרקליטות המדינה: ההחלטה לא תהיה גורפת אלא **פרטנית**; כשנבדקה אפשרות שתואר אקדמי זויף — יש לבדוק את הראיות לגבי כל מקרה, מתוך פתיחות.

7.7 אמינות — מבחן הראיה המנהלית

רשות מנהלית **אינה בית משפט**, ואינה כפופה לדיני הראיות הפורמליים. אבל היא אינה רשאית להסתמך על כל דבר. המבחן: **"ראיה מנהלית"** — ראיה ש**אדם סביר** (רשות סבירה) היה רואה בה ערך הוכחתי ו**היה סומך עליה** בנסיבות העניין.

פסק הדין	הקביעה

לנסקי נ' שר הפנים (בג"ץ 442/71)	בשונה מהדין הפלילי, רשות רשאית להסתמך על **עדות שמיעה**, אם היא אמינה דיה לאדם סביר
מלבסקי דותי	אושר ביטול אזרחות על סמך **דו"ח מודיעיני סודי** שבו השתמש שר הפנים
	תשתית הנתונים לא עמדה בדרישות: סירוב לתת אזרחות מחשש שהמבקשת מחזיקה קטינה שלא כדין — בלי מסמכים מוכיחים
אייזנברג נ' שר הבינוי והשיכון (בג"ץ 6163/92)	במינוי מנכ"ל למשרד השיכון — יש ראיות מנהליות על עבר פלילי חמור של המועמד, שעל הרשות לשקול **גם אם ניתנה לו חנינה**; המינוי בוטל

7.8 מוצקות — "ככל שההחלטה חמורה יותר"

ככל שההחלטה פוגעת יותר בזכויות — נדרשות ראיות **חזקות, ברורות וחד-משמעיות** יותר:

- **שללם נ' פקיד רישוי כלי ירייה: שלילת רישיון קיים** מחייבת תשתית עובדתית מעמיקה, חזקה ועדכנית — לא עבירות אלימות קלות מהעבר.
- **ג'ועמיס נ' שר הפנים (מועצת זרזיר):** ביטול החלטה של שר קודם, שיצרה ציפיות, מחייב תשתית **איתנה** — לא שמועות; ונסיבות נוספות מחמירות את הרף כשנפגעות זכויות יסוד.
- **ניימן נ' יו"ר ועדת הבחירות:** לפסילת רשימה נדרשות ראיות "**ברורות, חד-משמעיות ומשכנעות**".
- **מוסטקי:** ביטול הכרה אקדמית (פגיעה בקניין של בעל התואר) מחייב ראיות קונקרטיות.

מנגד — רף נמוך יותר:

- **בן שלמה נ' מנהל מע"מ ירושלים: שומת מס** אפשר לבסס, מעצם הגדרתה, על **אומדנים והשערות**.
- **גונזלס נ' משרד הפנים:** יש להתחשב בקשיים הראייתיים של **מבקש מקלט**; לא כל סתירה מצדיקה דחייה.

7.9 תשתית עובדתית ועילות אחרות

עילה	הקשר
חובת הנמקה	אין נימוק בלי עובדות
שיקולים זרים	התנאי השני (רלוונטיות) — סינון שיקולים שאינם שייכים

סבירות	אי אפשר לאזן נכון בין שיקולים בלי לדעת את העובדות (דפי זהב)
מידתיות	יורונט — היעדר בחינת חלופות הוביל לאמצעי פוגעני מהנדרש

7.10 מלכודות נפוצות

! שים לב — מלכודות נפוצות

- לחשוב שרשות כפופה לכללי הראיות הפליליים — מבחן הראיה המנהלית גמיש יותר (לנסקי — עדות שמיעה).
- לחשוב שכל ראיה מספיקה — הרף עולה עם חומרת הפגיעה (שללם, ניימן).
- לחשוב שבית המשפט מחליט במקום הרשות כשהתשתית חסרה — הוא מחזיר אליה (יורונט).
- להתעלם מנתונים חדשים או להסתמך על ישנים (ברגר; ועדת השחרורים).

7.11 שלד לפתרון שאלה — בחינת התשתית העובדתית

1. **מהי ההחלטה ומה חומרת הפגיעה?** ככל שהפגיעה בזכויות חמורה יותר (שלילת רישיון קיים, ביטול אזרחות), הרף עולה.
2. **מה היו הנתונים בפני הרשות?** מי אסף אותם, מתי, ומאיזה מקור (רשות אחרת, יועץ, שמועה).
3. **בדקו את ארבעת התנאים** – איסוף (הושלם?), רלוונטיות (קשורים לעניין?), אמינות (ראיה מנהלית?), מוצקות (די לפי החומרה?).
4. **האם נבחנו חלופות?** עבודת מטה (יורונט); אם לא – טענה גם למידתיות.
5. **הסעד** – בדרך כלל החזרה לרשות לגיבוש תשתית ולהחלטה מחדש; לא החלפת שיקול דעתה.

7.12 מלכודות בפתרון שאלות — טבלה

הטעות	למה היא שגויה	התיקון

להחיל על הרשות דיני ראיות פליליים	הרשות אינה בית משפט; מבחן הראיה המנהלית גמיש (לנסקי)	לבחון אם אדם סביר היה סומך על המידע
לחשוב שכל ראיה מספיקה	הרף עולה עם חומרת הפגיעה (שללם, ניימן)	להתאים את הרף לחומרה
לצפות שבית המשפט יחליט במקום הרשות	יורונט: הסעד הוא החזרה לרשות	לבקש החזרה לגיבוש תשתית
להתעלם ממועד הנתונים	ברגר ועדת השחרורים: נדרשים נתונים עדכניים	לבדוק את עדכניות המידע
לשכוח את החנינה כראיה	אייזנברג: ראיות על עבר חמור נשקלות גם אחרי חנינה	לשקול ראיות רלוונטיות גם אם הוענקה חנינה

7.13 תרגיל פתור — ביטול רישיון על סמך שמועה

✎ דוגמה — שלילת רישיון נשק

העובדות: פקיד רישוי כלי ירייה שלל רישיון נשק של אדם שהחזיק בו שנים רבות, על סמך תלונה אנונימית ועל עבירה קלה שביצע לפני כ-15 שנה. הוא לא שמע את האדם ולא בדק את התלונה.

הפתרון:

1. **חומרה:** שלילת רישיון קיים היא פגיעה משמעותית, ולכן נדרשת תשתית מעמיקה, חזקה ועדכנית (שללם).
2. **איסוף:** הפקיד לא בדק את התלונה ולא שמע את הפרט – איסוף חסר.
3. **אמינות:** תלונה אנונימית שלא נבדקה אינה "ראיה מנהלית" שאדם סביר היה סומך עליה לצורך שלילה כזו.
4. **מוצקות ועדכניות:** עבירה קלה ישנה אינה מספיקה.
5. **מסקנה:** התשתית פגומה; ההחלטה תבוטל והעניין יוחזר לפקיד לבדיקה מחודשת.

7.14 סיכום הפרק

✔ **שורה תחתונה — סיכום הפרק**

- כל החלטה מנהלית חייבת להישען על תשתית עובדתית; מקור החובה בשלטון החוק ובנאמנות (בז'רנו: לא על יסוד שמועות).
- יורונט: עבודת מטה ובחינת חלופות; הסעד – החזרה לרשות.
- ארבעה תנאים: איסוף, רלוונטיות, אמינות, מוצקות.
- ראיה מנהלית: מה שאדם סביר היה סומך עליו (לנסקי – עדות שמיעה; מלבסקי – מודיעין; אייזנברג – עבר פלילי).
- הרף עולה לפי חומרת הפגיעה (שללם, ג'ועמיס, ניימן, מוסטקי), ונמוך יותר בשומת מס ובמבקשי מקלט.

7.15 מילון מושגים

- **תשתית עובדתית** — הנתונים שעליהם נשענת ההחלטה.
- **עבודת מטה** — איסוף, ניתוח ובחינת חלופות לפני החלטה.
- **ראיה מנהלית** — ראיה שרשות סבירה הייתה סומכת עליה.
- **עדות שמיעה** — עדות על מה שאדם שמע מאחר.
- **מוצקות** — היקף ועוצמה של הנתונים, ביחס לחומרת ההחלטה.

7.16 נקודות מפתח למבחן

✔ שורה תחתונה — עיקרי הפרק

- מקור החובה: שלטון החוק, נאמנות; בז'רנו — "לא על יסוד שמועות".
- יורונט: עבודת מטה; חלופות; החזרה לרשות.
- ארבעה תנאים: איסוף, רלוונטיות, אמינות, מוצקות.
- ראיה מנהלית: לנסקי (עדות שמיעה), מלבסקי (מודיעין), אייזנברג (עבר פלילי אחרי חנינה), דותי (חסר).
- מוצקות לפי חומרה: שללם, ג'ועמיס, ניימן, מוסטקי; מנגד — שומת מס, מבקשי מקלט.

7.17 שאלות בסגנון המבחן

✎ דוגמה — שאלה בסגנון המבחן (1)

פקיד רישוי ביטל רישיון נשק קיים של אדם, על סמך עבירת אלימות קלה שביצע לפני 15 שנה ושמועה ששמע משכן. איזו טענה חזקה ביותר?

א. אין טענה — רשות אינה כפופה לדיני הראיות. ב. התשתית העובדתית אינה מוצקה דיה: שלילת רישיון קיים מחייבת תשתית חזקה, עדכנית ואמינה; שמועה ועבירה קלה ישנה אינן מספיקות. ג. טענת שיהוי. ד. טענה שהפקיד אינו מוסמך.

התשובה וההסבר

ב. שללם ובז'רנו. אמנם רשות אינה כפופה לדיני הראיות הפורמליים (א' חלקית נכונה), אבל המידע צריך להיות ראיה מנהלית, והרף עולה עם חומרת הפגיעה.

✎ דוגמה — שאלה בסגנון המבחן (2)

רשות הסתמכה על עדות שמיעה כדי לסרב לבקשת מעמד. מה הדין?

א. אסור לחלוטין — עדות שמיעה פסולה. ב. מותר, אם מדובר בראיה שרשות סבירה הייתה רואה בה ערך הוכחתי וסומכת עליה. ג. מותר רק בהסכמת המבקש. ד. מותר רק בשעת חירום.

התשובה וההסבר

ב. לנסקי — מבחן הראיה המנהלית.

7.18 שאלות לחשיבה

1. מדוע בית המשפט מחזיר את העניין לרשות ואינו מחליט בעצמו?

תשובה אפשרית: הפרדת הרשויות — הסמכות נתונה לרשות, והיא בעלת המומחיות והכלים לאסוף נתונים. בית המשפט בודק את חוקיות ההליך, לא מחליף את שיקול הדעת. החיסרון: הרשות עלולה להגיע לאותה תוצאה.

2. איך משפיעים חדשות כזב ובינה מלאכותית על חובת התשתית העובדתית?

תשובה אפשרית: קל יותר לזייף מסמכים, תמונות וקולות — ולכן הדרישה לאמינות ולבדיקה עצמאית מתחזקת. גם האזרח מתקשה לבדוק את נתוני הרשות. זה מחזק את חובות השקיפות והעיון.

פרק 8

כללי הצדק הטבעי — שימוע, ניגוד עניינים, הנמקה והיוועצות

8.1 מבוא — למה זה חשוב ומה מקומו בתמונה הגדולה

"לא מספיק שהצדק ייעשה — הוא צריך גם להיראות." כללי הצדק הטבעי הם ליבת הפרוצדורה המנהלית: לפני שהרשות פוגעת באדם — עליה **לשמוע אותו**; מי שמחליט — **אסור שיהיה במצב של ניגוד עניינים**; וכשהרשות מסרבת לבקשה — עליה **לנמק**. לצדם — **חובת ההיוועצות**, כשהחוק מחייב להתייעץ עם גוף מסוים לפני החלטה. בפרק נלמד מתי קמה כל חובה, מה היקפה, מהם החריגים, ומה המבחנים שקבעה הפסיקה. כל הכללים נגזרים מחובת הנאמנות (פרק 2), ועוצמתם משתנה לפי סוג הסמכות (פרק 5).

8.2 זכות הטיעון — חובת השימוע

מתי קמה? — "מבחן הפגיעה" (ברמן נ' שר הפנים, בג"ץ 3/58): מרגע שהרשות מבקשת **לפגוע** באזרח, והפגיעה **ישירה וממשית** — עליה לאפשר לו לטעון את טענותיו. (ברמן הרחיב את הזכות גם לסמכות ביצוע, ולא רק לסמכות מעין-שיפוטית.)

מה צורתה? אין מתכונת אחת: בכתב, בעל פה, בזום, פרטני או קבוצתי — לפי הנסיבות. אבל תמיד: **בלב פתוח ובנפש חפצה**. (יש חוקים מעטים שקובעים מתכונת מפורשת — למשל שימוע לפני הגשת כתב אישום בסדר הדין הפלילי.)

ענף	רכיב	תוכן
פסיבי	מסירת הודעה	הודעה על הפגיעה הצפויה או על הטענות — עם **כל המידע הרלוונטי** הנחוץ כדי לטעון עניינית (למעט מידע שחשיפתו פוגעת בביטחון, בסוד מסחרי או בצדדים שלישיים)
	בפני הגורם המוסמך	השימוע צריך להיות מול מי שמקבל את ההחלטה

אקטיבי	זמן סביר להזדמנות אפקטיבית	להתכונן; ככל שהפגיעה קשה יותר — יותר זמן שהפרט יוכל באמת לנסות לשכנע

עוצמה לפי סוג הסמכות: בהליך **מעין-שיפוטי** — זכות טיעון מוגברת: ייצוג בידי עורך דין, חקירה נגדית, עיון בטענות הצד שכנגד. (מפקח על המקרקעין שאומר לדייר "לכאן עורכי דין לא נכנסים" — פועל שלא כדין.)

8.3 חריגים לחובת השימוע

חריג	הסבר	דוגמה
סמכות מעין-חקיקה	תקנות מופנות לציבור רחב — שימוע לכל נפגע אינו יעיל	
ויתור מדעת	הרשות מסרה הודעה ונתנה זמן, והפרט ויתר	
אינטרס נוגד	בית המשפט ישקול	גירוש פעילי חמאס (1992) — חשש להתפרעויות וצורך מבצעי; הוכרה אפשרות של שימוע מאוחר בפני ועדות ערר
חשוב יותר		
דחיפות — "כורח השעה"	נבחנת **אובייקטיבית** — האם באמת אין זמן, או שהרשות עצמה גרמה לכך	**סרטי נוח נ' המועצה לביקורת סרטים (בג"ץ 549/75):** יום לפני הקרנת בכורה ביקשה המועצה לבטל היתר בלי שימוע — "אין זמן". נדחה: הרשות לא הייתה צריכה לחכות לדקה ה-90

דחיפות שכיחה כשהרשות נתנה היתר בטעות ורוצה לחזור בה, ובסמכויות חירום וביטחון (צווי הריסה וגירוש, פעולות מבצעיות).

שימוע מאוחר: שימוע מוקדם עדיף — ההחלטה עוד לא התקבלה. לעיתים שימוע מאוחר הוא "הרע במיעוטו"; אבל הוא עלול להיות חסר ערך כי ההחלטה כבר "סגורה". כשהרשות מקיימת שימוע מאוחר — **הנטל עליה** להוכיח שעשתה זאת בלב פתוח.

8.4 האיסור על ניגוד עניינים

אסור לעובד הציבור להימצא במצב שבו **קיימת אפשרות** לניגוד עניינים. הכלל חל על נבחרים ועל עובדים מקצועיים, בכל סוגי הסמכות, **בלי חריגים**. מטרתו **מניעתית** — "אל תביאוני לידי ניסיון": לא בודקים אם השיקולים בפועל היו פסולים, אלא אם היה **חשש**. הבדיקה **אובייקטיבית** — לא שואלים את עובד הציבור (הוא לא יודה בחולשתו).

סוג	ההתנגשות	המבחן	דוגמה
אישי	אינטרס ציבורי שהעובד אמון עליו מול אינטרס **אישי** (משפחתי, כלכלי)	**חשש סביר**	**מושלב נ' הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה:** תוכנית לקיבוץ כברי — לא נמצא שום פגם תכנוני, ובכל זאת ההחלטה נפסלה בשל חשש סביר לניגוד עניינים אישי
מוסדי	אינטרס שלטוני אחד מול אינטרס שלטוני אחר (שני "כובעים")	**אפשרות ממשית**	**סיעת הליכוד נ' עיריית פתח תקווה:** חבר מועצה שישב גם בוועדת ההנהלה (שמייעצת לראש העירייה) וגם בוועדת הביקורת (שמבקרת אותו) — קשה לבקר את עצמך

התוצאה לפי עוצמה: לא כל ניגוד עניינים פוסל. ככל שהאינטרסים קרובים יותר — העוצמה גבוהה יותר. בעוצמה נמוכה — **נטרול נקודתי** (הימנעות מישיבה מסוימת, האצלת חלק מהסמכויות, הסדר ניגוד עניינים). בעוצמה גבוהה שאי אפשר לנטרל — **ביטול** ההחלטה, או דרישה לבחור בין התפקידים.

קרוב — דעה מוקדמת: מלאך נ' לוי (פרק 5) — יו"ר ועדה שהתבטא בעד פרויקט לפני ששמע התנגדויות.

8.5 חובת ההנמקה

למה? הנמקה מחייבת חשיבה סדורה והגיונית; מובילה לביקורת עצמית; נשמרת בתיק ומאפשרת בקרה בדיעבד; מבטיחה אחידות ועקביות; ומאפשרת לנפגע לשקול אם ההחלטה עומדת בדין. מנגד — רשויות נוטות להימנע: טרחה, חשש מוויכוח וביקורת.

✦ **הגדרה — חוק לתיקון סדרי המינהל (החלטות והנמקות), התשי"ט–1958**

חוק לתיקון סדרי המינהל (החלטות והנמקות), התשי"ט–1958: נתבקש עובד ציבור **בכתב** להשתמש בסמכות שניתנה לו על פי דין — יחליט ויודיע למבקש בכתב בהקדם, ולא יאוחר מ-**45 ימים**; **סירב** — יודיע לו את **נימוקי הסירוב**.

- **תנאים:** (1) בקשה **בכתב** להפעלת סמכות; (2) החובה חלה כשהרשות **נתבקשה** — לא על פעולה מיוזמתה.
- **"סמכות על פי דין"** — כל מקורות המשפט: חקיקה, חקיקת משנה, משפט מקובל — כולל סמכויות ממשל כלליות. (**חולב:** המשטרה סירבה למסור לנחקר את זהות המודיע — גם סמכות חקירה כפופה לחוק.)
- **סירוב חלקי או מותנה** — עשוי להיחשב סירוב שמחייב הנמקה.
- **היקף ההנמקה** — לפי הנסיבות: עובדות ברורות ודין פשוט — הנמקה קצרה; מצב מורכב — מפורטת יותר.
- **גוף רב-חברים** — **שפירא נ' הוועד המחוזי של לשכת עורכי הדין:** הוועד גנז תלונה נגד עורך דין וסירב לנמק ("כל חבר מצביע מנימוקיו"). נקבע: חובה לנמק — גם כאן, ובמיוחד כאן, יש חשש לשיקולים פסולים.
- **פטור** — כשהנמקה עלולה לפגוע באינטרס חשוב, כמו ביטחון המדינה (ס' 7 לחוק).
- **התוצאה של אי-הנמקה:** ההחלטה אינה בטלה אוטומטית; אבל בכל הליך בעניינה — **הנטל על הרשות** להראות שפעלה כדין.

8.6 חובת ההיוועצות הסטטוטורית

כשהחוק מחייב להתייעץ עם גוף מסוים לפני החלטה (התייעצות **סטטוטורית**), אי-קיום ההתייעצות כהלכה הוא **פגם בהליך**. (התייעצות וולונטרית — עניין של עצמאות שיקול הדעת, פרק 6.)

רציונלים: לבעל הסמכות — "מרבה עצה, מרבה תבונה"; למייעץ — אפשרות להשפיע; לציבור — שיתוף, שקיפות ומנהל תקין.

איך? רוב החוקים מציינים עם מי להתייעץ, לא איך. **עזבה נ' מדינת ישראל:** אין נוקשות פרוצדורלית (טלפון, מייל, זום) — אבל היוועצות שהיא "**קליפה ריקה**" אינה מספיקה.

סוג	התנאי	הסבר
פורמלי	**מוקדמת**	לפני ההחלטה (**בוקובזה נ' שר החינוך:** התייעצות על תקציב לרשויות מקומיות שהתקיימה אחרי שנת הלימודים ואישור התקציב — פסולה)
פורמלי	**מלוא המידע וזמן סביר**	כל החומר הרלוונטי, ומהות ההחלטה הצפויה; זמן לפי מורכבות, היכרות המייעץ ולוחות זמנים — אבל לא "עד אין קץ"
פורמלי	**היכרות מוקדמת אינה פוטרת**	גם אם עמדת המייעץ ידועה — חובה להתייעץ (ולעיתים שוב, אם חלף זמן)
מהותי	**דו-צדדית**	לשמוע ולהשמיע, לשכנע ולהשתכנע — שיח אמיתי
מהותי	**לב פתוח ונפש חפצה**	בלי דעה קדומה, מתוך רצון כן לשמוע (קשה להוכחה)

המכון לארכיאולוגיה נ' שר החינוך (בג"ץ 512/81) — עיר דוד: חפירות בעיר דוד עוררו התנגדות של גורמים חרדיים (קברים עתיקים), עד כדי איומים. חוק העתיקות התיר לשר להתלות רישיון חפירה **אחרי התייעצות** עם המועצה הארכיאולוגית. השר כינס אותה **מהיום למחר** (החוק קבע 7 ימים), הציג רק את טענת הקברים, והמועצה המליצה להמשיך — והשר הורה להפסיק. שלושה פגמים: **זמן**; **מידע חלקי**; והשר "גמר בדעתו" מראש, תחת לחצים — לא בלב פתוח. ההיוועצות לא קוימה כהלכה; החפירות הותרו.

משקל עמדת המייעץ: ככלל — ההחלטה של בעל הסמכות. אבל כדי שההיוועצות לא תהפוך לטקס:

- **אשקר נ' משיח (1992):** סטאז'ר שלמד ברומניה נכשל בהערכות, חזר על חלק מהסטאז' — וגורמי ההכשרה והוועדה המייעצת המליצו לתת לו רישיון. המנהל דרש שלושה חודשים נוספים. בית המשפט: **הנטייה** תהיה לקבל את עמדת הגוף המייעץ; אפשר לסטות, אבל **"לא על דרך הסתם"** — רק בנימוקים מבוססים ועניינים; וככל שהמייעץ **מומחה** יותר — משקלו רב יותר. הנימוקים לא התקבלו.
- **איגוד מכוני הרישוי בישראל נ' שרת התחבורה (2024):** השרה סטתה מהמלצת ועדת המחירים לעדכון מחירי מבחני רישוי, בנימוקים כלליים (עדכון עתידי, יוקר המחיה). העתירה התקבלה — הנימוקים לא מבוססים מול מומחיות הוועדה.

8.7 מלכודות נפוצות

! שים לב — מלכודות נפוצות

- לחשוב שזכות הטיעון חלה רק בהליך מעין-שיפוטי — ברמן הרחיב.
- לקבל "דחיפות" שהרשות יצרה בעצמה — סרטי נוח.
- לבלבל בין מבחני ניגוד העניינים: אישי — חשש סביר; מוסדי — אפשרות ממשית.
- לחשוב שחובת ההנמקה חלה על כל פעולה — רק על בקשה בכתב (לפי החוק).
- לחשוב שאי-הנמקה מבטלת את ההחלטה — הנטל עובר לרשות.
- לחשוב שמותר להתעלם מהגוף המייעץ — אפשר לסטות רק בנימוקים מבוססים.

8.8 שלד לפתרון שאלה — פרוצדורה של קבלת החלטה

1. **שימוע:** האם ההחלטה פוגעת באדם פגיעה ישירה וממשית (ברמן)? אם כן – האם ניתנה לו הודעה עם המידע ושמיעה בלב פתוח, ובאיזו מתכונת? בדקו חריגים: ויתור, דחיפות אובייקטיבית, מעין-חקיקה.
2. **ניגוד עניינים:** מי השתתף בהחלטה? האם יש חשש סביר (אישי) או אפשרות ממשית (מוסדי)? מהי עוצמת הניגוד ומהו הסעד המתאים?
3. **הנמקה:** האם הוגשה בקשה בכתב? האם נמסרה תשובה בזמן? האם הסירוב מנומק? יש חריגים (ביטחון).
4. **היוועצות סטטוטורית:** האם נקבעה בחוק? האם הייתה מוקדמת, עם מידע מלא וזמן סביר, ובלב פתוח? ואם הרשות סטתה מהמלצה – האם הסיבות מבוססות?
5. **הסעד:** שימוע מאוחר או היוועצות מתוקנת, או ביטול ההחלטה (פרק 14).

8.9 מלכודות בפתרון שאלות — טבלה

הטעות	למה היא שגויה	התיקון
לדרוש שימוע בכל מקרה	אין שימוע במעין-חקיקה, בדחיפות אובייקטיבית או בוויתור	לבדוק חריגים
לטעון דחיפות שהרשות יצרה	סרטי נוח: הדחיפות נבחנת אובייקטיבית	לבחון מי גרם לדחיפות
לדרוש הוכחת ניגוד עניינים בפועל	הכלל מניעתי: מספיק חשש סביר (אישי) או אפשרות ממשית (מוסדי)	להפעיל את המבחן המתאים
לבלבל הנמקה לפי החוק והנמקה כללית	החוק חל כשנתבקשה פעולה בכתב; חובות נוספות נובעות מהפסיקה	לבדוק מה הפעיל את החוק
לראות בהיוועצות פורמליות בלבד	"קליפה ריקה" אינה מקיימת את החובה; נדרשת היוועצות בלב פתוח	לבחון את מהות ההיוועצות

8.10 תרגיל פתור — חבר ועדה שהוא גם בעל קרקע

✎ דוגמה — ועדה מקומית ואינטרס אישי

העובדות: הוועדה המקומית לתכנון ובנייה אישרה שינוי ייעוד של קרקע. אחד מחברי הוועדה השתתף בדיון ובהצבעה, והתברר שקרוב משפחתו הוא בעל חלק מהקרקע. הוא לא הצהיר על כך. עותר מבקש לבטל את ההחלטה.

הפתרון:

1. **סוג הניגוד:** ניגוד עניינים אישי.
2. **המבחן:** חשש סביר, הנבחן אובייקטיבית וללא צורך בהוכחה שהחבר השפיע בפועל (מושלב).
3. **יישום:** קרבה משפחתית לבעל הקרקע יוצרת חשש סביר; חבר ועדה צריך להימנע מהדיון.
4. **עוצמה:** אם הניגוד חמור והחבר היה משפיע, ההחלטה תבוטל; אם נקודתי, ייתכן שמספיק נטרול ודיון חוזר בלעדיו.
5. **מסקנה:** עתירה תתקבל; הוועדה תדון בעניין מחדש בלי החבר.

8.11 סיכום הפרק

✔ שורה תחתונה — סיכום הפרק

- שימוע: קם בפגיעה ישירה וממשית (ברמן); מתכונת גמישה; חריגים – ויתור, דחיפות אובייקטיבית (סרטי נוח), מעין-חקיקה; בשימוע מאוחר הנטל על הרשות.
- ניגוד עניינים: מניעתי; אישי – חשש סביר (מושלב); מוסדי – אפשרות ממשית (פתח תקווה); הסעד לפי עוצמה.
- הנמקה: חוק 1958 – בקשה בכתב, תשובה בהקדם ובמגבלת 45 ימים, סירוב מנומק; חריגים לביטחון; גם גופים רב-חברים (שפירא).
- היוועצות: מוקדמת, מידע מלא, זמן סביר, בלב פתוח (עיר דוד, בוקובזה); סטייה מהמלצה רק בנימוקים מבוססים (אשקר, מכוני הרישוי).
- כל הכללים נגזרים מחובת הנאמנות.

8.12 מילון מושגים

- **שימוע** — הזדמנות לטעון לפני החלטה פוגענית.
- **מבחן הפגיעה** — פגיעה ישירה וממשית מחייבת שימוע.
- **שימוע מאוחר** — שמיעה אחרי ההחלטה; הנטל על הרשות.
- **ניגוד עניינים אישי / מוסדי** — אינטרס פרטי / שני תפקידים ציבוריים.
- **הסדר ניגוד עניינים** — נטרול נקודתי.
- **היוועצות סטטוטורית** — חובה לפי החוק.
- **"קליפה ריקה"** — היוועצות למראית עין.

8.13 נקודות מפתח למבחן

✔ שורה תחתונה — עיקרי הפרק

- שימוע: ברמן — מבחן הפגיעה; ענף פסיבי (הודעה, גורם מוסמך) ואקטיבי (זמן, הזדמנות); מוגבר במעין-שפיטה.
- חריגים: מעין-חקיקה, ויתור, אינטרס נוגד, דחיפות (סרטי נוח); שימוע מאוחר — הנטל על הרשות.
- ניגוד עניינים: מניעתי, אובייקטיבי; אישי — חשש סביר (מושלב); מוסדי — אפשרות ממשית (פתח תקווה); נטרול לפי עוצמה.
- הנמקה: חוק 1958 — בקשה בכתב, 45 יום, נימוקי סירוב; שפירא; פטור ביטחוני; הנטל עובר.
- היוועצות: פורמלי (מוקדמת, מידע וזמן) ומהותי (דו-צדדית, לב פתוח); עיר דוד; אשקר ("לא על דרך הסתם"); מכוני הרישוי.

8.14 שאלות בסגנון המבחן

✎ דוגמה — שאלה בסגנון המבחן (1)

רשות החליטה לבטל רישיון עסק יומיים לפני אירוע גדול שתוכנן מזה חודשים, בלי שימוע, בטענת דחיפות — אף שידעה על הבעיה כבר חודש. מה הדין?

א. ההחלטה כדין — יש דחיפות. ב. ההחלטה פגומה — הדחיפות נבחנת אובייקטיבית, והרשות עצמה גרמה לה. ג. ההחלטה כדין כי מדובר בסמכות מעין-חקיקה. ד. אין חובת שימוע בביטול רישיון.

התשובה וההסבר

ב. סרטי נוח — לא היה צורך לחכות לדקה ה-90. ג' שגויה: ביטול רישיון פרטני הוא ביצוע. ד' שגויה לפי מבחן הפגיעה.

✎ דוגמה — שאלה בסגנון המבחן (2)

חבר ועדה עירונית שאחיו מחזיק בקרקע הגובלת בתוכנית השתתף בהצבעה על אישורה. התוכנית עצמה תקינה מבחינה תכנונית. מה הדין?

א. ההחלטה תקפה — אין פגם תכנוני. ב. ההחלטה עלולה להיפסל — מבחן ניגוד עניינים אישי הוא חשש סביר, אובייקטיבי, ואינו בודק אם השיקולים בפועל היו פסולים. ג. נדרשת הוכחה שהחבר פעל לטובת אחיו. ד. מבחן אפשרות ממשית חל כאן.

התשובה וההסבר

ב. מושלב — ההחלטה נפסלה אף שלא היה פגם תכנוני. ד' — זה המבחן לניגוד מוסדי.

8.15 שאלות לחשיבה

1. למה ניגוד עניינים נבחן לפי "חשש" ולא לפי מה שקרה בפועל?

תשובה אפשרית: כי אי אפשר לדעת מה עבר בראשו של מקבל ההחלטה, והוא לא יודה בכך; וכי אמון הציבור נפגע עצם מהמראית. הכלל מניעתי — כדי לא להעמיד את עובד הציבור בניסיון.

2. מה ההבדל בין זכות טיעון לבין היוועצות?

תשובה אפשרית: זכות טיעון ניתנת לנפגע — לשמוע אותו לפני פגיעה. היוועצות היא חובה כלפי גוף שהחוק הועיד לו תפקיד מייעץ — לשפר את ההחלטה ולשתף. שתיהן דורשות "לב פתוח", ושתיהן לא יהיו "קליפה ריקה".

פרק 9

פרסום תקנות והוראות מנהל ותחילת תוקף

9.1 מבוא — למה זה חשוב ומה מקומו בתמונה הגדולה

"אין חוקי סתר במדינה דמוקרטית." אם רוצים שאדם ינהג לפי הנורמה — הנורמה חייבת להיות **גלויה**. חוק עובר שלוש קריאות ומתפרסם ברשומות; אבל רוב הנורמות שמסדירות את חיינו הן **חקיקת משנה** והוראות של הרשות המבצעת. בפרק נלמד: אילו נורמות חייבות פרסום ברשומות (מבחן **"תקנה בת-פועל תחיקתי"**), מה החריגים, מה קורה כשלא פרסמו, מתי תקנה נכנסת לתוקף ומתי מותר להחילה למפרע, ומה דינן של **הנחיות מנהליות** — ולבסוף את **חוק חופש המידע**, שהפך את השקיפות לזכות.

9.2 חובת הפרסום ברשומות

§ סעיף — 17 לפקודת הפרשנות

(ההוראה הקלאסית שהפסיקה פירשה): "תקנה בת-פועל תחיקתי תפורסם ברשומות, ותחילת תוקפה ביום פרסומה, אם אין הוראה אחרת בעניין זה."

כלומר — מכל חקיקת המשנה, חובת פרסום ברשומות חלה על **תקנה בת-פועל תחיקתי**, משום שבמאפייניה היא דומה לחוק.

★ טיפ למבחן — מה לעשות במבחן

אל תחפשו רק את המילה "תקנה". גם "צו", "הוראה" או "הודעה" **מכוח חוק** עשויים להיות תקנה בת-פועל תחיקתי.

9.3 מבחן "תקנה בת-פועל תחיקתי" — אלכסנדרוביץ' (ע"פ 213/56)

סממן	תוכן
1. כלליות	נורמה **כללית ומופשטת** — מופנית לציבור כולו או לחלק בלתי מסוים ממנו; לא "שמית" — לא לאדם או לאנשים הנקובים בשמם
2. נורמטיביות	קובעת **נורמה משפטית חדשה** ובכך משנה את המשפט הנוהג

שני הסממנים **מצטברים**. (אותו מבחן שימש בהורנשטיין לסיווג סמכות מעין-חקיקה — פרק 5.) ומה אינה תקנה כזו? "תקנה אשר אין בה כל נורמה, או שיש בה נורמה... שהופנתה באורח קונקרטי לאדם מסוים הנקרא בשמו".

⚖ פסק דין — עובדות והכרעה

העובדות: צו מכוח חוק מס קנייה חייב סוחרי רהיטים לסמן סחורה בבולים ולשלם מס. אלכסנדרוביץ', סוחר רהיטים, קיבל מכתב — וזרק אותו. הוגש נגדו כתב אישום. טענת ההגנה — **מנהלית**: הצו הוא תקנה בת-פועל תחיקתי, ולא פורסם. **בית המשפט:** צו מכוח חוק — "תקנה"; מופנה לכל סוחרי הרהיטים — **כללי**; קובע חובה חדשה — **נורמטיבי**. לא פורסם — בטל, וכתב האישום בוטל.

הרציונל: אם רוצים שאדם ינהג על פי החוק — על החוק להיות גלוי. זה חשוב לשני הצדדים: הרשות יודעת את גבולות הגזרה, והפרט יכול לכלכל את צעדיו.

9.4 פטור מפרסום — מי רשאי לפטור?

מדינת ישראל נ' האז (ע"פ 421/61): הסיפא "אם אין הוראה אחרת" — על מה היא חלה? שתי קריאות:

1. על עצם **חובת הפרסום** — ואז מתקין התקנות יכול לפטור את עצמו (בעייתי);
2. רק על **מועד תחילת התוקף**.

בית המשפט אימץ את **השנייה**: תקנות בנות-פועל תחיקתי **חייבות** פרסום ברשומות, אלא אם **הכנסת** — בחוק — פטרה מכך. מחוקק המשנה **אינו רשאי** לפטור את עצמו. (העובדות: תעריפים של שירות הדואר פורסמו, אבל מנהל הדואר גבה בנוסף על שירותים נוספים לפי קביעה שלא פורסמה.) ואם הכנסת פוטרת — עליה לדאוג ל**פרסום חלופי אפקטיבי**; פטור לעולם אינו גורף — "אין חוקי סתר במדינת ישראל". דוגמה: חוק שירות ביטחון פוטר צווים מכוחו מפרסום ברשומות — ועדיין נדרש פרסום אחר. (גם הנחיות חקירה חסויות מובאות לפחות לידיעת ועדת החוץ והביטחון.)

נורמה מול נתון עובדתי — רונן נ' היועמ"ש (ע"פ 402/63): נהג עצר ליד תמרור "אין עצירה", וטען שהצבת התמרור היא תקנה שלא פורסמה. בית המשפט: **תוכן התמרור** (מה פירושו) — נורמה שחייבת פרסום; **הצבתו** במקום מסוים — **נתון עובדתי המפעיל את הנורמה**, ופטור מפרסום. התמרור עצמו הוא הפרסום.

9.5 מה קורה כשלא פרסמו?

תקופה	התוצאה
בעבר	אי-פרסום → **בטלות מוחלטת** (void), כמו כל פגם (אלכסנדרוביץ')
היום	**בטלות יחסית** — "לא כל חובות הפרסום נולדו שוות"

אזרזר נ' משרד האוצר (2023): הטבות המס לתושבי מיתר בוטלו, אבל הביטול **לא פורסם** ברשומות, ובמשך שנתיים אתר רשות המסים הציג את מיתר כיישוב מוטב. העותר עבר להתגורר במיתר בהסתמך על כך. בית המשפט: נפל פגם — אבל התוצאה נבחנת לפי **היקף הפגיעה בפרט** מול **האינטרס הציבורי**, וקיומו של פרסום אפקטיבי או חלופי. הפגיעה — לכל היותר — במי שהעתיקו את מגוריהם בהסתמך על המידע; עתירתו התקבלה. (ביקורת: הבטלות היחסית משדרת לרשות שגם פגם בפרסום "לא נורא", ולפרט נותרת רק תקווה.)

9.6 מועד תחילת התוקף

- **ברירת המחדל:** יום הפרסום ברשומות.
- **תחולה עתידית (פרוספקטיבית):** מותרת ואף **רצויה** — הליך התקנת תקנות אינו פומבי בדרך כלל, והציבור צריך זמן להתכונן. לעיתים בלתי אפשרית בשל דחיפות.

- **תחולה למפרע (רטרואקטיבית):** מותרת לפי לשון ההוראה — אבל בעייתית, וכפופה לביקורת (סבירות). זהירות מיוחדת כש**התקנה**:
  - קובעת **עבירה פלילית חדשה** (סותר את עקרונות חוק העונשין);
  - מטילה **תשלום חובה** על שירות שכבר ניתן או מצרך שכבר נרכש;
  - **שוללת הטבה** או פוגעת בזכויות.

9.7 פרסום הוראות מנהל והנחיות מנהליות

חוק הפרשנות, התשמ"א–1981 מגדיר "הוראת מינהל": "הוראה או מינוי, לרבות מודעה, הודעה, היתר או רישיון, שניתנו בכתב מכוח חיקוק ושאינם בני-פועל תחיקתי" — הפעילות השוטפת של הרשות (תוכניות, רישיונות). הן **אינן** חייבות פרסום ברשומות.

הנחיות פנימיות — האם הן "תקנה בת-פועל תחיקתי"? אפשר לטעון לכאן ולכאן (הן גמישות ואפשר לסטות מהן; הן מופנות פנימה — אבל מקרינות החוצה). בית המשפט קבע: **לא** — כדי לשמור על גמישותן (פרק 6).

אפרתי נ' אוסטפלד (בג"ץ 5537/91): לפי חוק העבירות המנהליות, בעבירות מסוימות "דרך המלך" היא **קנס מנהלי**, אבל התובע רשאי לבחור בכתב אישום. הפרקליטות קבעה הנחיות פנימיות מתי לבחור בכתב אישום — ולא פרסמה אותן. נגד אפרתי הוגש כתב אישום. בית המשפט: הנחיה פנימית אינה תקנה בת-פועל תחיקתי ואינה חייבת פרסום ברשומות — **אבל** הנחיות שהרשות פועלת לפיהן ויש להן חשיבות לציבור — **יש להביאן לידיעת הציבור**.

§ סעיף — 6(א) לחוק חופש המידע, התשנ"ח–1998

"רשות ציבורית תעמיד לעיון הציבור את ההנחיות המנהליות הכתובות שעל פיהן היא פועלת ושיש להן נגיעה או חשיבות לציבור".

הפרת החובה — **בטלות יחסית** (איזון בין הפגיעה בפרט לאינטרס הציבורי). כיום ההנחיות מפורסמות באתרי הרשויות (הנחיות היועמ"ש, חוזרי מנכ"ל).

9.8 פומביות ושקיפות — המסגרת

- **הכנסת** — "הכנסת תשב בפומבי" (חוק יסוד: הכנסת).
- **הממשלה** — "קובעת את סדרי ישיבותיה ועבודתה" (חוק יסוד: הממשלה); דיוניה וועדות השרים **אינם** פומביים, ויש הסדרי סודיות. לרוב מתפרסמת רק ההחלטה.
- **חובת פרסום ברשומות** — גם לגבי אצילה ונטילה של סמכויות.
- **שיתוף ציבור** — אין חובה כללית (למעט התנגדויות בתכנון ובנייה); מגמה גוברת ברשויות מקומיות ובמשרדי ממשלה ("ממשל פתוח"), עם אתגרי אמינות, אבטחה ונגישות.

9.9 חוק חופש המידע

סעיף	תוכן
1	"לכל אזרח ישראלי או תושב הזכות לקבל מידע מרשות ציבורית בהתאם להוראות חוק זה" — **בלי צורך להראות אינטרס**
3	חובת מינוי **ממונה על חופש המידע** בכל רשות (ועמדתו משפיעה מאוד על היישום)
5	דו"ח שנתי של הרשות על פעילותה, תפקידיה וסמכויותיה
6	פרסום הנחיות מנהליות וחוקי עזר
7	נוהל הגשת בקשות ולוחות זמנים
9–8	**חריגים** — מידע שאין למסור (ביטחון, פרטיות) או שאין חובה למסור (דיונים פנימיים, הקצאת משאבים בלתי סבירה, ועוד)
16	מידע על אדם עצמו שאינו נכון — זכות לבקש תיקון
17	**עתירה מנהלית** על אי-מסירת מידע

המועצה להשכלה גבוהה נ' הארץ (עע"מ 9135/03, 2006): המל"ג סירבה למסור מידע בטענה שהוא נוגע ל**דיונים פנימיים**. בית המשפט: אין די בכך — על הרשות להראות **טעם ממשי** לחיסוי ואפשרות לפגיעה. "**הזכות לקבלת מידע על פעילותן של רשויות ציבוריות היא מאבני היסוד של חברה חופשית**... היא משקפת את התפיסה שלפיה הרשות כנאמן הציבור... שקיפות... תורמת תרומה מכרעת ל'היגיינה הציבורית'." ועיקרון מרכזי: **חוק חופש המידע כפוף למשפט המנהלי** — גם כשיש לרשות עילת סירוב בחוק, עליה לשקול את הבקשה לפי כללי המשפט המנהלי (מידתיות, ענייניות, סבירות); אי אפשר "להסתתר מאחורי החריגים".

9.10 מלכודות נפוצות

! שים לב — מלכודות נפוצות

- לחשוב שרק מסמך בשם "תקנה" חייב פרסום — גם צו או הודעה מכוח חוק.
- לשכוח שהסממנים מצטברים (כללי + נורמטיבי).
- לחשוב שמתקין התקנות רשאי לפטור את עצמו — רק הכנסת (האז).
- לחשוב שהצבת תמרור מחייבת פרסום ברשומות — רק תוכנו (רונן).
- לחשוב שאי-פרסום מוביל תמיד לבטלות — היום: בטלות יחסית (אזרזר).
- לחשוב שחוק חופש המידע מחייב להראות אינטרס — לא.

9.11 שלד לפתרון שאלה — פרסום ותחילת תוקף

1. **סווגו את הנורמה:** תקנה בת-פועל תחיקתי (כללית ונורמטיבית, מצטבר), הוראת מינהל, או הנחיה פנימית.
2. **אם מדובר בתקנה בת-פועל תחיקתי:** האם פורסמה ברשומות? האם יש פטור בחוק (ורק הכנסת רשאית לפטור, ובלבד שיש פרסום חלופי)?
3. **אם לא פורסמה:** מהי התוצאה? בטלות יחסית – שקלו את היקף הפגיעה בפרט מול האינטרס הציבורי, ופרסום חלופי (אזרזר).
4. **מועד תחילה:** ברירת מחדל – יום הפרסום; עתידית רצויה; רטרואקטיבית – רק אם הותרה והיא סבירה; בעייתית בעבירה חדשה, בתשלום על מה שכבר ניתן ובשלילת הטבה.
5. **הנחיות פנימיות:** אינן חייבות פרסום ברשומות, אך הנחיות כתובות שיש להן נגיעה לציבור חייבות בעמידה לעיון הציבור (חופש המידע, ס' 6(א)).

9.12 מלכודות בפתרון שאלות — טבלה

הטעות	למה היא שגויה	התיקון

לחשוב שכל הוראה מנהלית חייבת רק תקנה בת-פועל תחיקתי; הוראת מינהל לבדוק את שני הסממנים

פרסום ברשומות	והנחיה פנימית פטורות	
להתמקד בשם ("צו", "הודעה")	אלכסנדרוביץ': הצו נבחן לפי תוכנו, לא כותרתו	לנתח את המהות
להסיק בטלות מוחלטת מאי-פרסום	כיום – בטלות יחסית (אזרזר)	לאזן בין הפגיעה בפרט לאינטרס הציבורי
לחשוב שמתקין התקנות רשאי לפטור את עצמו	רק הכנסת, בחוק, ובלבד שיש פרסום חלופי (האז)	לחפש פטור בחקיקה ראשית
להתעלם מהבעיה של רטרואקטיביות פלילית	עקרונות חוק העונשין אוסרים להעניש על מה שלא היה אסור	לבדוק עבירה חדשה

9.13 תרגיל פתור — צו שלא פורסם

✎ דוגמה — צו מכוח חוק, בלי פרסום

העובדות: שר התעשייה והמסחר הוציא צו מכוח חוק, החל על כל יבואני מוצר מסוים, שלפיו כל יבואן חייב לסמן את המוצר בסימון מיוחד. הצו נשלח בדואר ליבואנים אחדים אך לא פורסם ברשומות. יבואן שלא סימן הועמד לדין.

הפתרון:

1. **סיווג:** הצו כללי (מופנה ליבואנים בלתי מסוימים) ונורמטיבי (יוצר חובה חדשה – תקנה בת-פועל תחיקתי (אלכסנדרוביץ').
2. **חובת פרסום:** הצו חייב פרסום ברשומות, ואין פטור בחוק. שליחה בדואר ליבואנים אחדים אינה פרסום חלופי שהחוק קבע.
3. **תוצאה:** טענת אי-פרסום מועלית כהגנה בהליך הפלילי; כתב האישום עשוי להתבטל, בדומה לאלכסנדרוביץ'. בהליך מנהלי אחר ייבחנו הפגיעה בפרט והאינטרס הציבורי (בטלות יחסית).
4. **מסקנה:** היבואן יזוכה או כתב האישום יבוטל.

9.14 סיכום הפרק

✔ שורה תחתונה — סיכום הפרק

- תקנה בת-פועל תחיקתי (כללית + נורמטיבית) חייבת פרסום ברשומות; הוראת מינהל והנחיה פנימית לא.
- פטור מפרסום – רק הכנסת, בחוק, עם פרסום חלופי (האז); תמרור – נתון עובדתי (רונן).
- אי-פרסום: בטלות יחסית (אזרזר), לפי היקף הפגיעה בפרט ופרסום חלופי.
- תחילה: ברירת מחדל – יום הפרסום; פרוספקטיבית רצויה; רטרואקטיבית – בעייתית במיוחד בעבירה, בתשלום על העבר ובשלילת הטבה.
- שקיפות: ס' 6(א) לחוק חופש המידע; הזכות למידע כפופה לביקורת (המל"ג נ' הארץ).

9.15 מילון מושגים

- **תקנה בת-פועל תחיקתי** — נורמה כללית שמשנה את המשפט; חייבת פרסום ברשומות.
- **רשומות** — העיתון הרשמי של המדינה.
- **הוראת מינהל** — הוראה בכתב מכוח חיקוק שאינה בת-פועל תחיקתי.
- **תחולה פרוספקטיבית / רטרואקטיבית** — צופה פני עתיד / למפרע.
- **נתון עובדתי המפעיל נורמה** — כמו הצבת תמרור.
- **ממונה על חופש המידע** — בעל התפקיד בכל רשות.

9.16 נקודות מפתח למבחן

✔ **שורה תחתונה — עיקרי הפרק**

- ס' 17 לפקודת הפרשנות: חובת פרסום לתקנה בת-פועל תחיקתי.
- אלכסנדרוביץ': כלליות + נורמטיביות; כתב האישום בוטל.
- האז: רק הכנסת פוטרת; פרסום חלופי; "אין חוקי סתר".
- רונן: נורמה (פרסום) מול נתון עובדתי (פטור).
- אזרזר: בטלות יחסית.
- תחילת תוקף: יום הפרסום; עתידית רצויה; למפרע — בעייתית (עבירה, תשלום, שלילת הטבה).
- אפרתי + ס' 6(א) לחוק חופש המידע: להביא הנחיות לידיעת הציבור.
- חוק חופש המידע: ללא אינטרס; חריגים; עתירה; המל"ג נ' הארץ — טעם ממשי; כפיפות למשפט המנהלי.

9.17 שאלות בסגנון המבחן

✎ דוגמה — שאלה בסגנון המבחן (1)

מנהל רשות הוציא "הודעה" מכוח חוק, המחייבת את כל בעלי המסעדות בעיר להתקין מסנן שומן חדש, ושלח אותה בדואר רק לבעלי המסעדות הרשומים. ההודעה לא פורסמה ברשומות. מה הדין?

א. אין חובת פרסום — זו "הודעה" ולא "תקנה". ב. ההודעה היא תקנה בת-פועל תחיקתי (כללית ונורמטיבית) וחייבת פרסום ברשומות; התוצאה של אי-הפרסום תיבחן לפי הבטלות היחסית. ג. אין חובת פרסום כי נשלחה לנמענים. ד. המנהל רשאי לפטור את עצמו מפרסום.

התשובה וההסבר

ב. אלכסנדרוביץ' — לא השם קובע; האז — רק הכנסת פוטרת; אזרזר — בטלות יחסית.

✎ דוגמה — שאלה בסגנון המבחן (2)

רשות סירבה לבקשה לפי חוק חופש המידע, בנימוק שהמידע נוגע לדיונים פנימיים. מה נכון?

א. הסירוב כדין — דיונים פנימיים הם חריג. ב. המבקש צריך להראות אינטרס אישי. ג. אין די בהשתייכות לחריג — על הרשות להראות טעם ממשי ולשקול לפי כללי המשפט המנהלי. ד. אין עתירה על סירוב.

התשובה וההסבר

ג. המל"ג נ' הארץ. ב' שגויה — אין צורך באינטרס. ד' שגויה — ס' 17.

9.18 שאלות לחשיבה

1. האם המעבר לבטלות יחסית בפרסום הוא התקדמות?

תשובה אפשרית: מצד אחד — הוא מונע תוצאות קיצוניות (ביטול נורמה שכולם הכירו בפועל). מצד שני — הוא מחליש את התמריץ של הרשות לפרסם, ומעביר את הסיכון לפרט. מבחן הפגיעה בפרט מול האינטרס הציבורי מנסה לאזן.

2. למה הנחיות פנימיות אינן חייבות פרסום ברשומות, ובכל זאת חייבות להיות גלויות?

תשובה אפשרית: פרסום ברשומות מחייב ניסוח קשיח והליך ארוך, שיפגעו בגמישות. אבל הנחיה שקובעת למעשה איך יטופל אדם — משפיעה עליו; לכן הפשרה היא העמדה לעיון הציבור (ס' 6(א)), ולא פרסום רשמי.

פרק 10

שיקולים זרים, שוויון והפליה

10.1 מבוא — למה זה חשוב ומה מקומו בתמונה הגדולה

זהו המישור השלישי של התקיפה המנהלית: גם כשההחלטה התקבלה **בסמכות** ו**בהליך תקין**, אפשר לתקוף את **שיקול הדעת** עצמו. ארבעה פגמים מצדיקים התערבות: **שיקולים זרים**, **חוסר סבירות** (פרק 11), **חוסר מידתיות** ו**אי-מתן משקל ראוי לזכויות יסוד** (פרק 12). הפרק הזה עוסק בראשון — מתי שיקול "זר", מה עושים כשהשיקולים מעורבים, ואיך בכלל מוכיחים מה עבר בראשו של מקבל ההחלטה — ובעילה הקרובה לו: **שוויון והפליה**.

10.2 מהו שיקול דעת, ולמה בית המשפט נזהר

שיקול דעת — מצב שבו לגורם המוסמך יש כמה החלטות אפשריות, וכולן בתוך תחום הסמכות.

עמדה	הנימוק
נגד התערבות	המחוקק נתן את שיקול הדעת לרשות, לא לשופט; לשופט אין יתרון על הרשות
בעד התערבות	שיקול דעת מוחלט עלול להוביל לשימוש לרעה; בעל סמכות שאינו מפוקח יכול "להכשיר" כל החלטה ע"י עמידה בפרוצדורה

שני כלים לריסון:

- **הצהרתי:** "בית המשפט אינו מחליף את שיקול דעת הרשות בשיקול דעתו" — נאמר אינספור פעמים.
- **משפטי — חזקת החוקיות (התקינות) של המעשה המנהלי:** חזקה שפעולת הרשות חוקית ותקינה; הנטל על הטוען אחרת. החזקה פועלת גם **לטובת הפרט** שמסתמך על החלטת הרשות. **הוועדה המקומית ירושלים נ' ברעלי (ע"א 1182/92):** בעל בית בליפתא, שערך ירד בשל כביש

בגין, תבע פיצויים; הוועדה טענה שהבית בנוי בשמורת טבע בלי אישור. בית המשפט: יש היתר בנייה חתום כדין מלפני 30 שנה — חזקה שניתן כדין; הנטל על הוועדה.

10.3 כלל השיקולים הזרים — שני פנים

פן	הציווי
חיובי	לשקול **את כל** השיקולים הרלוונטיים
שלילי	לא לשקול **אף** שיקול שאינו רלוונטי

מאיפה יודעים מה רלוונטי? — מהחוק המסמיך ותכליתו (למשל ס' 82 לחוק הטיס: בטיחות, סדירות, יעילות, הגנה על הציבור והסביבה). אבל לא רק:

ויכסלבוים נ' שר הביטחון (בג"ץ 5688/92; דנג"ץ 3299/93): משפחה שכולה ביקשה להוסיף על מצבת בנה, בבית עלמין צבאי, את שמות אחיו. לפי החוק המצבות אחידות, וכל חריגה מחייבת אישור השר — שסירב בשם **ממלכתיות ואחידות**. העתירה התקבלה. **השופט ברק:** "השיקולים הרלוונטיים נגזרים מתכלית החקיקה. הם כוללים את המטרות הפרטיקולריות שדבר החקיקה נועד להגשים ואת **עקרונות היסוד של השיטה**, המשמשים '**מטרייה נורמטיבית**' ותכלית כללית לכל החקיקה כולה." השר לא שקל את כבוד האדם (וזכויות היסוד) — פגם בפן החיובי.

פורז נ' ראש עיריית תל אביב: הרכב הגוף הבוחר את רב העיר — השיקול הדתי היה רלוונטי, אבל לא נשקל כלל שיקול **השוויון** (השתתפות נשים) — שוב, פגם בפן החיובי.

10.4 "המקרה הקל" — שיקול זר בלבד

רסקין נ' המועצה הדתית ירושלים (בג"ץ 465/89): רקדנית בטן גילתה שמפסיקים להזמין אותה: המועצה הדתית הודיעה לאולמות ולמלונות שלא תינתן תעודת כשרות למקום שמתקיימות בו הופעות "לא צנועות". **ס' 11 לחוק איסור הונאה בכשרות, התשמ"ג–1983:** "במתן תעודת הכשר יתחשב הרב **בדיני כשרות בלבד**". המחוקק חשש בדיוק מזה — שהכשרות תהפוך למנוף לאכיפת נורמות אחרות. צניעות אינה חלק מדיני כשרות המזון — **שיקול זר**; ההחלטה נפסלה. (בית המשפט הכריע בשאלה הלכתית, כפי שהוא מכריע בשאלות רפואה או הנדסה — בעזרת חוות דעת.) **השופט אור:** החוק "לא נועד לשרת מטרות של השלטת דיני ההלכה בעניינים אשר אינם חלק מדיני כשרות המזון".

יישומים:

- **קומפורטי (2009):** בעלת מאפייה — יהודייה משיחית — נשללה ממנה תעודת כשרות. **מידת הדתיות של בעל העסק** אינה שיקול רלוונטי לכשרות.
- **לזרוביץ' נ' המפקח על המזונות:** צו שאסר גידול חזירים משיקולי כשרות — תפקיד המפקח על המזונות הוא להבטיח שאין מחסור במזון; השיקול הדתי **זר** לסמכותו.
- **מיטראל נ' ראש הממשלה ושר הדתות:** החלטה שמטרתה להגן על שומרי כשרות שלא ייאלצו לאכול לא-כשר — שיקול **ענייני**; החלטה שמטרתה למנוע ממי שאינו שומר כשרות לאכול בשר לא-כשר — **לא ענייני**.
- **שוורצמן נ' הרבנות הראשית:** יבואן בשר מינה רב מטעמו בחו"ל; הרבנות סירבה להכיר בכשרות — שיקול ראוי בתחום סמכותה; העתירה נדחתה.

10.5 "המקרה הקשה" — שיקולים מעורבים: הלכת אמה ברגר

ברגר נ' הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה חיפה (בג"ץ 392/72): אמה ברגר, נוצרייה גרמנייה שהאמינה שעל עם ישראל לשגשג בארצו, הקימה עם קהילתה מפעלים וחוות בין בנימינה לזכרון יעקב, וביקשה לקנות פנסיון במרכז המושבה. תושבים שמרנים לא רצו בכך, ויזמו תוכנית שסימנה את הפנסיון **כמבנה ציבור (בית עם)** — כדי שאפשר יהיה להפקיעו. הוועדה המחוזית אישרה ודחתה את התנגדותה. היו שיקולים רלוונטיים (צורך במתנ"ס, מיקום מתאים) — ושיקול זר (זהותה).

#	מבחן	מתי ההחלטה פסולה	קושי לעותר
1	**בלעדיות**	השיקול הזר היה היחיד; השאר — הסוואה	הכי קשה
2	**הכרעה** ("אלמלא")	אלמלא השיקול הזר — ההחלטה הייתה אחרת	↓
3	**דומיננטיות**	השיקול הזר היה העיקרי	↓
4	**השפעה ממשית**	לשיקול הזר הייתה השפעה ממשית	↓
5	**השפעה כלשהי**	כל השפעה	הכי קל

ההלכה (השופט י' כהן): המבחן הרביעי — **השפעה ממשית**. המבחנים מדורגים: מה שעומד במבחן 4 — עומד גם ב-1 עד 3 (ממשי, דומיננטי, מכריע או בלעדי → פסול). השפעה **כלשהי** בלבד (מבחן 5) — **אינה** פוסלת. (השופט ברנזון ראה כאן "מקרה קל" — השיקול הזר נאמר במפורש בדיונים.) העתירה התקבלה. לפי הלכת ברגר, **אופי** השיקול הזר (חמור מוסרית או לא) אינו משנה — רק עוצמת השפעתו.

דוויקאת נ' ממשלת ישראל (בג"ץ 390/79, אלון מורה): תפיסת קרקע פרטית להקמת יישוב — השיקולים היו ביטחוניים וגם אידיאולוגיים. בית המשפט השתמש במבחן **המטרה הדומיננטית**: מהפרוטוקולים עלה שהשיקול העיקרי היה אידיאולוגי — שאינו ענייני לפגיעה בקניין; נפסק שיש לפנות את היישוב.

רונן נ' שר החינוך (בג"ץ 706/94) — הרהורי השופט חשין: אדם שרצח מתחרה עסקי קיבל חנינה, בין השאר על סמך מצבו הבריאותי — והתברר שחוות הדעת הרפואיות זויפו. החנינה בוטלה (השיקול השקרי היה בעל השפעה מכרעת). חשין העלה (אמרת אגב): אולי ראוי להוסיף למבחן העובדתי **מבחן ערכי** — לפי **חומרת** השיקול: שיקול פסול "בעליל" (הפליה גזעית או פוליטית, מרמה, שוחד) — יפסול גם בהשפעה **כלשהי**; שיקול זר "רגיל" — רק בהשפעה דומיננטית. "נוכחות יסוד התרמית יצדיק ביטולה של החלטה... הגם שהשפעתה לא הייתה ניכרת". זה לא שינה את הלכת ברגר.

10.6 איך מוכיחים שיקול זר?

קשה מאוד: מדובר במחשבה סובייקטיבית, ובעל הסמכות לא יאמר "שקלתי שיקול זר". לפעמים זה עולה מפרוטוקולים או מעדויות.

מוסקוביץ נ' מועצת השמאים (בג"ץ 571/89): מוסקוביץ עבר את כל הבחינות וההתמחות, ונכשל שלוש פעמים בבחינת "שומה למעשה" — אף שלפי הפתרונות הרשמיים (שהקליט ביום העיון) ולפי שמאים ותיקים היה צריך לעבור. הטענה: המועצה — שמאים ותיקים — מכשילה בכוונה כדי לצמצם תחרות. הראיות: **נתונים סטטיסטיים** (בחמש שנים, אחוזי מעבר של 2% עד 35%; בשנים 1980–1984 — 32 מתוך 500 נבחנים, כ-6.5%), דו"ח **מבקר המדינה**, ממצאי **ועדת הכנסת לביקורת המדינה** ("מונופול של גילדה כמעט סגורה"), חוות דעת של שמאים **בלתי תלויים**, עדויות, ואף דברים של בכירים במועצה. **השופט אור:** "כשנמסר לרשות שיקול דעת להחליט בעניין מקצועי... חובה עליה... לפעול ללא שרירות, ללא הפליה, ללא שיקולים זרים... ומבלי להתעלם משיקולים החשובים לעניין"; המכלול מצביע על מדיניות הכשלה — שיקול זר. מדוע זר? הוועדה הבוחנת מוסמכת לבדוק רק אם התשובות נכונות — לא לשמור על "גילדה". המבחן נבדק מחדש, והעותר עבר.

השופט ברק: "מחשבות קשות הן להוכחה, ומחשבות שלא כדין על אחת כמה וכמה. מכאן **המגמה המודרנית** במשפט המינהלי לעבור ממבחנים סובייקטיביים... (כגון שיקולים זרים) לעבר מבחנים

אובייקטיביים (כגון סבירות)." ובינתיים: **נתונים סטטיסטיים** עשויים ליצור **חזקה שבעובדה** המעבירה את **נטל הבאת הראיות** לרשות — שתסביר את פעולתה.

10.7 שוויון והפליה

	שוויון חוקתי	שוויון מנהלי
התוכן	איסור הפליה מטעמים "חשודים": דת, גזע, מין, צבע, מוצא — פגיעה מבזה היא פגיעה בכבוד האדם	חובה לתת **יחס זהה למצבים זהים**; אסור להבחין בלי **שוני רלוונטי**
אילו טענות היא מבססת	שיקולים זרים (שקלו דת/גזע/מין), וגם חוסר סבירות, חוסר מידתיות ואי-מתן משקל ראוי לזכויות	חוסר סבירות, חוסר מידתיות, אי-מתן משקל ראוי — אבל **לא** בהכרח שיקול זר (סירוב לסגירת מרפסת שונה מהשכן אינו בהכרח משיקול זר)

הבחנה מותרת: כשיש **שוני רלוונטי**. **גת נ' המשרד לביטחון פנים (תקופת הקורונה):** הבחנה בין מתחסנים למי שלא התחסנו — נשענה על נתונים מדעיים מבוססים; זו הבחנה עניינית, לא הפליה.

הפליה תוצאתית — שדולת הנשים בישראל נ' ממשלת ישראל: אף שלא הוכח ששקלו את המגדר — ההפליה נבחנת גם **במבחן התוצאה**: אם בפועל כמעט אין נשים בתפקידים (כמו דירקטוריונים של חברות ממשלתיות), זו הפליה. (ס' 18א לחוק החברות הממשלתיות מחייב **ייצוג הולם** לשני המינים.)

הבית הפתוח נ' עיריית ירושלים (2010): העירייה לא הקצתה תמיכה לעמותה של הקהילה הגאה. התמיכה חייבת להיות לפי **קריטריונים שוויוניים** ומבחנים ענייניים; כשגוף פוליטי מרובה חברים מחליט — יש להבחין בין שיקולים זרים לשיקולים פסולים, ולבחון את התוצאה.

שרירותיות טבועה — מותרת: כל קביעת גבול (מרחק, משקל, גיל, תאריך) יוצרת שרירות מסוימת — מי שנמצא מטר מעבר לקו. **קיבוץ יחיעם נ' ממשלת ישראל** (הטבות "קו התפר"), **גני חוגה נ' שר האוצר** (פיצוי לגן אירועים אחרי מלחמת לבנון השנייה), **המון וולים נ' ממשלת ישראל** (פיצויי קורונה): חייבים לקבוע גבול, וזה לגיטימי — יעילות וודאות שלטונית; אבל "יעילות וודאות אינן חזות הכל" — הקו עצמו צריך להיות סביר.

10.8 מלכודות נפוצות

! שים לב — מלכודות נפוצות

- לשכוח את הפן החיובי — אי-שקילת שיקול רלוונטי (ויכסלבוים, פורז) היא פגם.
- לחשוב שכל השפעה של שיקול זר פוסלת — ההלכה: השפעה ממשית ומעלה.
- לחשוב שהרהורי חשין ברונן הם ההלכה — ברגר עומדת.
- לחשוב שאי אפשר להוכיח שיקול זר — ראיות נסיבתיות וסטטיסטיות מעבירות נטל (מוסקוביץ).
- לבלבל בין שוויון חוקתי (טעמים חשודים) למנהלי (יחס זהה למצבים זהים).
- לחשוב שכל קו גבול הוא הפליה — שרירותיות טבועה מותרת.

10.9 שלד לפתרון שאלה — שיקולים זרים והפליה

1. **מהי תכלית הסמכות?** התכלית היא מקור השיקולים הרלוונטיים (ויכסלבוים): מטרות החוק הספציפיות ועקרונות היסוד של השיטה, כולל זכויות יסוד.
2. **הפן החיובי:** האם הרשות שקלה את כל השיקולים הרלוונטיים (למשל שוויון, כבוד האדם)? אם לא – פגם.
3. **הפן השלילי:** האם נשקל שיקול זר? אם הוא יחיד – "המקרה הקל" (רסקין, קומפורטי). אם מעורב עם שיקולים רלוונטיים – "המקרה הקשה": מבחן ברגר – השפעה ממשית פוסלת.
4. **הוכחה:** ראיות נסיבתיות, סטטיסטיקה היוצרת חזקה בעובדה (מוסקוביץ), פרוטוקולים, התנהלות הרשות.
5. **שוויון:** האם יחס שונה למצבים זהים ללא שוני רלוונטי? האם יש הפליה תוצאתית (שדולת הנשים)? האם זו שרירותיות טבועה מותרת?

10.10 מלכודות בפתרון שאלות — טבלה

הטעות	למה היא שגויה	התיקון

לפסול כל החלטה שנגע בה שיקול זר	לפי ברגר פוסלת רק השפעה ממשית; השפעה כלשהי אינה מספיקה	להעריך את עוצמת ההשפעה
לחשוב שחומרת השיקול משנה במבחן ברגר	ההלכה: אופי השיקול אינו משנה, רק עוצמת ההשפעה (חשין הציע מבחן ערכי באגב)	להבחין בין הלכה להצעה
לדרוש כוונת הפליה	שדולת הנשים: ההפליה נבחנת גם במבחן התוצאה	לבדוק את התוצאה בפועל
לראות בכל קו גבול הפליה	שרירותיות טבועה בקביעת גבול היא לגיטימית	לבחון עניינות וסבירות הגבול
לראות בפגיעה בשוויון תמיד היא מבססת לעיתים חוסר סבירות או מידתיות ולא בהכרח שיקול זר		לשייך את הטענה לעילה הנכונה

10.11 תרגיל פתור — מכרז ושיקול נוסף

✎ דוגמה — מינוי ועדת שיפוץ

העובדות: רשות מקומית דחתה הצעה למתן רישיון לשימוש בנכס ציבורי. מפרוטוקולים עולה שהשיקולים היו (1) ניסיון מקצועי של המציע, (2) מחיר, ו-(3) העובדה שהמציע חבר בתנועה פוליטית מתחרה. השיקול השלישי הוזכר שלוש פעמים ונחשב "משמעותי" בדיוני הוועדה.

הפתרון:

1. **תכלית:** רישיון בנכס ציבורי נועד לאפשר שימוש טוב ובמחיר ראוי; השיקול הפוליטי זר.
2. **סוג המקרה:** שיקולים מעורבים – "המקרה הקשה" (ברגר).
3. **המבחן:** האם לשיקול הזר הייתה השפעה ממשית על ההחלטה? הפרוטוקולים (שלוש הזכרות, משקל "משמעותי") מצביעים על כך.
4. **הוכחה:** ראיות נסיבתיות מהפרוטוקולים מספיקות; אין צורך בהודאה.
5. **שוויון:** גם פגיעה בשוויון בין מציעים משיקול פוליטי.
6. **מסקנה:** ההחלטה נפסלת; הוועדה תדון מחדש בלי השיקול הפוליטי.

10.12 סיכום הפרק

✔ **שורה תחתונה — סיכום הפרק**

- כלל השיקולים: פן חיובי (לשקול הרלוונטי) ופן שלילי (לא לשקול זר). מקור השיקולים – תכלית החקיקה (ויכסלבוים).
- מקרה קל: שיקול זר בלבד – החלטה נפסלת (רסקין, קומפורטי, לזרוביץ').
- מקרה קשה: ברגר – השפעה ממשית פוסלת; מבחנים אחרים (כלשהי, אלמלא, דומיננטית, בלעדית). חשין ברונן – מבחן ערכי (אגב).
- הוכחה: מכלול ראיות וסטטיסטיקה כחזקה בעובדה (מוסקוביץ).
- שוויון מנהלי: יחס זהה למצבים זהים; הפליה תוצאתית; שרירותיות טבועה בקביעת גבולות מותרת.

10.13 מילון מושגים

- **שיקול זר** — שיקול שאינו נובע מתכלית החוק המסמיך ועקרונות השיטה.
- **מטרייה נורמטיבית** — עקרונות היסוד שחלים על כל חקיקה.
- **חזקת החוקיות** — חזקה שמעשה הרשות תקין.
- **השפעה ממשית** — המבחן לשיקולים מעורבים.
- **חזקה שבעובדה** — מסקנה מנסיבות שמעבירה את נטל הבאת הראיות.
- **שוני רלוונטי** — הבדל שמצדיק יחס שונה.
- **שרירותיות טבועה** — שרירות בלתי נמנעת בכל קביעת גבול.

10.14 נקודות מפתח למבחן

✔ שורה תחתונה — עיקרי הפרק

- ריסון: "לא יחליף את שיקול דעתה"; חזקת החוקיות (ברעלי — גם לטובת הפרט).
- שני פנים: לשקול את כל הרלוונטיים (ויכסלבוים — "מטרייה נורמטיבית"; פורז), ולא לשקול זרים.
- מקרה קל: רסקין (כשרות בלבד); קומפורטי; לזרוביץ'; מיטראל.
- מקרה קשה: אמה ברגר — חמישה מבחנים; ההלכה — השפעה ממשית; דוויקאת — מטרה דומיננטית; רונן — הרהורי חשין.
- הוכחה: מוסקוביץ — סטטיסטיקה ומכלול ראיות; ברק — מעבר למבחנים אובייקטיביים; העברת נטל.
- שוויון: חוקתי מול מנהלי; שוני רלוונטי; שדולת הנשים (תוצאה); שרירותיות טבועה מותרת.

10.15 שאלות בסגנון המבחן

✎ דוגמה — שאלה בסגנון המבחן (1)

ועדה הסירה רישיון לבעל עסק בשל שלושה טעמים: שני טעמים ענייניים, וטעם שלישי — עמדותיו הפוליטיות. הוכח שלטעם הפוליטי הייתה השפעה ממשית על ההחלטה, אך לא הוכח שבלעדיו ההחלטה הייתה שונה. מה הדין לפי הלכת אמה ברגר?

א. ההחלטה תקפה — לא הוכח קשר סיבתי. ב. ההחלטה פסולה — די בהשפעה ממשית של שיקול זר. ג. ההחלטה תקפה — יש שני שיקולים ענייניים. ד. ההחלטה פסולה רק אם השיקול הזר היה בלעדי.

התשובה וההסבר

ב. מבחן ההשפעה הממשית אינו דורש להוכיח "אלמלא". א' משקפת את מבחן ההכרעה (2), ד' — את מבחן הבלעדיות (1); שניהם מחמירים מההלכה.

✎ דוגמה — שאלה בסגנון המבחן (2)

במשך עשר שנים עברו את בחינת הרישוי של מקצוע מסוים 4% בלבד מהנבחנים, בעוד שבמקצועות דומים עוברים 60%. מה המשמעות הראייתית?

א. אין משמעות — שיקול זר חייב הוכחה ישירה. ב. הנתונים הסטטיסטיים עשויים ליצור חזקה שבעובדה המעבירה לרשות את נטל ההסבר. ג. הנתונים מוכיחים לבדם הפליה מוחלטת. ד. יש לפנות לבית הדין לעבודה.

התשובה וההסבר

ב. מוסקוביץ — דברי השופט ברק. ג' מגזימה — מדובר בחזקה הניתנת לסתירה.

10.16 שאלות לחשיבה

1. האם הצעת חשין (מבחן לפי חומרת השיקול) עדיפה על הלכת ברגר?

תשובה אפשרית: בעד — הפליה גזעית או מרמה פוגעות באמון הציבור גם בהשפעה קטנה, וראוי להחמיר. נגד — מבחן ערכי פחות צפוי ומרחיב את שיקול הדעת השיפוטי; ברגר פשוטה וברורה יותר.

2. למה בית המשפט מעדיף מבחנים אובייקטיביים כמו סבירות?

תשובה אפשרית: כי קשה להוכיח מחשבות, והרשות יכולה להסוות שיקול זר. בחינת התוצאה (האם ההחלטה סבירה, האם יש הפליה תוצאתית) אינה דורשת לחדור לראשו של מקבל ההחלטה. המחיר — ביקורת רחבה יותר על שיקול הדעת.

פרק 11

עילת הסבירות

11.1 מבוא — למה זה חשוב ומה מקומו בתמונה הגדולה

עילת הסבירות היא העילה המוכרת — והשנויה במחלוקת — ביותר במשפט המנהלי הישראלי. בפרק נעקוב אחרי התפתחותה: מ"חוסר היגיון קיצוני" בנוסח האנגלי, דרך **דקה** ו**דפי זהב** שהפכו אותה לעילה של **איזון בין שיקולים**, ועד **גנור** ו**הלכת דרעי–פנחסי** שהביאו אותה לתודעה. נכיר את שלושת סוגי המקרים שבהם היא מופעלת, את הנימוקים בעד ונגד, ואת הפרק האחרון: פסק הדין בעניין **שיינפלד** (2023), **תיקון חוק יסוד: השפיטה** שביקש לבטל את העילה לגבי הממשלה ושריה, וביטולו בידי בג"ץ (2024).

11.2 הגישה הוותיקה — חוסר סבירות כחוסר היגיון

Wednesbury (אנגליה, 1948): החלטה בלתי סבירה היא החלטה "כה אבסורדית, עד ששום אדם הגיוני לא יכול לחלום שהיא בגדר הסמכות שהוענקה לו... כה בלתי סבירה עד שניתן לתארה כנגועה ברוע לב".

היועמ"ש נ' מ' דיזנגוף ושות' (שיט) (ע"א 311/57): הממשלה העלתה אגרות נמל **רטרואקטיבית** מתחילת השנה — גם על אוניות שכבר פרקו. התקנות נפסלו: "אם ימצא בית המשפט כי חקיקת המשנה היא כה בלתי הגיונית ובלתי נסבלת, עד שאדם בר-דעת לא יעלה על דעתו ששר סביר היה מסוגל לעשותה, כי אז יצטרך לאמור שמעולם לא נתכוון המחוקק לתת כוח זה בידי השר".

מאפייני הגישה הוותיקה:

- חוסר סבירות = חוסר היגיון, שרירות, חוסר צדק משווע, חוסר תום לב בוטה.
- קישור (מלאכותי) לחוסר סמכות: "המחוקק לא התכוון לתת כוח כזה" — אף שמבחינה תפקודית השר היה מוסמך.
- הופעלה בעיקר נגד **תקנות** (חקיקת משנה).

11.3 דקה נ' שר התחבורה (בג"ץ 156/75) — עילה עצמאית של איזון

⚖ פסק דין — עובדות והכרעה

העובדות: רישיונות מונית מוגבלים במספרם וניתנים בהגרלה לפי תנאים בתקנות; נקבע שמי שמחזיק רישיון — אפילו חצי רישיון בשותפות — אינו רשאי להשתתף. דקה, בעל חצי רישיון, עתר: לא סביר ולא שוויוני. העתירה נדחתה — אבל **השופט שמגר** ניסח מחדש את העילה:

§ סעיף — ציטוט / הסעיף

חוסר הסבירות מתבטא בדרך כלל בהפליה, בשיקולים זרים, באי-שקילת שיקול מהותי — "אולם... יכולה אי-הסבירות גם להתגלות **כאשר היא בגפה**: ...לא נשקל שיקול זר, והובאו בחשבון אך ורק שיקולים רלבנטיים, אולם לשיקולים הרלבנטיים השונים יוחס **משקל בפרופורציה כה מעוותת** ביניהם לבין עצמם, עד שהמסקנה הסופית הפכה מופרכת מעיקרה... חוסר-הסבירות יכול שיתגלה **על אף תום הלב**."

- הרחבה: מ"לא הגיוני" ל**"סבירות איזונית"** — משקל לא ראוי לשיקולים רלוונטיים.
- **עילה עצמאית** — גם בלי שיקולים זרים ובלי חוסר תום לב.
- לפסילה נדרש חוסר סבירות **קיצוני** — כאן התקנות לא היו נכונות לדעתו, אבל לא קיצוניות.

11.4 דפי זהב נ' רשות השידור (בג"ץ 389/80) — ברק מול לנדוי

⚖ פסק דין — עובדות והכרעה

העובדות: פרסומות ברדיו של רשות השידור טופלו מאז 1960 בידי חברה פרטית (ש.פ.ב.) תמורת חלק מההכנסות, בחוזה שמתחדש אוטומטית. דפי זהב ביקשה להגיש הצעה מתחרה; הרשות סירבה, שיפרה את התנאים מול ש.פ.ב. (מ-40% ל-50%) והאריכה. דפי זהב עתרה: לא סביר לסרב לשמוע הצעה. העתירה נדחתה (גם חובת מכרז — לא הוכרה בלי חקיקה; חוק חובת המכרזים נחקק ב-1992).

השופט ברק — ארבע הפרופוזיציות:

1. חוסר סבירות **כשלעצמו** הוא עילה לפסילת שיקול דעת מנהלי;
2. חוסר הסבירות נמדד ב**אמות מידה אובייקטיביות**;
3. הפוסל — חוסר סבירות **מהותי או קיצוני**;
4. עקרון הסבירות פוסל שיקול דעת ש**אינו נותן משקל ראוי** לאינטרסים השונים שעל הרשות להתחשב בהם.

ועוד: חל על **כל** אקט מנהלי — כללי או פרטני (ולא רק על תקנות). (השופטת בן פורת הצטרפה.)

השופט לנדוי — הסתייגות: "סבירות" הוא קנה מידה אובייקטיבי של **התנהגות**, כמו ברשלנות. אם כך, בית המשפט יבחן את ההחלטה מחדש (*de novo*), כאילו הוא מקיים דיון חוזר בנכונותה. די בנוסחאות המקובלות (שרירות, שיקולים זרים); נוסחה של "משקל יחסי בלתי סביר" "עלולה לערב את בית המשפט בבדיקת תבונתה ויעילותה של ההחלטה" — ולעורר "תקוות שווא בלב האזרח".

מתחם הסבירות: בכל החלטה יש **מתחם** של החלטות לגיטימיות. גם אם השופט סבור שההחלטה האופטימלית היא א' והרשות בחרה ב' — כל עוד ב' בתוך המתחם, היא תעמוד. פסילה רק ב**חריגה מהמתחם**. בדפי זהב, האפשרויות היו: הארכה בתנאים גרועים יותר; הארכה בלי שינוי; הארכה בתנאים טובים יותר (שנבחרה); השוואה עם הצעת דפי זהב; מכרז פתוח — כולן בתוך המתחם, למעט הראשונה. ככל שמצטברת פסיקה — המתחם מתבהר.

11.5 גנור נ' היועמ"ש (בג"ץ 935/89) — העילה בפעולה

⚖ פסק דין — עובדות והכרעה

הרקע — פרשת ויסות מניות הבנקים: הבנקים "ויסתו" את מחירי מניותיהם במשך שנים; ב-1983 קרסה השיטה, המסחר הופסק, והמדינה רכשה את המניות מהציבור בכ-7 מיליארד דולר. ועדת חקירה ממלכתית (ועדת בייסקי) מצאה פעולות לא חוקיות, והמשטרה המליצה להעמיד את מנהלי הבנקים לדין. **היועמ"ש** החליט שלא להעמיד לדין — מחוסר "עניין לציבור".

כיוון	השיקולים
בעד העמדה לדין	עבירות ממושכות, בחשאיות; פגיעה קשה באלפי אזרחים ובקופה הציבורית; עניין ציבורי בענישה ובהרתעה
נגד (שהיועמ"ש העדיף)	הוקעה ציבורית בדו"ח ועדת בייסקי; הבנקאים הודחו; אשמה גם של רשויות המדינה; זמן רב שחלף; עלות ההליך

ההכרעה: ההחלטה **בלתי סבירה באופן קיצוני** — המשקל לשיקולים נגד היה גדול מהראוי, ולשיקולים בעד — קטן מהראוי (הוקעה ציבורית אינה כמו הרשעה פלילית; רשלנות הרשויות אינה פוטרת את המבצעים). בית המשפט הורה להעמיד לדין — **על סמך עילת הסבירות בלבד** (לא נקבע שהיו שיקולים זרים). (הבנקאים הורשעו; בעליון הומרו עונשי המאסר.) מכאן ואילך — שטף של עתירות בעילת הסבירות.

11.6 שלושה סוגי מקרים

סוג	השיקולים המתנגשים	דוגמה	מידת הלגיטימיות
1	זכות יסוד מול אינטרס ציבורי	**אינדור נ' ראש עיריית ירושלים (בג"ץ 953/89):** הפגנה מול הקונסוליה האמריקאית; הקונסול התלונן, וההפגנה פוזרה. ניתן משקל גדול מדי ליחסי החוץ ומשקל קטן מדי **לחופש הביטוי** — לא סביר	נתפס כלגיטימי

2	שני אינטרסים מקצועיים שאינם זכויות יסוד	**התנועה לאיכות השלטון נ' המועצה הארצית (בג"ץ 2324/91):** תחנת כוח הידרו-חשמלית בירדן ההררי — אנרגיה ירוקה מול שמירת טבע; בית המשפט **לא התערב**. **צוקר נ' שר הפנים (בג"ץ 581/87):** השר הטיל וטו על תוכנית אצטדיון טדי בטענה שנדרש תכנון כולל (ובעיתון — חילול שבת); הווטו נפסל — כנראה מתוך חשד לשיקולים זרים שלא הוכחו	חריג ביותר — בעיקר כשההחלטה "לא הגיונית".
3	אינטרס ציבורי מול **שלטון החוק ואמון הציבור**	גנור; **אייזנברג** (מינוי מנכ"ל שהיה מעורב בפרשת קו 300 שנוי במחלוקת וקיבל חנינה — לא סביר); **דרעי–פנחסי**	ביותר

11.7 הלכת דרעי–פנחסי (1993)

- **התנועה לאיכות השלטון נ' ממשלת ישראל (בג"ץ 3094/93):** שר הפנים דרעי, שהוגש נגדו כתב אישום בעבירות שוחד, לא התפטר (אף שהתחייב), וראש הממשלה רבין לא פיטר אותו. ההחלטה שלא לפטר — **בלתי סבירה**; אף שבחוק נאמר "רשאי לפטר", בכתב אישום על עבירות חמורות שיש עמן קלון — **רשאי = חייב**.
- **אמיתי נ' ראש הממשלה (בג"ץ 4267/93):** אותו יום — אותה הכרעה לגבי סגן השר פנחסי (עבירות בחירות).
- הפסיקה הוחלה גם על **ראשי ערים** שהוגש נגדם כתב אישום (אומ"ץ). ומנגד — **לא** על כהונת ראש ממשלה שהוגש נגדו כתב אישום, שנבחר בידי הכנסת (2020).
- **2015 (בג"ץ 3095/15):** מינוי דרעי לשר, אחרי שריצה עונשו בעבירות שוחד ותקופת הצינון — לא בלתי סביר באופן קיצוני.

11.8 בעד ונגד עילת הסבירות

נושא	נגד העילה	בעד העילה
הפרדת רשויות	המחוקק נתן את שיקול הדעת לרשות — למה השקפת השופט על "סביר" תגבר על השקפת השר?	ביקורת שיפוטית היא חלק מהאיזונים והבלמים, במיוחד להגנה על זכויות

ודאות	אין אמות מידה; היועץ המשפטי אינו יודע אם החלטה תעמוד	גם ברשלנות הסבירות נקבעת בדיעבד; הפסיקה המצטברת משרטטת את המתחם
לגיטימציה	"הכשרה ערכית": כשבית המשפט קובע שהחלטה סבירה, הוא נותן לה גם לגיטימציה ערכית (למשל הריסת בתי מחבלים)	ביקורת אפקטיבית חשובה גם מול גורמים בינלאומיים — שהמעשים נבחנו לגופם

11.9 התקופה האחרונה — שיינפלד, התיקון לחוק היסוד וביטולו

שיינפלד נ' הכנסת (בג"ץ 8948/22, ינואר 2023): דרעי הורשע ב-2022 בהסדר טיעון בעבירות מס, והתפטר מהכנסת; בית משפט השלום אישר את ההסדר בין השאר בהבנה שהוא פורש מהחיים הציבוריים. אחרי הבחירות מונה לשר. רוב השופטים פסלו את המינוי — בנימוקים שונים:

נימוק	פירוט ושופטים
חוסר סבירות קיצוני	פגיעה באמון הציבור; הרשעה חוזרת; מאסר על תנאי; המצג לבית המשפט — חיות, פוגלמן, עמית, כבוב, ברון, גרוסקופף (וגם וילנר — בגישה מרוסנת)
השתק / מניעות	המצג שהציג לבית המשפט בהסדר הטיעון — שטיין, מינץ (וגם ברק-ארז ווילנר במצטבר)
אי-הכרעה	הפנייה לשאלת הקלון — אלרון

השופט שטיין — נגד סבירות "**המשפט זה אני**" (בחינה מוסרית-ערכית של השיקולים); בעד סבירות כ**כלל שיורי**, כמו "הדבר מעיד על עצמו" בנזיקין: החלטה שעל פניה בלתי סבירה באופן קיצוני "היא החלטה שלבטח לוקה באחד הפגמים היסודיים... שרירות, שיקולים זרים, הפליה" שאינם גלויים לעין. **השופט מינץ** — מתחם הסבירות של ראש ממשלה בהרכבת ממשלה **רחב ביותר**; כל "מרכיב ממשלה סביר" היה פועל כך.

תיקון מס' 3 לחוק יסוד: השפיטה (יולי 2023) — ס' 15(ד1): "על אף האמור בחוק יסוד זה, מי שבידו סמכות שפיטה על פי דין, לרבות בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק, **לא ידון בעניין סבירות ההחלטה של הממשלה, של ראש הממשלה או של שר אחר**, ולא ייתן צו בעניין כאמור; ...'החלטה' — כל החלטה, לרבות בענייני מינויים או החלטה להימנע מהפעלת כל סמכות".

התנועה לאיכות השלטון נ' הכנסת (בג"ץ 5658/23, 1.1.2024): ברוב של 12 מול 3 נקבע שלבית המשפט סמכות לבקר חוקי יסוד במקרים חריגים וקיצוניים של חריגה מהסמכות המכוננת; וברוב של 8 מול 7 — **התיקון בוטל** (זו שאלה חוקתית). אבל גם חלק משופטי הרוב (כמו השופט כבוב) קראו "להישיר מבט לביקורת" ולצמצם את השימוש בעילה; והשופט סולברג הציע לחזור לגבי החלטות הממשלה ושריה ל**סבירות בנוסח Wednesbury**. **המגמה:** ריסון בשימוש בעילה, ומעבר לעילות אחרות (השתק, שיקולים זרים, מידתיות).

11.10 מלכודות נפוצות

! שים לב — מלכודות נפוצות

- לחשוב שכל החלטה "לא טובה" אינה סבירה — נדרשת חריגה קיצונית ממתחם הסבירות.
- לחשוב שחוסר סבירות מחייב שיקול זר או חוסר תום לב — עילה עצמאית (דקה).
- לחשוב שהעילה חלה רק על תקנות — מאז דפי זהב על כל אקט מנהלי.
- לבלבל בין עמדות ברק ולנדוי בדפי זהב.
- לחשוב שעילת הסבירות בוטלה לגבי שרים — התיקון בוטל בבג"ץ 5658/23.
- לחשוב שבשיינפלד כל השופטים פסלו מטעמי סבירות — חלקם בשל השתק.

11.11 שלד לפתרון שאלה — עילת הסבירות

1. **סווגו את סוג המקרה:** (1) זכות יסוד מול אינטרס ציבורי; (2) איזון בין שני שיקולים מקצועיים; (3) פגיעה בשלטון החוק ובאמון הציבור (מינויים, אי-פיטורים, אי-העמדה לדין).
2. **זהו את השיקולים הרלוונטיים** שהרשות שקלה ואת המשקל שנתנה לכל אחד.
3. **בדקו את המשקל:** האם ניתן משקל "בפרופורציה מעוותת" לשיקול אחד על חשבון אחר (דקה, דפי זהב)?

4. **הפעילו את מתחם הסבירות:** האם ההחלטה חורגת מהמתחם באופן קיצוני? בית המשפט פוסל רק החלטה כזו, גם אם היה בוחר אחרת.
5. **הוסיפו הקשר עכשווי:** מצב העילה לאחר שיינפלד ובג"ץ 5658/23, וגישת שטיין (כלל שיורי) וסולברג (חזרה ל-Wednesbury).

11.12 מלכודות בפתרון שאלות — טבלה

הטעות	למה היא שגויה	התיקון
לבלבל סבירות עם חוסר היגיון גרידא	מאז דקה ודפי זהב זו גם עילה איזונית – משקל מעוות לשיקולים רלוונטיים	להצביע על משקל לא ראוי
לפסול כל החלטה שבית המשפט היה מחליט אחרת	נדרשת חריגה קיצונית ממתחם הסבירות	לציין "קיצוני"
לדרוש חוסר תום לב לראות בה עילה רק לתקנות	העילה עצמאית וקיימת גם בתום לב דפי זהב: חלה על כל אקט מנהלי	לא להוכיח כוונה להחיל על החלטות פרטניות
להתעלם ממצבה הנוכחי	התיקון לחוק היסוד בוטל ב-5658/23, ובכל זאת נשמעו קריאות לריסון	לציין את המחלוקת והמגמה

11.13 תרגיל פתור — החלטה שלא להעמיד לדין

✎ דוגמה — סבירות החלטת היועץ

העובדות: גורם בכיר באכיפה החליט לסגור תיק נגד בכירים בגוף פיננסי, על אף ראיות לכאורה חזקות לעבירות חמורות. בהחלטה נכתב שהעמדה לדין "עלולה לפגוע במוניטין המערכת הפיננסית". עותרים טוענים לחוסר סבירות.

הפתרון:

1. **סוג המקרה:** פגיעה בשלטון החוק ובאמון הציבור (סוג 3), כמו בגנור.
2. **שיקולים:** חומרת העבירות וכוח הראיות מול החשש למוניטין.
3. **משקל:** המשקל לשיקול המוניטין מעוות ביחס לחומרה ולאינטרס הציבורי באכיפה שוויונית.
4. **מתחם:** ההחלטה חורגת באופן קיצוני מהמתחם.
5. **מסקנה:** ההחלטה בלתי סבירה; ייתכן סעד של הוראה להעמיד לדין, כמו בגנור, או החזרה לבחינה מחדש.

11.14 סיכום הפרק

✔ שורה תחתונה — סיכום הפרק

- הגישה הוותיקה (Wednesbury, דיזנגוף): אבסורד שאין שר סביר שיעשה.
- דקה: עילה עצמאית של משקל מעוות; דפי זהב: ארבע פרופוזיציות, חלה על כל אקט, מתחם סבירות; לנדוי מזהיר מבחינה de novo.
- גנור: הפעלת העילה; שלושה סוגי מקרים: זכות יסוד, שני שיקולים מקצועיים, שלטון החוק.
- דרעי–פנחסי: אי-פיטורים אינו סביר. שיינפלד: מינוי דרעי נפסל – סבירות ומניעות; שטיין – כלל שיורי; מינץ – מתחם רחב.
- התיקון לחוק היסוד (2023) בוטל ב-5658/23 (12–3 לסמכות; 8–7 לביטול); סולברג הציע חזרה ל-Wednesbury.

11.15 מילון מושגים

- **Wednesbury** — סבירות כחוסר היגיון קיצוני.
- **סבירות איזונית** — משקל ראוי לשיקולים הרלוונטיים.
- **מתחם הסבירות** — טווח ההחלטות הלגיטימיות.
- **de novo** — בחינה מחדש של ההחלטה, כאילו לראשונה.
- **הלכת דרעי–פנחסי** — חובה לפטר שר שהוגש נגדו כתב אישום חמור.
- **מניעות / השתק** — מי שהציג מצג אינו יכול לטעון להפך.

11.16 נקודות מפתח למבחן

✔ שורה תחתונה — עיקרי הפרק

- Wednesbury ודיזנגוף — חוסר היגיון; קישור לסמכות; תקנות.
- דקה — עילה עצמאית; משקל מעוות; גם בתום לב; קיצוני.
- דפי זהב — ארבע הפרופוזיציות; כל אקט; ברק מול לנדוי; מתחם הסבירות.
- גנור — העמדה לדין בעילת סבירות בלבד.
- שלושה סוגים: זכות מול אינטרס (אינדור); מקצועי מול מקצועי (ירדן; צוקר); שלטון החוק (אייזנברג, דרעי–פנחסי).
- בעד ונגד; שיינפלד (סבירות + השתק; שטיין — כלל שיורי; מינץ — מתחם רחב); תיקון 2023 וביטולו ב-2024.

11.17 שאלות בסגנון המבחן

✎ דוגמה — שאלה בסגנון המבחן (1)

רשות שקלה רק שיקולים רלוונטיים, בתום לב, אך נתנה משקל מזערי לפגיעה קשה בחופש העיסוק של אלפי אנשים, לעומת משקל עצום לחיסכון מנהלי קטן. איזו קביעה **נכונה**?

א. אין עילה — לא נשקלו שיקולים זרים. ב. אין עילה — הרשות פעלה בתום לב. ג. ההחלטה עלולה להיפסל בעילת חוסר סבירות — משקל מעוות לשיקולים רלוונטיים, גם בתום לב. ד. ההחלטה בטלה רק אם נעשתה בחוסר סמכות.

התשובה וההסבר

ג. דקה ודפי זהב — סבירות איזונית, עילה עצמאית.

✎ דוגמה — שאלה בסגנון המבחן (2)

מה הייתה עמדת השופט לנדוי בדפי זהב?

א. שחוסר סבירות הוא עילה עצמאית רחבה. ב. שהוספת נוסחה של "משקל יחסי בלתי סביר" עלולה להפוך את בית המשפט לבוחן את תבונת ההחלטה ויעילותה — ויש להסתפק בנוסחאות המקובלות. ג. שאין ביקורת שיפוטית על רשות השידור. ד. שחובה לערוך מכרז.

התשובה וההסבר

ב. א' — עמדת ברק. ד' — בית המשפט לא הכיר בחובת מכרז בלי חקיקה.

11.18 שאלות לחשיבה

1. האם הגישה של השופט שטיין ("כלל שיורי") פותרת את הוויכוח?

תשובה אפשרית: היא שומרת על העילה ככלי ראייתי — החלטה בלתי סבירה באופן קיצוני מעידה על פגם נסתר — ובכך מצמצמת את הטענה ש"השופט מחליף את שיקול הדעת". מנגד, היא מוותרת על ההגנה ה"איזונית" על זכויות, שאולי תעבור לעילת המידתיות.

2. למה הלכת דרעי–פנחסי שנויה במחלוקת במיוחד?

תשובה אפשרית: כי אין בה זכות יסוד מול אינטרס, אלא שאלה של "תקינות שלטונית" — ובית המשפט מכריע בשאלה פוליטית מובהקת (הרכב הממשלה) לפי הערכתו את אמון הציבור. תומכים — מאבק בשחיתות; מתנגדים — "גידול פרא" שאינו נגזר מעקרונות מסודרים.

פרק 12

עילת המידתיות ומשקל ראוי לזכויות יסוד

12.1 מבוא — למה זה חשוב ומה מקומו בתמונה הגדולה

עילת המידתיות נכנסה למשפט המנהלי בעקבות חוקי היסוד של 1992, והפכה לכלי המרכזי לבחינת החלטות שפוגעות בזכויות. היא בוחנת את **היחס בין האמצעי לבין המטרה**: האם האמצעי מקדם את המטרה, האם יש אמצעי פוגעני פחות, והאם התועלת מצדיקה את הנזק. בפרק נלמד את שלושת מבחני המשנה, את יישומם בבן עטיה ובבית סוריק (כולל "המידתיות היחסית"), את השאלה הקשה — **מה ההבדל בין מידתיות לסבירות** — ואת העילה הקרובה: **אי-מתן משקל ראוי לזכויות יסוד**. נסיים במפה: איך משלבים בתיק אחד שיקולים זרים, שוויון, סבירות ומידתיות.

12.2 המקור — פסקת ההגבלה

§ סעיף — 8 לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו

"אין פוגעים בזכויות שלפי חוק-יסוד זה אלא בחוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל, שנועד לתכלית ראויה, **ובמידה שאינה עולה על הנדרש**, או **לפי חוק כאמור מכוח הסמכה מפורשת בו**."

"לפי חוק" — כלומר גם **החלטה של הרשות המבצעת** שפועלת מכוח חוק חייבת לעמוד בדרישה "במידה שאינה עולה על הנדרש". מכאן עילת המידתיות במשפט המנהלי. (גם לפני חוקי היסוד הייתה המידתיות קיימת ברקע — היא "נוהגת במשפט ישראל מאז ומתמיד", אך "לא זכתה למעמד ולמשקל הראויים לה".)

12.3 בן עטיה נ' שר החינוך (בג"ץ 3477/95)

⚖ פסק דין — עובדות והכרעה

העובדות: משרד החינוך הנהיג רפורמה: בכמה מקצועות שנבחרו בהגרלה, התלמידים מקבלים את **הציון הפנימי** של בית הספר במקום בחינת בגרות. בתי ספר שבהם התגלו בעבר בעיות בטוהר הבחינות (העתקות) — הוחרגו מההקלה. בנם של בני הזוג עטיה למד בבית ספר כזה, ונאלץ להיבחן גם במקצוע שעלה בהגרלה. העתירה התקבלה.

השופט ברק: ההחלטה אינה סבירה (אינה הגיונית ופוגעת בשוויון בין התלמידים) — וגם **אינה מידתית**: "עקרון המידתיות — **כאחיו הבכור עקרון הסבירות** — מחייב קונקרטיזציה... הוא מורכב משלושה יסודות, או מבחני משנה":

מבחן	תוכן (בלשון ברק)	היישום בבן עטיה
1. התאמה (קשר רציונלי)	"האמצעי צריך להוביל באופן רציונלי להגשמתה של המטרה"	**נכשל:** אין קשר בין העתקות בעבר (בבגרות החיצונית) לבין הבטחת טוהר הבחינות בעתיד אצל תלמידים אחרים, ובבחינה פנימית
2. האמצעי שפגיעתו פחותה	"החייט המינהלי צריך לתפור את החליפה המינהלית... תוך בחירה באמצעי הפוגע פחות משגיחים, להסביר ולחנך באדם"	**נכשל:** אפשר להגביר פיקוח, להוסיף
3. מידתיות במובן הצר	"יחס ראוי בין התועלת לציבור לבין הנזק לאזרח... אם יגרום... נזק כבד לאזרח, ואילו התועלת הצפויה לציבור אינה אלא מזערית — מזערית אסור"	**נכשל:** נזק לתלמידים, למורים שלא חטאו, למוניטין של בית הספר — מול תועלת

הקריאה: החלטה מידתית — רק אם עומדת ב**כל** שלושת המבחנים. מנקודת מבטו של העותר — די בכישלון באחד מהם כדי לפסול.

12.4 בית סוריק נ' ממשלת ישראל (בג"ץ 2056/04) — מידתיות יחסית

(הרקע — פרק 1.) בקטע מסוים, תוואי הגדר עבר בין הכפר למטעי הזיתים שלו, כדי שכיפה שולטת ("ג'בל") תישאר בצד הישראלי. התושבים הציעו להזיז את התוואי ולהציב שער ושמירה.

- **מבחן 1 — עומד:** הגדר מקדמת את המטרה (מניעת מעבר מחבלים).
- **מבחן 2 — עומד:** ברק קבע שיש **להגדיר את המטרה ואת רמת ההישג הנדרשת**, ורק אז לשאול אם יש אמצעי פוגעני פחות **שמשיג אותה רמה**. לפי המפקד הצבאי — התוואי החלופי משיג פחות ביטחון; לכן התוואי שנבחר הוא האמצעי שפגיעתו פחותה **לאותה רמת ביטחון**.
- **מבחן 3 — נכשל, ב"בחינה יחסית":** "מקובל ליישם [את המבחן] ב'ערכים מוחלטים'... אולם ניתן גם להפעיל בחינה 'יחסית'... הפעולה השלטונית המקורית תהא בלתי מידתית... אם **הפחתה מסוימת ביתרון**... באמצעות נקיטת החלופה האפשרית, תבטיח **הפחתה משמעותית בנזק**." תוספת ביטחון קטנה אינה שווה את הנזק הגדול לפרנסת התושבים. התוואי נפסל.

12.5 יישומים נוספים

- **יורונט (פרק 7):** פגיעה "קשה מאוד, אם לא אנושה" בחופש העיסוק, כשהיו חלופות פוגעניות פחות — לא מידתית; מוזכרת כאחת מאבני הדרך של המידתיות במשפט המנהלי.
- **אל-טאיי נ' שר הפנים (1995):** אזרחים עיראקים שנכנסו שלא כדין הוחזקו במשמורת עד גירושם, חודשים ושנים. נדרש איזון בין **משך ההחזקה** לבין צורכי הביטחון — החזקה ממושכת ללא תכלית ממשית אינה מידתית.
- **נציגות הבית המשותף ברח' השונית 10 בהרצליה נ' משרד התיירות (עע"מ 1036/16):** מתווה שחייב רוכשי "דירות נופש" להעמידן לשימוש הציבור (השכרה מלונאית) — הרוב (דנציגר): זכות הקניין של הרוכשים מוגבלת מלכתחילה (דירה שנועדה לנופש ציבורי חלק ניכר מהשנה), והמתווה עומד בשלושת המבחנים; המיעוט (שהם): אינו האמצעי שפגיעתו פחותה. מדגים שהיישום תלוי ב**נקודת המוצא** — היקף הזכות.

12.6 מידתיות מול סבירות — האם יש הבדל?

ברק בבן עטיה: "במובן מסוים ניתן לראות בעילת המידתיות '**ענף בעץ אי-הסבירות**'. במובן אחר ניתן לראות בה עילה עצמאית... שלב נוסף ועצמאי בפיתוח תורת שיקול הדעת המינהלי ובעידונה של עילת הסבירות".

מבחן מידתיות	המקבילה בסבירות
1. התאמה בין אמצעי למטרה	סבירות "צרה" (דיזנגוף) — החלטה לא הגיונית. כל מה שאין בו התאמה — גם אינו הגיוני
3. התועלת מול הנזק	סבירות "רחבה" — איזונית (דקה, דפי זהב): משקל ראוי לשיקולים
2. האמצעי שפגיעתו פחותה	**כאן אולי ההבדל:** במידתיות — חובה לבחור את האמצעי הפוגעני **ביותר פחות**; בסבירות — די לבחור **אחת** מההחלטות שבתוך מתחם הסבירות

השערה: מידתיות עוסקת בעיקר בפגיעה ב**זכויות**, ולכן מחמירה; סבירות עוסקת בכל איזון בין אינטרסים, ולכן מקלה. **אבל** — גם במידתיות הכיר ברק ב"**מתחם התחשבות**" (מתחם מידתיות): "בהפעלת עקרון המידתיות — ובעיקר בבחינת האמצעי שפגיעתו פחותה — יש להכיר במרחב התמרון של הרשות... מתחם זה דומה למתחם הסבירות". כלומר — ייתכן שאין הבדל של ממש; כל מה שנפסל בסבירות — נפסל גם במידתיות, ולהפך.

אז למה קידם ברק את המידתיות?

- לייחד עילה מיוחדת ל**פגיעה בזכויות יסוד** — ואולי להפעיל בה מבחנים מחמירים;
- היא נשענת על **חוק יסוד** — לגיטימיות רבה יותר;
- אחידות מושגית עם ה**משפט הבינלאומי** ושיטות זרות (קנדה, גרמניה).

(ובתקופה האחרונה, כשעילת הסבירות נתונה בביקורת, המידתיות מקבלת משקל גדל.)

12.7 אי-מתן משקל ראוי לזכויות יסוד

אפשר לתקוף החלטה מנהלית גם בטענה שמקבל ההחלטה **לא נתן משקל ראוי לזכות יסוד** — כטענה עצמאית. זה אזור החפיפה בין המשפט החוקתי (זיהוי הזכות — מנויה או נגזרת) לבין המנהלי (המשקל בהחלטה). שלוש העילות דומות מאוד, ובתיק אחד אפשר לטעון את שלושתן במצטבר או לחלופין.

דוגמה — סירוב להתיר הפגנה ליד בית ראש הממשלה בשל חשש להפרת הסדר:

עילה	הניסוח
חוסר סבירות	לא ניתן משקל נכון לשיקולים הרלוונטיים — חופש הביטוי מול הסדר הציבורי
חוסר מידתיות	לא נבחר האמצעי שפגיעתו בחופש הביטוי פחותה (הגבלת שעות, מקום, מספר משתתפים); והנזק לחופש הביטוי עולה על התועלת לסדר
אי-מתן משקל ראוי לזכויות יסוד	לא ניתן משקל ראוי לזכות היסוד לחופש הביטוי

12.8 מפה — שילוב העילות בתיק אחד

קצין התגמולים נ' פלוני (עע"מ 7335/10): חייל שנפגע ב-1998 הוכר כנכה צה"ל רק ב-2006. ההטבות לפי **חוק הנכים** ניתנו מיום הפגיעה; אבל ההטבות לפי **הוראות פנימיות** — רק מיום ההכרה. בית המשפט קיבל את העתירה, בשלוש עילות במקביל:

- **פגיעה בשוויון** — הבחנה בין נפגעים לפי משך ההליך עד ההכרה, שאינה **שוני רלוונטי**;
- **חוסר סבירות** — משקל גדול מדי לשיקול התקציבי ומשקל קטן מדי לשוויון;
- **חוסר מידתיות** — לא נבחר האמצעי שפגיעתו פחותה.

פגם	מבסס גם...
הפליה מטעם חשוד (דת, גזע, מין)	שיקול זר + סבירות + מידתיות + משקל ראוי לזכויות
הפליה "מנהלית" (יחס שונה למצבים זהים)	סבירות + מידתיות + משקל ראוי (לא בהכרח שיקול זר)
היעדר תשתית עובדתית / חלופות	מידתיות (מבחן 2) — יורונט

12.9 מלכודות נפוצות

! שים לב — מלכודות נפוצות

- לחשוב שמספיק שהאמצעי מקדם את המטרה — צריך לעבור את שלושת המבחנים.
- לבחון "אמצעי שפגיעתו פחותה" בלי להגדיר קודם את רמת ההישג הנדרשת (בית סוריק).
- לשכוח את "הבחינה היחסית" במבחן השלישי.
- לחשוב שבמידתיות אין מרחב לרשות — יש "מתחם התחשבות".
- לחשוב שאפשר לטעון רק עילה אחת — בדרך כלל טוענים כמה במצטבר.

12.10 שלד לפתרון שאלה — מבחני המידתיות

1. **זהו את הזכות הנפגעת** (עיסוק, קניין, ביטוי, חירות) ואת המטרה שהרשות ביקשה להשיג.
2. **מבחן ההתאמה:** האם יש קשר רציונלי בין האמצעי למטרה? אם האמצעי אינו משרת את המטרה – ההחלטה נכשלת כבר כאן (בן עטיה).
3. **מבחן האמצעי שפגיעתו פחותה ("החייט המינהלי"):** הגדירו את המטרה ואת רמת ההישג הנדרשת, ובדקו אם יש אמצעי פוגעני פחות שמשיג אותה רמה. זכרו את "מתחם ההתחשבות".
4. **מידתיות במובן הצר:** השוו תועלת לנזק; בחינה יחסית – האם חלופה שתועלתה פחותה במעט מפחיתה נזק משמעותית (בית סוריק)?
5. **הוסיפו עילות:** משקל ראוי לזכויות יסוד, סבירות ושוויון – לעיתים יחד. לעותר מספיק לכשול במבחן אחד.

12.11 מלכודות בפתרון שאלות — טבלה

הטעות	למה היא שגויה	התיקון
לדלג על הגדרת המטרה	בלי מטרה ורמת הישג אי אפשר לבחון חלופות (בית סוריק)	להגדיר מטרה ורמת הישג

לדרוש שההחלטה תיכשל בכל המבחנים	לרשות המבחנים מצטברים; לעותר מספיק כשל באחד	להצביע על המבחן הרלוונטי
לטעון שהרשות חייבת את האמצעי הפוגעני הפחות בכל מקרה	יש "מתחם התחשבות" ויכולות כמה דרכים לציין את המתחם	
לבלבל מידתיות במובן הצר עם אמצעי פחות פוגעני	האחרון בוחן חלופות; הצר משווה תועלת לנזק	להפריד בין המבחנים
לעבור מיד למידתיות בלי לזהות זכות	המידתיות פועלת בעיקר כשנפגעת זכות; לזהות את הזכות והיקפה	להתחיל בזכות

12.12 תרגיל פתור — סגירת דרך

✎ דוגמה — סגירת רחוב לשם שמירה על הסדר

העובדות: רשות סגרה רחוב ראשי לפני אירוע ציבורי למשך שלושה שבועות, בנימוק של מניעת הפרות סדר. הסגירה פגעה קשה בעסקי הרחוב. בעלי העסקים עותרים.

הפתרון:

1. **מטרה:** מניעת הפרות סדר בזמן האירוע; רמת ההישג – סדר בטווח שעות האירוע.
2. **התאמה:** סגירה בשעות האירוע קשורה למטרה; סגירה של שלושה שבועות רחבה בהרבה.
3. **אמצעי פחות פוגעני:** סגירה רק בשעות האירוע, הפניית תנועה, סידורי אבטחה – משיגים רמת סדר דומה.
4. **מידתיות במובן הצר:** התועלת (סדר מעט גבוה יותר) קטנה מהנזק (פגיעה בפרנסה); בבחינה יחסית – הפחתה מעטה בסיכון חוסכת נזק גדול.
5. **מסקנה:** ההחלטה אינה מידתית; ייתכן צמצום הסגירה. נוסף: פגיעה בחופש העיסוק ללא משקל ראוי.

12.13 סיכום הפרק

✔ **שורה תחתונה — סיכום הפרק**

- מקור: פסקת ההגבלה בס' 8 לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו; בן עטיה הרחיב למשפט המנהלי.
- שלושה מבחני משנה: התאמה, אמצעי שפגיעתו פחותה, מידתיות במובן הצר; מצטברים לרשות, חלופיים לעותר.
- בית סוריק: הגדרת המטרה ורמת ההישג ואז חלופות; בחינה יחסית.
- מידתיות וסבירות: סבירות היא "אחיו הבכור"; מקבילות: התאמה = היגיון; מובן צר = איזון; הבדל עיקרי בחלופות; מתחם התחשבות.
- אי-מתן משקל ראוי לזכויות יסוד: טענה עצמאית או מצטברת.

12.14 מילון מושגים

- **מבחן ההתאמה** — קשר רציונלי בין אמצעי למטרה.
- **האמצעי שפגיעתו פחותה** — "החייט המינהלי".
- **מידתיות במובן הצר** — יחס ראוי בין תועלת לנזק.
- **בחינה יחסית** — השוואה לחלופה שמפחיתה מעט את התועלת ומפחיתה הרבה את הנזק.
- **מתחם ההתחשבות** — מרחב התמרון של הרשות במידתיות.

12.15 נקודות מפתח למבחן

✔ **שורה תחתונה — עיקרי הפרק**

- ס' 8 לחוק יסוד: כבוד האדם — "במידה שאינה עולה על הנדרש" חל גם על החלטות מכוח חוק.
- בן עטיה: שלושת המבחנים; "אחיו הבכור — הסבירות"; נכשל בשלושתם.
- בית סוריק: הגדרת רמת ההישג; מבחן 2 עמד; מבחן 3 נכשל בבחינה יחסית.
- יורונט, אל-טאיי, השונית 10.
- מידתיות מול סבירות: "ענף בעץ אי-הסבירות"; ההבדל האפשרי — מבחן 2; אבל "מתחם התחשבות"; למה ברק קידם אותה.
- משקל ראוי לזכויות יסוד — עילה עצמאית; שילוב עילות (קצין התגמולים נ' פלוני).

12.16 שאלות בסגנון המבחן

✎ דוגמה — שאלה בסגנון המבחן (1)

כדי להפחית רעש, עירייה אסרה כל אירוע מוזיקלי בפארק העירוני, בכל שעות היממה. התברר שהגבלת האירועים לשעות היום הייתה משיגה כמעט את אותה תועלת. באיזה מבחן נכשלת ההחלטה?

א. מבחן ההתאמה. ב. מבחן האמצעי שפגיעתו פחותה. ג. אין כישלון — יש קשר רציונלי. ד. מבחן השיהוי.

התשובה וההסבר

ב. יש אמצעי פוגעני פחות שמשיג (כמעט) את אותה רמת תועלת. יש קשר רציונלי (א' עומד), ולכן ג' אינה מספיקה.

✎ דוגמה — שאלה בסגנון המבחן (2)

לפי בית סוריק, מתי אמצעי ייחשב בלתי מידתי במבחן השלישי ב"בחינה יחסית"?

א. כשהוא אינו מקדם את המטרה. ב. כשחלופה שמפחיתה מעט את התועלת מפחיתה באופן משמעותי את הנזק. ג. כשיש לו עלות כספית. ד. כשלא נערך שימוע.

התשובה וההסבר

ב. א' — מבחן 1; ד' — עילה פרוצדורלית.

12.17 שאלות לחשיבה

1. אם אין הבדל של ממש בין מידתיות לסבירות — למה לטעון את שתיהן?

תשובה אפשרית: כי בפועל בתי המשפט מפעילים אותן בעוצמות שונות: המידתיות מובנית יותר (שלושה מבחנים), נשענת על חוק יסוד ומתמקדת בזכויות — ולכן לעיתים מצליחה במקום שהסבירות (שנתונה כיום בביקורת) נכשלת. עורך דין זהיר יטען את שתיהן.

2. האם ראוי שבית המשפט יכריע ב"רמת הביטחון הנדרשת" כבבית סוריק?

תשובה אפשרית: ברק השאיר את הגדרת רמת ההישג למפקד הצבאי, ובחן רק אם האמצעי משיג אותה בפגיעה פחותה — ריסון מוסדי. ההכרעה הערכית הגיעה רק במבחן השלישי, שם בית המשפט קבע שתוספת ביטחון קטנה אינה מצדיקה נזק גדול.

פרק 13

עילות הסף וערכאות השיפוט — בג"ץ ובית המשפט לעניינים מנהליים

13.1 מבוא — למה זה חשוב ומה מקומו בתמונה הגדולה

לפני שבית המשפט בוחן אם ההחלטה פגומה, העותר צריך לעבור שני "שערים": (1) לפנות ל**ערכאה הנכונה** — בג"ץ או בית המשפט לעניינים מנהליים — בהליך הנכון (עתירה, ערעור או תובענה); (2) לעמוד ב**עילות הסף**, שמאפשרות לדחות עתירה **על הסף** בלי לדון בה לגופה. בפרק נלמד את שניהם — נושא שמופיע הרבה בשאלות מבחן, ולעיתים נבחן ממש לפי לשון החוק.

13.2 חלק א': הערכאות

13.3 שתי הערכאות

	בג"ץ	בית המשפט לעניינים מנהליים
מהו	בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק — "בית המשפט המנהלי של המדינה"	בית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים ("מיני-בג"ץ"); הוקם ב-**2000** להקלת העומס על בג"ץ
מעמד ערכאה ראשונה ואחרונה; **עותרים** (לא מערערים); אין ערעור — אפשר רק לבקש **דיון נוסף** (לא זכות מוקנית)		על פסק דינו — **ערעור לבית המשפט העליון**
סמכות	**שיורית** — מה שלא בסמכות ערכאה אחרת	לפי **חוק בתי משפט לעניינים מנהליים, התש"ס–2000** והתוספות לו

חשוב: הבחירה בין הערכאות אינה לפי רצון העותר או עורך דינו — היא **קבועה בחוק**.

13.4 בית המשפט לעניינים מנהליים — שלושה הליכים (ס' 5)

הליך	מתי	דוגמאות	ערעור לעליון
עתירה מנהלית	בעניינים שב**תוספת הראשונה**	חופש המידע, ארנונה, חינוך, רישוי עסקים, רישיונות נשק, עובדים זרים ואשרות שהייה	**בזכות**
ערעור מנהלי	בעניינים שב**תוספת השנייה**	ערעור על רשם האגודות השיתופיות; על בית הדין לביקורת משמורת של שוהים שלא כדין; על **שלילת רישיון נהיגה מטעמים רפואיים** (ס' 55א לפקודת התעבורה)	**ברשות** (כי זו כבר ערכאה שנייה)
תובענה מנהלית	בעניינים שב**תוספת השלישית**	תביעת **פיצויים** שעילתה במכרז (המכרז כבר בוצע, ואי אפשר לבטלו)	**בזכות**

- **ס' 6 — העברה לבג"ץ:** בית המשפט לעניינים מנהליים רשאי — מיוזמתו, לבקשת בעל דין או לבקשת היועמ"ש — להעביר עתירה לבג"ץ אם יש בה **חשיבות מיוחדת, רגישות מיוחדת או דחיפות מיוחדת** (אחרי שמיעת עמדות הצדדים).
- **ס' 9 — צו ביניים:** סעד זמני שמקפיא את המצב עד ההכרעה; לעיתים — **צו ביניים ארעי** על סמך בקשת העותר בלבד, לפני תגובת המשיבה. קריטי כשיש פעולה שעומדת להתבצע (צו הריסה, צו גירוש); חסר טעם אם הפעולה כבר בוצעה (הסעות שכבר הופסקו).

13.5 בג"ץ — הסמכות

§ סעיף — 15(ג) לחוק יסוד: השפיטה — הסמכה כללית

בג"ץ ידון "בעניינים אשר הוא רואה צורך לתת בהם **סעד למען הצדק** ואשר אינם בסמכותו של בית משפט או של בית דין אחר" — שני תנאים מצטברים: (1) לא בסמכות ערכאה אחרת; (2) צורך בסעד למען הצדק. זו גם הסיבה שסמכותו **שבשיקול דעת** — ומכאן עילות הסף.

§ סעיף — 15(ד) — ארבע הסמכות ספציפיות

(קודם בודקים את הספציפיות; אם אף אחת אינה מתאימה — חוזרים לכללית):

#	הצו	כלפי מי	מתי
1	**הביאס קורפוס** ("הביאו את גופו")	מי שמחזיק אדם	שחרור מי שנעצר או נאסר שלא כדין — חשיבות יתרה מאז שהחירות הפכה לזכות יסוד (ס' 5 לחוק יסוד: כבוד האדם)
2	**מנדמוס** (צו עשה / אל תעשה)	רשויות המדינה, רשויות מקומיות ופקידיהן, וגופים ואנשים הממלאים **תפקיד ציבורי על פי דין** (שני תנאים: תפקיד בעל אופי ציבורי + על פי דין)	לפעול לפי חובותיהם. (מפעל הפיס — זיכיון לפי דין, ייעוד ציבורי: כן; פעילות וולונטרית שאינה לפי דין: לא)
3	**צו לבתי משפט ובתי דין ייחודיים**	בית הדין לעבודה, תעבורה, נוער, משפחה וכו' — **לא** שלום, מחוזי, עליון, ולא בתי דין דתיים	ערכאת **פיקוח**, לא ערעור; מתערב רק ב**טעות מהותית**
4	**צו לבתי הדין הדתיים**	בתי הדין הרבניים ושאר הדתיים	רק ב**חריגה מסמכות** (צר מהשלישי)

צו על תנאי: כל עתירה בבג"ץ נפתחת ב**בקשה לצו על תנאי** — צו המורה למשיב לבוא ולנמק מדוע לא יעשה (או ייעשה) כמבוקש. אם הנימוקים מקובלים — העתירה נדחית; אם לא — הצו נעשה **מוחלט**. **צו ביניים** — קיים בשתי הערכאות.

צו	בג"ץ	בית משפט לעניינים מנהליים
צו על תנאי	✓ (חובה — כל עתירה)	✗
צו ביניים	✓	✓

13.6 חלק ב': עילות הסף

13.7 למה יש עילות סף?

זכות הגישה לערכאות היא זכות יסוד (ארפל אלומיניום). אבל במשפט הציבורי היא **מסוגת**: סמכות בג"ץ — שבשיקול דעת ("למען הצדק"). עילות הסף הן **יצירה שיפוטית** (לא בחוק); חלקן עוסקות ב**עותר** (שיהוי, ניקיון כפיים), חלקן ב**נושא** (שפיטות).

המחיר	התועלת
פגיעה בזכות הגישה; החלטה ויסות עתירות ומניעת "הצפה"; סינון עותרים טורדניים (גם בהוצאות); פגומה עלולה להישאר בתוקף יעילות ושמירה על זמן שיפוטי; סדר ומניעת שרירות; והגנה על הלגיטימיות המוסדית של בית המשפט	

(דחייה על הסף — בהרכב של שלושה שופטים.)

13.8 זכות עמידה

במובן הקלאסי (שנות ה-60): רק מי ש**נפגע באופן ישיר**. **רסלר נ' שר הביטחון (בג"ץ 910/86):** חיילי מילואים — הפטור לבחורי ישיבות **מגדיל את הנטל** עליהם — נפגעים במשתמע, ולהם זכות עמידה; ובהמשך — הכרה ב**עותר הציבורי** (ארגונים, חברי כנסת).

הסייג לעותר ציבורי: כשיש **נפגע ישיר** שלא פנה בעצמו ולא ביקש להצטרף — הנטייה לדחות ("**רב על ריב לא לו**"):

- **קורן נ' שר הביטחון:** עתירה לחייב פינוי אלון מורה — לעותר אין זיקה; נדחתה.
- **אמסלם נ' שר הביטחון (2021):** חבר כנסת עתר לחייב את השר לחתום על מינוי מנכ"ל התעשייה האווירית — המועמד עצמו (הנפגע הישיר) כבר פנה בעצמו; העתירה נדחתה על הסף.
- מנגד — **בוקובזה נ' שר החינוך:** עותר בלי זיקה אישית לתקצוב מוסדות חינוך — בית המשפט **דן**. המסקנה: בשיקול דעת.

13.9 שפיטות

סוג	השאלה	המצב
נורמטיבית (שאלת הכלים)	האם יש לבית המשפט נורמות וכלים להכריע?	מאז שהסבירות הפכה לעילה עצמאית — כמעט **הכל שפיט נורמטיבית**
מוסדית (שאלת הכדאיות)	האם בית המשפט הוא המוסד המתאים? האם הדיון יפגע באמון הציבור בו?	נשארת שיקול, בעיקר בעתירות פוליטיות

מאז שנות ה-80 הורחבו זכות העמידה והשפיטות — מה שאיפשר את האקטיביזם השיפוטי.

13.10 פנייה מוקדמת ומיצוי הליכים

- **פנייה מוקדמת:** לפני עתירה — לפנות לרשות עצמה, כדי לצמצם את המחלוקת. פנייה **אישית וישירה**; פנייה כללית, דרך גורם עקיף או לכמה גורמים — לא מספיקה; לעיתים נדרשות כמה פניות.
- **מיצוי הליכים:** לנצל את כל האפיקים האחרים לפני בג"ץ (שהוא החלופה האחרונה). מול הרשות — ערר לוועדה רפואית בביטוח לאומי; השגה בחוק רישוי עסקים. מול ערכאה — ערעור לבית משפט לתעבורה על שלילה מנהלית (ס' 48 לפקודת התעבורה); ערעור לבית הדין הרבני הגדול לפני עתירה נגד בית דין אזורי.
- **אמסלם נ' היועמ"ש:** עתירה בעניין "הצבעה כפולה" במליאה — נדחתה כי כבר **נפתחה חקירה**: ההליך המתאים קיים ופועל.

13.11 שיהוי — שלושה יסודות

במשפט המנהלי אין התיישנות — יש **שיהוי**. בבג"ץ — אין מועד קבוע; בבית המשפט לעניינים מנהליים — **תקנה 3(ב)**: **45 ימים** מהמוקדם מבין: פרסום ההחלטה כדין, קבלת הודעה עליה, או שנודע לעותר עליה (וגם בתוך 45 ימים — כפוף לשיהוי).

יסוד	השאלה
שיהוי סובייקטיבי	האם יש לעותר **צידוק** לאיחור?
שיהוי אובייקטיבי	האם הדיון עכשיו יגרום **נזק** למשיבה או לצדדים שלישיים תמי לב? (אפשר לדחות גם בלי אשמת העותר — בניין מגורים מאוכלס שמונה שנים)
הפגיעה בשלטון החוק	פגם חמור ושורשי (חריגה מסמכות, שחיתות) — הנטייה לדון **חרף** השיהוי

- **לשכת עורכי הדין נ' שר המשפטים (בג"ץ 8684/20):** תקנות סדר הדין האזרחי פורסמו ב-2018, לכניסה לתוקף ב-1.1.2021; הלשכה שותפה בגיבושן — ועתרה שבועיים וחצי לפני התחילה. סובייקטיבי — אין צידוק; אובייקטיבי — נזק כבד למתדיינים; שלטון החוק — לא הוצבע על פגם מהותי. נדחתה על הסף.
- **בית אריזה רחובות נ' שר החקלאות:** בשל השיהוי, חברה אחרת (יכין) זכתה והחלה לפעול — **מעשה עשוי** ונזק לצד שלישי.

13.12 בשלות (עתירה מוקדמת)

העתירה צריכה להיות **בשלה** — מחלוקת קונקרטית "כאן ועכשיו", לא תרחיש עתידי. רלוונטי בעיקר בעתירות נגד חוקים. **שני שלבים:** (1) האם נדרשת תשתית עובדתית נוספת — למשל, יישום החוק — או שלשונו מספיקה (לשון גזענית — אין צורך לחכות)? (2) אם העתירה מוקדמת — האם יש **אינטרס ממשי** לדון בה בכל זאת?

- **סבח נ' הכנסת (בג"ץ 2311/11, תשעה שופטים):** תיקון לפקודת האגודות השיתופיות התיר ועדות קבלה ביישובים קהילתיים, שרשאיות לסרב למועמד שאינו מתאים "לחיי החברה" או "למרקם החברתי-תרבותי" (לצד איסור הפליה). הרוב (5): העתירה מוקדמת — יש לבחון את היישום; ואין אינטרס לדון עכשיו. נדחתה על הסף.

- **חסון נ' הכנסת (חוק יסוד: הלאום, 2021):** הכנסת טענה לחוסר בשלות. בית המשפט דן — גם אם נדרש יישום, יש **אינטרס ממשי** לדון בשאלה העקרונית אם אפשר לבחון חוק יסוד (ונקבע שבית המשפט יתערב רק בפגיעה בליבת העקרונות היהודיים והדמוקרטיים; העתירות נדחו לגופן).

13.13 ניקיון כפיים, עתירה תלויה ועומדת, מעשה עשוי, עתירה תיאורטית

- **ניקיון כפיים:** "אין צדק בידיים לא נקיות". העותר חייב לגלות הכל — כל עתירה נתמכת ב**תצהיר**. הסתרה (אפילו של מכתב שנשלח ותשובה שהתקבלה) — עלולה להוביל לדחייה. ועותר שבעצמו מפר את הדין (סגר מרפסת בלי היתר ועותר נגד השכן). **זילכה נ' ראש עיריית חולון:** בקשה לרישיון למכונות מזל שנדחתה שלא כדין — נדחתה על הסף בשל חוסר ניקיון כפיים.
- **עתירה תלויה ועומדת** (עילה חדשה יחסית): **כספי** (2021–2022) — בתקופת הקורונה הוגשו כמה עתירות נפרדות באותו עניין; נקבע שיש להצטרף לעתירה הקיימת, אחרת — דחייה על הסף. **אלימלך נ' משטרת ישראל** — שכן של ראש הממשלה דאז עתר נגד התנהלות המשטרה בהפגנות, כשהיו כבר עתירות של שכנים אחרים; נדחתה. אבל **התנועה לאיכות השלטון נ' מבקר המדינה (2024):** "הגיעה העת להשתחרר מהלכת כספי" כהלכה מחייבת — לשופט שיקול דעת לבחור כלים אחרים (איחוד, הזמנה להצטרף).
- **מעשה עשוי** — הפעולה כבר בוצעה (הבית נהרס) — אין טעם בצו; אולי פיצויים בהליך אחר.
- **עתירה תיאורטית** — שאלה חשובה שאינה "על השולחן" (שמאי הביטוח, פרק 5).

סיכום: עילות הסף נתונות ל**שיקול דעת** רחב — אם בית המשפט ירצה לדון, ידון (בוקובזה, חסון); אם לא — ידחה. מגמה בעשור האחרון: עלייה בשימוש בעילות הסף, ופיתוח עילות חדשות.

13.14 מלכודות נפוצות

! שים לב — מלכודות נפוצות

- לחשוב שמערערים לבג"ץ — עותרים; ואין ערעור על בג"ץ (רק דיון נוסף).
- לחשוב שבוחרים ערכאה לפי רצון — לפי החוק והתוספות.
- לבלבל בין עתירה (תוספת 1), ערעור (תוספת 2) ותובענה (תוספת 3).
- לחשוב שבבית המשפט לעניינים מנהליים יש צו על תנאי — רק בבג"ץ.
- לחשוב שבג"ץ הוא ערכאת ערעור על בית הדין לעבודה — הוא ערכאת פיקוח (עתירה).
- לשכוח את היסוד השלישי בשיהוי — פגם חמור עשוי "להציל" עתירה מאוחרת.

13.15 שלד לפתרון שאלה — לאן פונים ואם עומדים בסף

1. **קבעו פורום:** לפי חוק בתי משפט לעניינים מנהליים ותוספותיו – עתירה, ערעור או תובענה מנהלית; או בג"ץ (ס' 15(ג), 15(ד)) או בית דין מתמחה (למשל בית הדין לעבודה בנושאי ביטוח לאומי).
2. **זכות עמידה:** האם העותר נפגע ישירות או במשתמע (רסלר), או עותר ציבורי? אם יש נפגע ישיר שלא פנה – חשש מ"רב על ריב לא לו".
3. **שפיטות:** נורמטיבית (יש כלים משפטיים להכרעה) ומוסדית (האם בית המשפט הוא המוסד המתאים).
4. **פנייה מוקדמת ומיצוי הליכים; בשלות; עתירה תלויה ועומדת; מעשה עשוי; עתירה תיאורטית.**
5. **שיהוי (שלושה יסודות) וניקיון כפיים:** סובייקטיבי, אובייקטיבי, שלטון החוק; האם העותר הסתיר עובדות או פעל בידיים לא נקיות?

13.16 מלכודות בפתרון שאלות — טבלה

הטעות	למה היא שגויה	התיקון

להגיש בג"ץ כשיש ערכאה מתאימה	סעד "למען הצדק" ניתן רק בעניין שאינו בסמכות ערכאה אחרת (15(ג))	לבדוק את התוספות לחוק
לחשוב שיש ערעור בזכות על פסק דין של בג"ץ	בג"ץ ערכאה ראשונה ואחרונה; אפשר בקשה לדיון נוסף שאינה זכות	לא "ערעור" אלא עתירה/דיון נוסף
לבלבל פנייה מוקדמת עם מיצוי הליכים	הראשונה לרשות עצמה, השנייה לאפיקים משפטיים אחרים	להפריד
להתעלם מהיסוד האובייקטיבי בשיהוי	גם עותר שאינו אשם עלול להידחות בשל נזק לצדדים שלישיים	לבחון שלושה יסודות
להניח שעותר ציבורי תמיד נדחה	הרחבת זכות העמידה מאפשרת עותר ציבורי; דחייה כשיש נפגע ישיר שלא פנה	לבדוק מי הנפגע הישיר

13.17 תרגיל פתור — עתירה שאיחרה

✎ דוגמה — עתירה נגד החלטה ישנה

העובדות: עיריית מרכז העיר אישרה לפני שלוש שנים היתר בנייה, והבניין כבר נבנה ואוכלס. ארגון חברתי, שלא נפגע ישירות, מגיש כעת עתירה לביטול ההיתר בטענה לחוסר סבירות. מיד אחרי ההגשה נטען גם שהארגון לא פנה לעירייה לפני כן.

הפתרון:

1. **פורום:** עתירה מנהלית בבית המשפט לעניינים מנהליים (תוספת 1), לא בג"ץ.
2. **עמידה:** עותר ציבורי – ייתכן, אם אין נפגע ישיר שיכול לעתור.
3. **פנייה מוקדמת:** לא פנה לרשות – פגם שיכול להצדיק דחייה או השהיה.
4. **שיהוי:** שלושה יסודות – סובייקטיבי (אין צידוק להמתנה של שלוש שנים), אובייקטיבי (נזק לדיירים תמי לב ולעירייה), שלטון החוק (פגם חמור?). אם אין פגם מהותי בולט – סביר שהעתירה תידחה.
5. **מעשה עשוי:** הבניין מאוכלס – ביטול כמעט בלתי אפשרי.
6. **מסקנה:** העתירה נדחית על הסף, אלא אם הפגם חמור במיוחד.

13.18 סיכום הפרק

✔ **שורה תחתונה — סיכום הפרק**

- בג"ץ – ערכאה ראשונה ואחרונה (ס' 15(ג) סעד למען הצדק; 15(ד) ביאס קורפוס, מנדמוס, בתי דין); דיון נוסף אינו זכות.
- בית המשפט לעניינים מנהליים (2000): עתירה, ערעור, תובענה; ערעור ברשות בערעור מנהלי; ס' 6 העברה לבג"ץ.
- עילות הסף: עמידה (רסלר – עותר ציבורי), שפיטות, פנייה מוקדמת ומיצוי, שיהוי (שלושה יסודות), בשלות (סבח/חסון), ניקיון כפיים, עתירה תלויה ועומדת, מעשה עשוי, תיאורטית.
- מועד: 45 ימים, כפוף לשיהוי.

13.19 מילון מושגים

- **צו על תנאי** — צו לבוא ולנמק; פותח כל עתירה בבג"ץ.
- **צו ביניים** — הקפאת המצב עד ההכרעה.
- **עותר ציבורי** — ארגון או חבר כנסת ללא נגיעה אישית.
- **"רב על ריב לא לו"** — עותר בלי זיקה כשיש נפגע ישיר.
- **שפיטות נורמטיבית / מוסדית** — האם יש כלים / האם ראוי לדון.
- **שיהוי סובייקטיבי / אובייקטיבי** — צידוק לאיחור / נזק מהדיון.

13.20 נקודות מפתח למבחן

✔ שורה תחתונה — עיקרי הפרק

- בג"ץ: שיורי, ראשון ואחרון, עתירה; ס' 15(ג) (סעד למען הצדק + לא בסמכות אחרת) ו-15(ד) (ארבעה צווים).
- בית משפט לעניינים מנהליים (2000): עתירה/ערעור/תובענה לפי התוספות; ערעור לעליון בזכות או ברשות; ס' 6 (העברה לבג"ץ); ס' 9 (צו ביניים).
- צו על תנאי — רק בג"ץ; צו ביניים — בשתיהן.
- עילות הסף: עמידה (רסלר; קורן; אמסלם), שפיטות (נורמטיבית/מוסדית), פנייה מוקדמת ומיצוי, שיהוי (שלושה יסודות; 45 ימים; לשכת עוה"ד), בשלות (סבח מול חסון), ניקיון כפיים, עתירה תלויה (כספי — ו-2024), מעשה עשוי, תיאורטית.

13.21 שאלות בסגנון המבחן

✎ דוגמה — שאלה בסגנון המבחן (1)

איזו קביעה **נכונה** לגבי צו על תנאי וצו ביניים?

א. צו על תנאי ניתן לבקש בבית המשפט לעניינים מנהליים, וצו ביניים בשתי הערכאות. ב. צו על תנאי בבג"ץ, וצו ביניים רק בבית המשפט לעניינים מנהליים. ג. צו על תנאי בבג"ץ, וצו ביניים בשתי הערכאות. ד. שני הצווים בשתי הערכאות.

התשובה וההסבר

ג. וליתר דיוק — צו על תנאי אינו רק "ניתן לבקש": כל עתירה בבג"ץ נפתחת בבקשה לצו על תנאי.

✎ דוגמה — שאלה בסגנון המבחן (2)

בעל דין שאינו מרוצה מפסק דין של בית הדין האזורי לעבודה, אחרי שמיצה את הערעור בבית הדין הארצי. האם יכול "לערער" לבג"ץ?

א. כן, בזכות. ב. כן, ברשות. ג. לא — בג"ץ אינו ערכאת ערעור; אפשר להגיש עתירה, והוא יתערב רק בטעות מהותית. ד. לא — אין שום דרך.

התשובה וההסבר

ג. ס' 15(ד)(3) — ערכאת פיקוח.

13.22 שאלות לחשיבה

1. האם הרחבת זכות העמידה והשפיטות הייתה רצויה?

תשובה אפשרית: בעד — מאפשרת ביקורת על פגמים שאין להם "נפגע ישיר" (שחיתות, מינויים), ושומרת על שלטון החוק. נגד — מעבירה הכרעות פוליטיות לבית המשפט ופוגעת בלגיטימיות שלו; העלייה בשימוש בעילות סף חדשות היא חלק מתגובת-נגד.

2. למה בית המשפט עשוי לדון בעתירה מאוחרת על שחיתות?

תשובה אפשרית: כי היסוד השלישי — הפגיעה בשלטון החוק — עשוי לגבור על האיחור ועל הנזק; השארת פגם חמור בתוקף פוגעת באינטרס הציבורי יותר מהנזק שבדיון.

פרק 14

הבטחה מנהלית, השתק ותוצאות הפגמים — ושיטת פתרון למבחן

14.1 מבוא — למה זה חשוב ומה מקומו בתמונה הגדולה

הפרק המסכם עוסק בשני נושאים שסוגרים את "מפת הדרכים" של הקורס, ובשיטת עבודה למבחן. ראשית — **התחייבויות הרשות**: מתי הבטחה של רשות מחייבת אותה, מתי היא רשאית להשתחרר ממנה, ומה קורה כשאזרח הסתמך על מצג של מי שלא היה מוסמך (השתק, סמכות נחזית). שנית — **תוצאות הפגמים** (השאלה הרביעית מתוך ארבע השאלות של פרק 1): האם כל פגם מוביל לבטלות? כאן נכיר את **תורת הבטלות היחסית**, שהיא היום הכלל. ולבסוף — **שיטת פתרון** לשאלות מבחן אמריקאיות במשפט מנהלי.

14.2 שלושה סוגי התחייבויות של הרשות

סוג	מהותו	דין
חוזה רשות	הרשות מתקשרת בחוזה	**תחולה כפולה** — דיני החוזים ("חוזים יש לקיים") **וגם** המשפט המנהלי (דואליות נורמטיבית, פרק 3); כשהרשות מתקשרת כ"צד רגיל" (קייטרינג לקפיטריה) — דגש על הפרטי; כשהיא מתקשרת כ**קובעת מדיניות** (הסכמי משאבי טבע) — דגש על המנהלי
הסדר מנהלי	הסדר שמבוסס על הסכמת הפרט, כשהרשות יכלה להחליט גם בלי הסכמתו (הסדר טיעון, הסדר פשרה)	אותם תנאים כמו בהבטחה; וחלה הלכת ההשתחררות
הבטחה מנהלית	התחייבות **חד-צדדית** של הרשות	שלושה (או ארבעה) תנאים — להלן

הדרישה המקדמית לכל השלוש — **סמכות**. בלי סמכות — אף אחת מהן אינה מחייבת.

14.3 הבטחה מנהלית — התנאים

§ סעיף — ציטוט / הסעיף

הבטחה של רשות מחייבת רק אם: (1) ניתנה הבטחה **מפורשת, ברורה וחד-משמעית** — לא הצהרת כוונות כללית; (2) ניתנה בידי **בעל הסמכות** לתתה, בגדר סמכותו; (3) לנותן הייתה **כוונה להקנות לה תוקף משפטי מחייב**; (4) והוא **בעל יכולת** לקיים אותה. (ובפסיקה העדכנית — ניסוח של השופט גרוסקופף.)

ואם כל אלה התקיימו? — "הלכת ההשתחררות": הרשות רשאית לחזור בה כאשר **חל שינוי נסיבות**, או כאשר **אינטרס ציבורי חשוב** מצדיק זאת. הרשות אינה כבולה לעולם להחלטותיה (וזה גם ביטוי לאיסור כבילת שיקול הדעת — פרק 6). אבל לעיתים — השתחררות כרוכה ב**סעד לפרט**, למשל פיצוי.

פסק הדין	הקביעה
רגב נ' משרד הביטחון	ניסוח הכלל: לעיתים אפשר להשתחרר מחוזה שלטוני ("הלכת ההשתחררות"), ולהבטחות שלטוניות יש — בתנאים — תוקף משפטי
סאי טקס קוגן (1997)	הבטחה מחייבת רק בהתקיים **כל** היסודות: סמכות, כוונה משפטית, יכולת
מנבר (1998)	במרד אסירים — לגורם שנתן את ההבטחה (התובע הצבאי) הייתה סמכות לתתה
קכמן (אלמנות הטייסים)	לאיש שב"כ **אין סמכות** להבטיח הבטחות לנחקר בעבירות ביטחון — ההבטחה אינה מחייבת
שרוני (2025)	היו שופטים שסברו שלא ניתנה הבטחה בשל העדר סמכות; אחרים — שניתנה, אבל יש **צידוק לסגת** ממנה: השוויון בין משפחות חללי צה"ל
	הבטחה שהייתה כרוכה בהסדר טיעון "התמסמסה" כשההסדר בוטל; המדינה רשאית הייתה לחזור בה מטעמי אינטרס ציבורי

14.4 כשאין סמכות — השתק, סמכות נחזית ופיצויים

מה דינו של אזרח שהסתמך בתום לב על החלטה או מצג של מי ש**לא היה מוסמך**? עקרון החוקיות אומר: פעולה בלי סמכות אינה יוצרת זכות (עבאדה, פרק 2). אבל הפסיקה מכירה בכמה "תיקונים":

דוקטרינה	תוכן	דוגמה
השתק נגד הרשות	אין לדחות על הסף טענת השתק גם כשהפעולה לא הייתה חוקית — אלא **לאזן** בין האינטרסים	**עבדאמה נ' רשות הפיתוח** (השופטת דורנר)
סמכות נחזית	כשהאזרח, "הנבוך העומד בפני מסתרי מוסדות השלטון", הסתמך על מי שנחזה כמוסמך	**דישון כפר שיתופי נ' שר החקלאות:** בית המשפט הורה להגדיל מכסות, אף שההבטחה ניתנה בידי מי שלא הוסמך. מנגד — **עזבון שמעון נ' רשות מקרקעי ישראל:** הבטחת שר להקצות קרקעות — לא: "אין מדובר ב'אזרח הנבוך העומד בפני מסתרי מוסדות השלטון', אלא באנשי עסקים ותיקים ומנוסים... שכרו את שירותיהם של עורכי דין בכירים"
בטלות יחסית לגבי העבר	הפעולה בטלה — אבל התוצאה מותאמת לנסיבות	**מנצור נ' מדינת ישראל:** סגני שרים קיבלו שכר שלא כדין — יחזירו אותו רק מהיום שנודע שאינו כדין
פיצויים בנזיקין	המעשה הבלתי חוקי אינו מוכשר, אבל הנפגע שניתן שלא כדין; בית המשפט לא הכשיר את ההיתר — אך חייב מפוצה	**רוטברד נ' עיריית בני ברק:** הוועדה המחוזית ביטלה היתר בנייה לפצות את המסתמך על נזקו

(בשיינפלד, פרק 11, השתק שימש גם **נגד הפרט** — מי שהציג מצג לבית המשפט מנוע מלטעון להפך.)

14.5 תוצאות הפגמים — מבטלות מוחלטת לבטלות יחסית

הגישה	תוכן
הישנה	**בטלות** (void) — תוצאה של **חוסר סמכות**: הפעולה כאילו לא נעשתה מעולם, כלפי כולם. **נפסדות** (voidable) — תוצאה של טעות **בתוך** הסמכות: תקפה עד שבוטלה. (בדקה — כל פגם, בסמכות, בהליך או במהות, נחשב לחריגה מסמכות ומוביל לבטלות.)

הביניים שיקול הדעת של בית המשפט בעילות הסף כמסננת (**זילכה נ' ראש עיריית חולון** — עתירה לרישיון למכונות מזל שנדחתה שלא כדין, נדחתה בשל ניקיון כפיים)

היום — הוצעה בידי **ברק** (שפירא חברה קבלנית) ואומצה (**האגודה לזכויות האזרח נ' שר הפנים**): **בטלות יחסית** יש להבחין בין **הפגם** לבין **נפקותו**

✦ הגדרה — גיספן (2001), השופט זמיר

גיספן (2001), השופט זמיר: "במקום ההבחנה החדה שבין בטלות... לבין נפסדות... בא לעולם המבחן של בטלות יחסית. לפי מבחן זה יש להבדיל בין **הפגם** לבין **הנפקות**. הכלל הקובע מה מותר ומה אסור נמצא במישור אחד, ואילו הסעד על הפרת הכלל נמצא במישור אחר... לכן אין לשלול את האפשרות שחוסר סמכות לא יוביל בהכרח לבטלות מוחלטת."

⚖ פסק דין — עובדות והכרעה

העובדות בגיספן: חייל ערק 55 יום ונגזר לו מאסר על תנאי לתקופת תנאי של **שלוש** שנים, אף שהחוק התיר רק **שנתיים**; כשעבר שוב עבירה — טען שכל המאסר על תנאי בטל. זמיר — כרופא: קודם **אבחנה** (הפגם), אחר כך **טיפול** (הסעד); לא כל חולה מקבל אותו טיפול. בית המשפט היה מוסמך לגזור מאסר על תנאי; הפגם — בהיקף התקופה בלבד; לא נגרם עיוות דין (העבירה החוזרת בוצעה תוך זמן קצר); ויש למנוע "ניצול פגמים" — ההפעלה נותרה בתוקף.

מאפייני הבטלות היחסית:

- הבטלות יחסית ל**פגם, לנסיבות ולהקשר** — שונה ממקרה למקרה;
- נורמה יכולה להיות **תקפה לגבי אלמוני ובטלה לגבי פלמוני** (אזרזר, פרק 9);
- אותה עילה יכולה להוביל ל**בטלות מיידית** במקרה אחד ול**סעד עתידי** במקרה אחר;
- שיקולים: חומרת הפגם, הנסיבות, ההסתמכות, האינטרס הציבורי, ההרתעה.

סעדים גמישים: בית המשפט מעדיף להחזיר את העניין לרשות; משעה את הבטלות; קובע תחולה עתידית; ואף נותן **"התראת בטלות"**. **המרכז האקדמי למשפט ועסקים נ' הכנסת:** הכנסת העבירה שוב ושוב תיקונים לחוק יסוד כ"הוראת שעה" כדי לאשר תקציב דו-שנתי. בית המשפט לא ביטל (התקציב כבר חולק; וזהירות מביטול חוק יסוד) — אבל הזהיר: בפעם הבאה — יבוטל.

ביקורת — עינת הראל נ' מדינת ישראל: מי שסבר שהחלטה פגומה (לא ניתנה לו זכות טיעון) היה צריך לתקוף אותה **תקיפה ישירה**, ולא להתעלם מהצו. הבטלות היחסית מקשה על "תקיפה עקיפה" — אי אפשר להניח שההחלטה בטלה ולהתעלם ממנה; והיא משדרת לרשות שגם פגם חמור "לא בהכרח" יוביל לבטלות.

14.6 שיטת פתרון — מבחן אמריקאי במשפט מנהלי

מבחן טיפוסי בקורס: **רב-ברירתי** (כ-25 שאלות), ללא חומר עזר, יש לבחור "**התשובה הנכונה ביותר**". השאלות בודקות שלושה דברים: **היכרות עם הלכות** ופסקי דין, **הבחנות** בין מושגים קרובים, ו**יישום** על תרחיש.

1. **קראו את השאלה לפני התשובות.** זהו מה נשאל: סמכות? הליך? מהות? עילת סף? ערכאה? תוצאה?
2. **מקמו את התרחיש במפה:** ארבע השאלות (ערכאה; סף; עילות; סעד) ושלוש קבוצות העילות (סמכות; פרוצדורה; שיקול דעת).
3. **שימו לב למילות מפתח:** "רשאי" מול "חייב" (אופנהיימר); "בכפוף לכל דין" (ס' 32); "שאינה בעלת אופי שיפוטי" (ס' 34); "חשש סביר" מול "אפשרות ממשית" (ניגוד עניינים); "השפעה ממשית" (ברגר); "במידה המתקבלת על הדעת" (סמכות עזר); "מפורשת, ברורה וחד-משמעית" (הבטחה).
4. **הכירו את מבנה ה"מלכודות":** תשובה שנכונה **חלקית** (למשל "צו ביניים רק בבג"ץ"); תשובה שמשקפת **דעת מיעוט** או אמרת אגב (לנדוי בדפי זהב; חשין ברונן ובחורב); תשובה שמשקפת את **ההלכה הישנה** (בטלות מוחלטת; Wednesbury); ותשובות "ג' נכונה ואולם..." / "כל התשובות נכונות".
5. **סלקו תשובות** מוחלטות מדי ("תמיד", "לעולם", "בכל מקרה") — המשפט המנהלי מלא "כלל + חריג".
6. **הבחינו בין דומים:** סבירות/מידתיות; שיקול זר/הפליה; האצלה/הסתייעות/העברה; עתירה/ערעור/תובענה; צו על תנאי/צו ביניים; שיהוי סובייקטיבי/אובייקטיבי; התייעצות

סטטוטורית/וולונטרית; פרסום ברשומות/העמדה לעיון.

7. **בתשובה "הנכונה ביותר"** — אם שתיים נכונות, בחרו את המלאה והמדויקת יותר.

14.7 מפת הקורס

שאלה	הנושא	פרקים
על מי חל?	גופים ציבוריים, דו-מהותיים	3
לאן פונים?	בג"ץ / בית משפט לעניינים מנהליים	13
תנאי סף?	עמידה, שפיטות, מיצוי, שיהוי, בשלות, ניקיון כפיים, עתירה תלויה	13
סמכות?	חוקיות המנהל; פרשנות; הסדרים ראשוניים; שיורית ועזר; עצמאות שיקול הדעת	2, 4, 5, 6
הליך?	תשתית עובדתית; שימוע; ניגוד עניינים; הנמקה; היוועצות; פרסום	7, 8, 9
שיקול דעת?	שיקולים זרים; שוויון; סבירות; מידתיות; משקל ראוי לזכויות	10, 11, 12
תוצאה?	בטלות יחסית; סעדים; הבטחה, השתק, פיצויים	14

14.8 מלכודות נפוצות

! שים לב — מלכודות נפוצות

- לחשוב שכל הבטחה של רשות מחייבת — נדרשים כל התנאים, ויש הלכת השתחררות.
- לחשוב שהבטחה של מי שאינו מוסמך מחייבת תמיד — רק בחריגים (סמכות נחזית, השתק — באיזון).
- לחשוב שחוסר סמכות מוביל תמיד לבטלות מוחלטת — היום בטלות יחסית (גיספן).
- לחשוב שאפשר להתעלם מהחלטה "בטלה" — יש לתקוף אותה ישירות (עינת הראל).
- בבחינה — לבחור תשובה שמשקפת דעת מיעוט או הלכה ישנה.

14.9 שלד לפתרון שאלה — התחייבות הרשות ותוצאות הפגם

1. **סווגו את ההתחייבות:** חוזה רשות, הסדר מנהלי (מבוסס הסכמה) או הבטחה מנהלית. בכולן נדרשת סמכות.
2. **הבטחה מנהלית – תנאים (סאי טקס):** מפורשת וברורה, בידי בעל סמכות, בכוונה להקנות תוקף משפטי, וביכולת לקיימה.
3. **אין סמכות?** בחנו השתק, סמכות נחזית (דישון), הגנת מסתמך (עבדאמה – איזון) ופיצויים (רוטברד). בחנו אם המסתמך "אזרח נבוך" (עזבון שמעון).
4. **השתחררות:** הרשות רשאית לסגת בשל שינוי נסיבות או אינטרס ציבורי חשוב (רגב), לעיתים תוך פיצוי.
5. **תוצאת הפגם (גיספן):** הבחינו בין הפגם לבין נפקותו; התאימו סעד: בטלות מלאה, יחסית, התראת בטלות, או השבה מהיום (מנצור).

14.10 מלכודות בפתרון שאלות — טבלה

הטעות	למה היא שגויה	התיקון
לחשוב שהבטחה מחייבת תמיד להתעלם מחוסר סמכות בהבטחה לראות בכל פגם בטלות מוחלטת להתעלם מצו פגום לבחור תשובות עם "תמיד" או "בכל מקרה"	הרשות רשאית להשתחרר בשל אינטרס ציבורי או שינוי נסיבות מנבר: לאיש שב"כ אין סמכות להבטיח לנחקר גיספן: בטלות יחסית – הפגם מול הנפקות עינת הראל: יש לתקוף ישירות ולא להתעלם המשפט המנהלי הוא כלל וחריג	לבחון תנאים והשתחררות לבדוק סמכות קודם להתאים סעד תקיפה ישירה לחשוד במילים מוחלטות

14.11 תרגיל פתור — הבטחה של פקיד בכיר

✎ דוגמה — הבטחה שנסתמכו עליה

העובדות: מנהל מחלקה במשרד ממשלתי הבטיח בכתב ליזם כי יאושר לו היתר מיוחד אם ישקיע בבניית מתקן. היזם השקיע סכום גדול. לאחר מכן התברר שמנהל המחלקה אינו מוסמך לתת היתרים מסוג זה, והמשרד מסרב לתת היתר.

הפתרון:

1. **סיווג:** הבטחה מנהלית.
2. **תנאים:** מפורשת וברורה (כתובה) – כן; ניתנה בידי בעל סמכות – לא; בכוונה משפטית – ייתכן; יכולת לקיים – תלוי בסמכות. התנאי השלישי של סמכות נכשל (מנבר).
3. **סמכות נחזית:** האם ליזם היה מראה סביר שמנהל המחלקה מוסמך? האם הוא "אזרח נבוך" או איש עסקים מנוסה (עזבון שמעון, דישון)?
4. **הגנת המסתמך:** איזון בין האינטרס הציבורי בחוקיות לאינטרס היזם (עבדאמה).
5. **הסעד:** ייתכן שהיתר לא יינתן (פעולה בלי סמכות לא יוצרת זכות), אך פיצוי על הסתמכות סביר (רוטברד).

14.12 סיכום הפרק

✔ שורה תחתונה — סיכום הפרק

- שלוש התחייבויות של הרשות: חוזה רשות, הסדר מנהלי, הבטחה מנהלית – כולן דורשות סמכות.
- תנאי ההבטחה: מפורשת, בידי מוסמך, בכוונה משפטית, ויכולת לקיימה (סאי טקס); מנבר מול קוגן; הלכת ההשתחררות (רגב).
- חוסר סמכות: השתק (עבדאמה), סמכות נחזית (דישון), פיצויים (רוטברד); "אזרח נבוך" מול איש עסקים (עזבון שמעון).
- גיספן: בטלות יחסית – הבחנה בין פגם לנפקות; התראת בטלות; מנצור – השבה מהיום.
- שיטת פתרון: מיקום השאלה במפה, סינון מוחלטים, זיהוי אמרות אגב ודעות מיעוט.

14.13 מילון מושגים

- **הבטחה מנהלית** — התחייבות חד-צדדית של הרשות.
- **הלכת ההשתחררות** — חזרה מהבטחה או חוזה בשל שינוי נסיבות או אינטרס ציבורי חשוב.
- **השתק** — מניעה מלטעון בניגוד למצג קודם.
- **סמכות נחזית** — מי שנראה מוסמך בעיני אזרח סביר.
- **בטלות / נפסדות** — void / voidable.
- **בטלות יחסית** — הפרדה בין הפגם לנפקותו.
- **התראת בטלות** — אזהרה שבפעם הבאה תבוטל הנורמה.
- **תקיפה ישירה / עקיפה** — תקיפת ההחלטה עצמה / טענה לבטלותה בהליך אחר.

14.14 נקודות מפתח למבחן

✔ שורה תחתונה — עיקרי הפרק

- חוזה רשות (תחולה כפולה), הסדר מנהלי, הבטחה מנהלית — כולם דורשים סמכות.
- תנאי ההבטחה: מפורשת וברורה; בעל סמכות; כוונה משפטית; יכולת. השתחררות: שינוי נסיבות / אינטרס ציבורי חשוב (ולעיתים פיצוי).
- קוגן (סמכות) מול מנבר (אין סמכות); קכמן (צידוק לסגת — שוויון).
- עבדאמה (השתק באיזון); דישון (סמכות נחזית) מול עזבון שמעון (אנשי עסקים מנוסים); מנצור; רוטברד (פיצוי).
- בטלות/נפסדות → בטלות יחסית (ברק; האגודה לזכויות האזרח; גיספן — פגם מול נפקות); התראת בטלות; עינת הראל.
- שיטת פתרון: מיקום במפה; מילות מפתח; מלכודות (מיעוט, הלכה ישנה, חלקי); הבחנות בין דומים.

14.15 שאלות בסגנון המבחן

✎ דוגמה — שאלה בסגנון המבחן (1)

פקיד זוטר במשרד ממשלתי הבטיח בעל פה לחברה גדולה, המיוצגת בידי משרד עורכי דין מוביל, הקצאת קרקע. לפקיד אין סמכות להקצות קרקעות. מה הדין?

א. ההבטחה מחייבת — החברה הסתמכה עליה. ב. ההבטחה אינה מחייבת — חסרה סמכות; ונראה שגם אין מקום לסמכות נחזית מול גוף עסקי מנוסה ומיוצג. ג. ההבטחה מחייבת לפי הלכת ההשתחררות. ד. ההבטחה מחייבת כי ניתנה בתום לב.

התשובה וההסבר

ב. תנאי הסמכות; ועזבון שמעון — לא "אזרח נבוך". ג' — הלכת ההשתחררות מאפשרת לרשות לחזור בה, לא מחייבת אותה.

✎ דוגמה — שאלה בסגנון המבחן (2)

מה קבע השופט זמיר בגיספן?

א. שחוסר סמכות מוביל תמיד לבטלות מוחלטת. ב. שיש להבחין בין הפגם לבין נפקותו — וחוסר סמכות אינו מוביל בהכרח לבטלות מוחלטת. ג. שאין ביקורת על בתי דין צבאיים. ד. שנפסדות היא הכלל.

התשובה וההסבר

ב. תורת הבטלות היחסית. א' — הגישה הישנה.

14.16 שאלות לחשיבה

1. האם הבטלות היחסית מחזקת או מחלישה את שלטון החוק?

תשובה אפשרית: היא מאפשרת סעד צודק ומונעת תוצאות קשות לצדדים תמי לב — וכך מגינה על הסתמכות ועל האינטרס הציבורי. מנגד, היא מחלישה את ההרתעה: רשות יודעת שגם פגם חמור לא בהכרח יבטל את ההחלטה, והפרט נשאר בחוסר ודאות.

2. למה מותר לרשות להשתחרר מהבטחה, ומה ההגנה של הפרט?

תשובה אפשרית: הרשות נאמנת לציבור ואסור לה לכבול את שיקול דעתה לנצח; שינוי נסיבות או אינטרס ציבורי חשוב עשויים לחייב שינוי. ההגנה — דרישת צידוק ממשי, והסעד: לעיתים פיצוי במקום אכיפה.